

## (2) 공평성과 통일성의 결여

(가) 기여상속인이 기여의 평가로서 다액의 “증여·유증을 받은 경우”와 “분할 시에 기여분으로 상속재산의 취득한 경우”는 그의 지위가 같지 않다. 즉, 기여상속인의 위와 같은 취득으로 인하여 다른 상속인의 취득액이 그의 유류분액에 미달되는 경우에, 전자의 경우에는 그 부족액을 증여·유증에서 반환청구 당하게 되지만, 후자의 경우에는 기여분으로부터 반환청구 당하지 않는다.

(나) 제3자 또는 기여 없는 상속인이 증여 또는 유증을 받았기 때문에 기여상속인 등 다른 상속인의 유류분권이 침해되었을 경우, 분할할 상속재산이 있으면 기여상속인의 기여분이 인정될 수 있지만, 분할할 상속 재산이 없으면 기여분은 인정될 여지가 없고, 다른 상속인과 동일한 액에 의하여 반환청구만이 가능할 뿐이다.

(다) 위와 같은 불공평, 불통일성을 해소하기 위하여는 기여분의 가액결정시 다른 공동상속인의 유류분을 참작하여야 한다.

## (3) 유류분반환청구와 기여분 청구를 병합할 수 있는지 여부

“기여분 청구는 가사소송법 제2조 소정의 마류 가사비송사건으로서 민사사건인 유류분 반환 청구사건과는 소송절차를 달리하여 심판되는 것으로서 청구의 병합이 허용되지 않을 뿐만 아니라, 기여분의 결정은 상속재산분할의 청구가 있을 경우 또는 피인지자 등의 상속분에 상당한 가액의 지급 청구가 있는 경우에 한하여 비로소 할 수 있는 것이므로 기여분 청구가 상속재산분할의 청구를 전제로 함이 없이 일반 민사사건인 유류분반환청구사건에 추가적으로 병합 청구된 경우, 기여분반환청구부분에 대한 소는 부적법하다.”는 하급심 판례<sup>218)</sup>가 있다.

기여분은 상속재산분할의 전제문제로서의 성격을 갖는 것이므로 상속재산분할의 청구나 조정신청이 있는 경우에 한하여 기여분결정청구를 할 수 있고, 다만 예외적으로 상속재산분할 후에라도 피인지자나 재판의 확정에 의하여 공동상속인이 된 자의 상속분에 상당한 가액의 지급청구가 있는 경우에는 기여분의 결정청구를 할 수 있다고 해석되며, 상속재산분할의 심판청구가 없음에도 단지 유류분반환청구가 있다는 사유만으로는 기여분결정청구가 허용된다고 볼 것은 아니다.<sup>219)</sup>

218) 광주지방법원 1999. 12. 02. 선고 99가합207 판결: 항소.

219) 대법원 1999. 08. 24. 선고 99스28 판결.

## 제7절 유류분반환청구권

### 제1관 총 설

#### 1. 의 의

“유류분(遺留分)”이란 상속 재산 가운데 상속을 받은 사람이 마음대로 처리하지 못하고 일정한 범위의 상속인이 법률상 반드시 취득하도록 보장되어 있는 상속재산의 가액을 말한다. 따라서 피상속인이 하는 유증이나 증여에 의해서 침해되는 경우 상속인은 유류분반환청구권을 가진다(민법 제1112조부터 제1118조까지).

피상속인은 생전에 자신의 재산을 자유로이 처분하거나 다른 사람에게 줄 수 있을 뿐만 아니라, 사후에도 유증의 형태로 자신의 재산을 자유로이 다른 사람에게 줄 수 있다. 그러나 피상속인의 재산 전체를 타인에게 주거나, 일방적으로 가족 한 사람에게만 주는 경우, 또한 재산을 사회단체에 전부 출연한다면 남아 있는 가족은 생계위협을 느낄 뿐만 아니라, 공평한 재산승계를 할 수 없다. 따라서 가족의 최소한 물질적 기초를 확보함과 동시에 사회정책적인 입장에서 필요하다고 하여 법이 일정한 범위의 상속인이 공평한 재산승계를 할 수 있도록 하는 제도를 마련하는 것이 유류분제도이다.

유류분 반환제도는 피상속인의 증여 및 유증으로 그 유류분에 부족이 생긴 유류분권자에게 그 부족한 한도 내에서 이를 회복하기 위하여 마련된 것이고 원물반환이나 가액반환은 부족한 유류분의 한도로 재산을 반환받는 방법만 다를 뿐이므로 어느 방법이든지 반환되는 재산의 가치는 사실심 변론종결 시를 기준으로 동일하게 유지되어야 한다. 따라서 원물반환이 불가능한지 여부에 따라 반환할 가액의 산정 기준이 달라지지 아니한다(대법원 2021. 6. 10. 선고 2021다213514 판결).

#### 2. 유류분제도의 기능

유류분제도는 상속재산분배의 최소한의 합리화, 피상속인의 유언자유에 대한 유족의 공헌의 참작, 피상속인의 유족의 생활 고려 등 유언자유와 가족공유의 갈등을 조화하는 제도이다.

유류분제도에 관한 민법 제1112조, 제1113조, 제1118조와 제1008조가 피상속인의 재

산처분의 자유와 수증자의 재산권을 과도하게 침해함으로써 헌법 제23조 제1항과 제37조 제2항에 위반된다고 할 수 없다. 그 이유는 다음과 같다.

유류분제도는 피상속인의 재산처분행위로부터 유족의 생존권을 보호하고 법정상속분의 일정 비율에 해당하는 부분을 유류분으로 산정하여 상속인의 상속재산 형성에 대한 기여와 상속재산에 대한 기대를 보장하는 데 그 목적이 있다. 민법 제1118조에 따라 준용되는 민법 제1008조는 공동상속인 중에 피상속인으로부터 재산의 증여 또는 유증을 받은 특별 수익자가 있는 경우에 공동상속인 사이의 공평을 도모하기 위하여 수증자산을 상속분의 선급으로 다루어 구체적인 상속분을 산정하는 데 참작하도록 하려는 데 그 취지가 있다.

유류분제도가 피상속인이 생전에 자유롭게 처분하는 것을 원천적으로 막는 것은 아니다. 또한 공동상속인이 피상속인으로부터 받은 증여가 모두 유류분반환의 대상인 특별수익이 되는 것은 아니고, 어떠한 생전 증여가 특별수익에 해당하는지는 피상속인의 생전의 자산, 수입, 생활수준, 가정상황 등을 참작하고 공동상속인 사이의 형평을 고려하여 생전 증여가 장차 상속인으로 될 사람에게 돌아갈 상속재산 가운데 그의 몫 일부를 미리 주는 것이라고 볼 수 있는지에 따라 판단된다. 유류분의 범위도 법정상속분의 일부로 제한되어 있다.

따라서 유류분제도에 관한 민법 제1112조, 제1113조, 제1118조와 제1008조에 따라 피상속인의 재산처분 자유와 수증자의 재산권이 과도하게 침해된다고 보기 어렵다.

### 3. 각국의 유류분제도<sup>220)</sup>

#### 가. 독일 민법

유류분액을 법정상속인의 상속분의 2분의 1로 하고, 피상속인의 직계비속 부모 및 배우자가 사인처분으로 인하여 배제된 경우에도 유류분청구권만은 인정한다(독일민법 제2303조).

#### 나. 프랑스 민법

피상속인의 사망 당시 자가 1인인 때에는 전유산의 2분의 1, 2인인 때에는 3분의 1, 3인 이상인 때에는 4분의 1 이상을 피상속인은 유증할 수 없고(프랑스 민법 제913조), 만약 자가 없고 부계 및 모계의 직계존속친이 1인 내지 수인인 때에는 전 유산의 2분의 1, 1계 만에 직계존속친이 있을 때에는 4분의 3 이상을 유증할 수 없다(동법 제914조).

220) 배경숙·최금숙, 앞의 책, 580면.

### 다. 스위스

직계비속은 그 법정상속분의 3/4, 부모는 1/2, 형제자매는 1/4, 배우자는 다른 법정상속인이 있는 때에는 상속분 전부, 없는 때에는 전유산의 1/2의 유류분을 인정한다(스위스 민법 제417조).

### 라. 중국

직계비속, 부모, 배우자에 대하여는 각각 상속분의 1/2, 형제자매와 조부모에 대하여는 각각 상속분의 1/3의 유류분을 인정한다(중국민법 제1223조).

### 마. 일본

직계비속과 배우자가 상속인 때에는 전유산의 1/2, 그 밖의 상속인에 대하여는 1/3의 유류분을 인정한다(일본민법 제1028조).

## 4. 유류분의 포기 인정 여부

### 가. 유류분권

상속이 개시되면 일정한 범위의 상속인이 피상속인의 재산의 일정한 비율을 확보할 수 있는 지위를 가지는 것을 유류분권이라 한다. 유류분의 침해행위로 부족이 생긴 때에는 그 부족한 한도에서 재산의 반환을 요구할 수 있는 반환청구권이라는 파생적 권리가 이 유류분권으로부터 생긴다.

### 나. 상속개시전의 포기

유류분권은 개인적인 재산권이므로 이를 포기하는 것은 자유이다. 그러나 상속개시 전에는 유류분을 포기할 수 없다.<sup>221)</sup> 이를 허용한다면 피상속인이 위력을 행사하여 상속인이 될 자에게 포기를 강요하는 일이 생길 수 있다. 배우자상속권의 확립과 자녀균분 상속의 취지를 살린다는 의미에서 사전포기를 인정하지 않는 것은 타당하다.

유류분을 포함한 상속의 포기는 상속이 개시된 후 일정한 기간 내에만 가능하고 가정법원에 신고하는 등 일정한 절차와 방식에 따라야만 그 효력이 있으므로, 상속개시 전에

221) 박윤직, 앞의 책(상속법), 282면; 김주수·김상용, 앞의 책, 738면; 박병호, 앞의 책, 473면.



이루어진 상속포기약정은 그와 같은 절차와 방식에 따르지 아니한 것으로 그 효력이 없다.<sup>222)</sup>

#### 다. 상속개시 후의 포기

민법상 명문의 규정이 없으나 다수설<sup>223)</sup>은 유류분권에서 유출하는 개개의 유류분반환청구권은 개인적 재산권이므로 이를 포기하는 것은 자유라고 한다.

#### 라. 포기의 효과

민법상 명문의 규정이 없으나 유류분권리자가 유류분을 포기하면 처음부터 그 유류분권리자는 없었던 것으로 되고, 유류분권은 다시 산정되어야 한다.

## 제2관 유류분의 청구권

### 1. 서 설

유류분권리자가 피상속인의 증여 및 유증으로 인하여 그 유류분에 부족이 생긴 때에는 부족한 한도에서 그 재산의 반환을 청구할 수 있다(민법 제1115조제1항).

이때 피상속인이 한 증여는 상속개시 전 1년 이내의 것이어야 하는 것이 원칙이나, 상속인에 대한 증여 또는 유류분이 침해되는 것을 알고 행한 증여는 기간의 제한 없이 해당된다(민법 제1114조 및 대법원 1996. 9. 25. 선고 95다17885 판결).

한편 고인이 살아생전에 재산을 다른 사람에게 전부 증여하더라도 가족은 이에 대하여 어떠한 법적 조치를 할 수 없다.

### 2. 유류분 청구권자 및 반환의 상대방

#### 가. 청구권자

##### (1) 직계비속, 배우자, 직계존속, 형제자매

피상속인의 직계비속, 배우자, 직계존속, 형제자매이다. 태아도 살아서 출생하면 직계비

222) 대법원 1994. 10. 14. 선고 94다8334 판결.

223) 김주수·김상용, 앞의 책, 737면; 송덕수, 앞의 책, 1973면.

속으로 유류분을 가진다. 대습상속인도 피상속자의 상속분의 범위 내에서 유류분권을 가진다. 따라서 직계비속인 자녀가 있으면 그들 자녀와 그 대습자가 제1순위로 유류분권자가 되고, 직계비속인 자녀나 그 대습자가 없으면 직계존속이 유류분권자이다. 배우자는 직계비속과 그의 대습자가 있으면 이들과 함께 유류분권자로 되나, 이들이 없는 때에는 단독으로 유류분권자가 된다. 형제자매는 이들 모두 없는 때에 유류분권자가 된다.

※ 법무부는 2021. 11. 9. 형제자매를 유류분 권리자에서 제외하는 민법 일부개정법률(안)과 가사소송법 일부개정법률(안)을 입법예고하였다(법무부공고 제2021-341호).

입법예고의 취지는 현행법은 상속인의 상속재산에 대한 기여를 인정하여 상속인들의 생계보장을 위한 최소한의 권리로서 유류분을 인정하는 등 상속인의 상속재산에 대한 기대를 일정 부분 보장하는 한편, 특정한 경우 상속인이 될 수 없도록 결격사유를 규정하고 있다. 그런데 상속인이 될 사람이 피상속인에 대한 민법상 보호, 교양의무를 해태한 경우에도 피상속인의 사망 후 상속재산을 법정 상속하도록 하는 것은 구체적 타당성이 결여되어 있다는 지적이 이어지고 있음. 그리고 유류분제도 또한 법 개정을 통해 최초로 도입된 1970년대와는 달리 현재는 상속인들의 희생과 기여가 인정되는 가족재산으로서의 상속재산을 인정하기 어렵다는 점에서 제도의 시의성 및 구체적 타당성을 제고하기 위한 개정의 필요성이 지적되고 있다.

이에 상속인이 될 사람이 피상속인에 대한 민법상 보호, 교양의무를 해태한 경우에는 피상속인의 배우자 또는 공동상속인 등 일정한 자의 청구에 의해 가정법원에서 상속권 상실의 선고를 할 수 있도록 하고, 유류분의 권리자의 범위를 축소하려는 것이다(안 제1004조의2 신설 및 제1112조).

## (2) 태 아

태아는 상속에 관하여 이미 출생한 것으로 보기 때문에 살아서 출생하면 유류분권을 갖는다.

## (3) 상속결격자와 상속을 포기한 자

상속결격자와 상속을 포기한 자는 상속인이 아니므로 유류분권자가 되지 못한다.

#### (4) 대습상속인의 유류분반환청구권

대습상속인도 보통의 상속인과 마찬가지로 유류분권리자가 된다. 대습상속인의 상속분은 상속을 받을 수 있었던 피대습인의 상속분만큼을 상속받게 되므로 유류분액도 이를 기준으로 계산한다(민법 제1118조 및 제1001조).

상속인이 될 직계비속 또는 형제자매가 상속개시 전에 사망하거나 결격자가 된 경우(민법 제1000조제1항제1호 및 제3호)에 그 직계비속이 있는 때에는 그 직계비속이 사망하거나 결격된 사람의 순위에 갈음하여 상속인이 되며, 이러한 대습상속인도 유류분반환청구를 할 수 있다(민법 제1118조 및 제1001조). 배우자가 대습상속인인 경우에도 유류분반환청구권을 행사할 수 있다(민법 제1118조 및 제1010조제2항).

사망 또는 결격된 사람에 갈음하여 상속인이 된 사람, 즉 대습상속인의 유류분은 사망 또는 결격된 사람의 상속분에 따른다(민법 제1118조 및 제1010조제1항). 사망 또는 결격된 사람의 직계비속이 여러 명인 때(민법 제1010조제1항)에는 그 유류분은 사망 또는 결격된 사람의 상속분의 한도에서 유류분에 따라 이를 정한다(민법 제1118조 및 제1010조제2항).

#### (5) 특별수익자의 유류분반환청구권

공동상속인 중에 피상속인으로부터 재산의 증여 또는 유증을 받은 사람이 있는 경우에 그 수증재산이 자기의 상속분에 달하지 못한 때에는 그 부족한 부분의 한도에서 상속분이 있고, 유류분청구권도 있다(민법 제1118조 및 제1008조).

#### (6) 반환의 상대방

자신의 유류분액을 침해하여 유증 또는 증여를 받은 사람이 유류분청구의 상대방이 된다.

### 3. 유류분의 비율(민법 제1112조)

| 유류분을 가지는 자     | 비율         |
|----------------|------------|
| (1) 피상속인의 직계비속 | 법정상속분의 1/2 |
| (2) 피상속인의 배우자  | 법정상속분의 1/2 |
| (3) 피상속인의 직계존속 | 법정상속분의 1/3 |
| (4) 피상속인의 형제자매 | 법정상속분의 1/3 |

### 4. 유류분액의 산정방법과 계산

#### 가. 민법 제1113조

유류분은 피상속인의 상속개시 시에 있어서 가진 재산의 가액에 증여재산의 가액을 가산하고 채무의 전액을 공제하여 이를 산정한다. 즉, 유류분산정의 기초가 되는 재산=(상속개시 시에 가진 재산)+(증여재산)-(채무)

#### 나. 상속개시시에 가진 재산

(1) 피상속인의 상속개시에 있어서 가지는 재산이란 상속개시로 상속인이 승계한 상속재산 중의 적극재산을 말한다. 적극재산에 포함되지 않는 재산은 제사용 재산<sup>224)</sup>과 피상속인의 일신에 전속한 권리이다. 유류분 산정의 기초가 되는 증여 부동산의 가액 산정 시기를 피상속인이 사망한 상속개시 당시의 가격으로 판시한 것은 정당하다.<sup>225)</sup>

(2) 유류분 가액의 산정에 있어 상속부동산에 대한 월 임대료 수익은 그 부동산의 상속 당시 시가인 교환가격에 포함되어 있으므로 별도의 상속재산이라 할 수 없고, 상속세, 등기비용, 장례비 등은 유증자 사망 후에 지출된 비용으로서 상속개시시의 재산에서 이를 공제할 성질의 것이 아니다.<sup>226)</sup>

(3) 유류분은 피상속인의 상속개시 시에 있어서 가진 재산의 가액에 상속개시 전의 1년간에 행한 증여재산의 가액을 가산하고 채무의 전액을 공제하여 산정하며 유증한 재산

224) 민법 제1008조의3(분묘에 속한 1정보 이내의 금양임야와 600평 이내의 묘토인 농지, 족보와 제구의 소유권은 제사를 주재하는 자가 이를 승계한다).

225) 대법원 1996. 02. 09. 선고 95다17885 판결.

226) 창원지방법원 1992. 09. 25. 선고 90가합9001 제4민사부판결 : 항소.

은 상속개시 시에 현존하는 재산으로 볼 것이므로, 수증자가 망인으로부터 유증받은 부동산의 가액도 망인의 총재산가액에 포함시켜 계산한 결과 망인의 상속개시의 총재산의 가액을 기준으로 한 상속인들의 유류분과 그들의 실제 상속재산의 가액을 대비하여 그 유류분에 부족이 생겼다면, 수증자는 상속인들에게 유증받은 부동산에 관하여 그 부동산의 상속개시시의 가액 중 그 유류분 부족분에 해당하는 금원만큼씩의 지분비율에 따른 소유권이전등기절차를 이행할 의무가 있다.<sup>227)</sup>

(4) 유류분액을 산정함에 있어 반환의무자가 증여받은 재산의 시가는 상속개시 당시를 기준으로 산정하여야 하고, 당해 반환의무자에 대하여 반환하여야 할 재산의 범위를 확정하는 다음 그 원물반환이 불가능하여 가액반환을 명하는 경우에는 그 가액은 사실심 변론종결시를 기준으로 산정하여야 한다.<sup>228)</sup>

(5) 대습상속인이 대습원인의 발생 이전에 피상속인으로부터 증여를 받은 경우 특별수익에 해당되는가? 판례<sup>229)</sup>는 “피상속인 갑이 사망하기 이전에 갑의 자녀들 중 을 등이 먼저 사망하였는데, 갑이 을 사망 전에 을의 자녀인 병에게 임야를 증여한 사안에서, 병이 갑으로부터 임야를 증여받은 것은 상속인의 지위에서 받은 것이 아니므로 상속분의 선급으로 볼 수 없어 특별수익에 해당하지 아니하여 유류분 산정을 위한 기초재산에 포함되지 않는다.”고 한다.

## 다. 증여재산의 가산

### (1) 상속개시 전 1년간의 증여

증여재산은 상속개시 전의 1년간 행하여진 것에 한하여 상속재산의 가액에 가산한다. 따라서 상속개시 1년 전에 증여한 재산은 가산하지 않는다. 다만, 유류분 권리자에게 손해를 가할 것을 알고 증여한 때에는 1년 전에 증여한 것도 가산한다.

유류분 산정의 기초가 되는 재산의 범위에 관한 민법 제1113조 제1항에서의 ‘증여재산’이란 상속개시 전에 이미 증여계약이 이행되어 소유권이 수증자에게 이전된 재산을 가리키는 것이고, 아직 증여계약이 이행되지 아니하여 소유권이 피상속인에게 남아 있는 상태로 상속이 개시된 재산은 당연히 ‘피상속인의 상속개시 시에 있어서 가진 재산’에 포함되는 것이므로, 수증자가 공동상속인이든 제3자이든 가리지 아니하고 모두 유류분 산정의 기초

227) 부산고등법원 1991. 01. 23. 선고 90나3188 제2부판결: 확정.

228) 대법원 2005. 06. 23. 선고 2004다51887 판결.

229) 대법원 2014. 05. 29. 선고 2012다31802 판결.

가 되는 재산을 구성한다.<sup>230)</sup>

증여 당시 법정상속분의 2분의 1을 유류분으로 갖는 직계비속들이 공동상속인으로서 유류분권리자가 되리라고 예상할 수 있는 경우에, 제3자에 대한 증여가 유류분권리자에게 손해를 가할 것을 알고 행해진 것이라고 보기 위해서는, 당사자 쌍방이 증여 당시 증여재산의 가액이 증여하고 남은 재산의 가액을 초과한다는 점을 알았던 사정뿐만 아니라, 장래 상속개시일에 이르기까지 피상속인의 재산이 증가하지 않으리라는 점까지 예견하고 증여를 행한 사정이 인정되어야 하고, 이러한 당사자 쌍방의 가해의 인식은 증여 당시를 기준으로 판단하여야 한다.<sup>231)</sup>

## (2) 공동상속인

공동상속인 중에 피상속인으로부터 재산의 생전 증여에 의하여 특별수익을 한 자가 있는 경우에는 민법 제1114조의 규정은 그 적용이 배제되고, 따라서 그 증여는 상속개시 1년 이전의 것인지 여부, 당사자 양쪽이 손해를 가할 것을 알고서 하였는지 여부에 관계없이 유류분 산정을 위한 기초재산에 산입된다. 공동상속인이 피상속인으로부터 받은 특별수익분은 그 수익일자가 상속개시일 전 1년 이내인지 여부에 관계없이 그 상속인의 유류분 산정에 포함되는 재산에 해당한다.<sup>232)</sup>

즉, ‘공동상속인 중에 피상속인으로부터 재산의 증여 또는 유증을 받은 자가 있는 경우에 그 수증재산이 자기의 상속분에 달하지 못한 때에는 그 부족한 부분의 한도에서 상속분이 있다.’고 규정하고 있는바, 이와 같이 상속분의 산정에서 증여 또는 유증을 참작하게 되는 것은 원칙적으로 상속인이 유증 또는 증여를 받은 경우에만 발생하고, 그 상속인의 직계비속, 배우자, 직계존속이 유증 또는 증여를 받은 경우에는 그 상속인이 반환의무를 지지 않는다. 그러나 예외적으로 증여 또는 유증의 경위, 증여나 유증된 물건의 가치, 성질, 수증자와 관계된 상속인이 실제 받은 이익 등을 고려하여 실질적으로 피상속인으로부터 상속인에게 직접 증여된 것과 다르지 않다고 인정되는 경우에는 상속인의 직계비속, 배우자, 직계존속 등에게 이루어진 증여나 유증도 특별수익으로서 이를 고려할 수 있다는 것이 판례의 태도이다.<sup>233)</sup>

230) 대법원 1996. 08. 20. 선고 96다13682 판결.

231) 대법원 2012. 05. 24. 선고 2010다50809 판결.

232) 부산지방법원 1994. 10. 19. 선고 94나2487 판결 : 확정.

233) 대법원 2007. 08. 28. 자 2006스3 결정(청구인 상대방 3에 대한 자금규모가 다른 자녀에 비하여 과도한 것이었다고 볼 만한 자료도 없고, 망인의 생전의 자산, 수입, 생활수준 등에 비추어 청구인 상대방 3에 대한 증여가 생전의 분재라기보다는 자연적인 애정을 바탕으

공동상속인이 다른 공동상속인에게 무상으로 자신의 상속분을 양도하는 것은 특별한 사정이 없는 한 유류분에 관한 민법 제1008조의 증여에 해당하므로, 그 상속분은 양도인의 사망으로 인한 상속에서 유류분 산정을 위한 기초재산에 포함된다. 위와 같은 법리는 상속 재산 분할협의의 실질적 내용이 어느 공동상속인이 다른 공동상속인에게 자신의 상속분을 무상으로 양도하는 것과 같은 때에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 상속재산 분할협이에 따라 무상으로 양도된 것으로 볼 수 있는 상속분은 양도인의 사망으로 인한 상속에서 유류분 산정을 위한 기초재산에 포함된다.<sup>234)</sup>

### (3) 기여분

기여분은 상속재산 일부로 유류분 산정의 기초재산에 포함되어 있으므로 별도로 더하거나 빼 수 없다.

기여분은 상속재산분할의 전제문제로서의 성격을 갖는 것이므로 상속재산분할의 청구나 조정신청이 있는 경우에 한하여 기여분결정청구를 할 수 있고, 다만 예외적으로 상속재산분할 후에라도 피인지자나 재판의 확정에 의하여 공동상속인이 된 자의 상속분에 상당한 가액의 지급청구가 있는 경우에는 기여분의 결정청구를 할 수 있다고 해석되며, 상속재산분할의 심판청구가 없음에도 단지 유류분반환청구가 있다는 사유만으로는 기여분결정청구가 허용된다고 볼 것은 아니다.<sup>235)</sup>

### (4) 유족급여, 퇴직연금 등

유족급여는 공무원 또는 공무원이었던 자의 사망 당시 그에 의하여 부양되고 있던 유족의 생활보장과 복리향상을 목적으로 하여 민법과는 다른 입장에서 수급권자를 정한 것으로, 수급권자인 유족이나 유족이 아닌 직계비속은 상속인으로서가 아니라 이들 규정에 의하여 직접 자기의 고유의 권리로서 취득하는 것이다.<sup>236)</sup> 따라서 유류분 산정 시 증여나 상속재산으로 가산할 수 없다.

---

로 자녀를 배려한 것이어서, 청구인 상대방 3에 대한 자금지원을 특별수익으로 보지 아니하였고, 망인이 상대방 5에게 용인시 모현면 오산리 (지번 3 생략) 전 641㎡ 및 같은 리 (지번 4 생략) 임야 846㎡를 증여하였거나 위 각 토지의 매수대금이 망인으로부터 나온 사실을 인정할 증거가 없다는 이유로, 위 각 토지에 대한 상대방 5의 특별수익을 인정하지 아니하였다).

234) 대법원 2021. 8. 19. 선고 2017다230338 판결.

235) 대법원 1999. 08. 24. 자 99스28 결정.

236) 대법원 2000. 09. 26. 선고 98다50340 판결.

### (6) 대습상속인의 유류분반환청구권

상속인이 될 직계비속 또는 형제자매가 상속개시 전에 사망하거나 결격자가 된 경우(민법 제1000조제1항제1호 및 제3호)에 그 직계비속이 있는 때에는 그 직계비속이 사망하거나 결격된 사람의 순위에 같음하여 상속인이 되며, 이러한 대습상속인도 유류분반환청구를 할 수 있다(민법 제1118조 및 제1001조).

배우자가 대습상속인인 경우에도 유류분반환청구권을 행사할 수 있다(민법 제1118조 및 제1010조제2항).

사망 또는 결격된 사람에 같음하여 상속인이 된 사람, 즉 대습상속인의 유류분은 사망 또는 결격된 사람의 상속분에 따른다(민법 제1118조 및 제1010조제1항).

사망 또는 결격된 사람의 직계비속이 여러 명인 때(민법 제1010조제1항)에는 그 유류분은 사망 또는 결격된 사람의 상속분의 한도에서 유류분에 따라 이를 정한다(민법 제1118조 및 제1010조제2항).

### (7) 특별수익자의 유류분반환청구권

공동상속인 중에 피상속인으로부터 재산의 증여 또는 유증을 받은 사람이 있는 경우에 그 수증재산이 자기의 상속분에 달하지 못한 때에는 그 부족한 부분의 한도에서 상속분이 있고, 유류분청구권도 있다(민법 제1118조 및 제1008조).

## 라. 채무전액의 공제

여기서 채무는 상속채무를 말하며, 상속채무는 유류분액의 산정에서 공제한다. 상속채무는 사법상의 채무(상속인이 부담하는 채무)와 공법상 채무(세금, 벌금, 과태료 등)를 말한다. 다만, 상속에 관한 비용(상속세, 관리비, 소송비용등)이나 유언집행에 관한 비용(검인신청비용, 재산목록 작성비용 등)은 어차피 상속재산 중에서 지급되어야 하므로 여기서 공제할 필요가 없다.<sup>237)</sup>

유류분 가액의 산정에 있어 상속부동산에 대한 월 임대료 수익은 그 부동산의 상속 당시 시가인 교환가격에 포함되어 있으므로 별도의 상속재산이라 할 수 없고, 상속세, 등기 비용, 장례비 등은 유증자 사망 후에 지출된 비용으로서 상속개시 시의 재산에서 이를

237) 김주수·김상용, 앞의 책, 742면; 박병호, 앞의 책, 477면; 이경희, 앞의 책, 582면; 반대설은 모두 채무에 포함된다고 한다[곽윤직, 앞의 책(상속법), 286면; 송덕수, 앞의 책, 1976면].



공제할 성질의 것이 아니다.<sup>238)</sup>

한편 판례는 유류분 산정시 공제되어야 할 채무의 범위와 관련하여 채무에 상속세, 상속 재산의 관리·보존을 위한 소송비용 등 상속재산에 관한 비용이 포함되는지 여부가 문제된 사안에서, 공제되어야 할 채무란 상속채무, 즉 피상속인의 채무를 가리키는 것이고, 여기에 상속세, 상속재산의 관리·보존을 위한 소송비용 등 상속재산에 관한 비용은 포함되지 아니한다고 판시하였다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2012다21720 판결).

## 마. 유류분액의 계산

### (1) 계산식

증여재산과 상속채무가 있는 경우에 유류분액의 계산액은 앞서 설명한 것들을 식으로 표시하면 다음과 같다.

$$\text{유류분액} = (\text{적극상속재산액} + \text{증여액} - \text{상속채무액}) \times (\text{해당상속인의 유류분액}) - (\text{해당상속인의 수증액})$$

여기서 ‘해당상속인의 수증액’이란 피상속인으로부터 생전증여나 유증이다.

예컨대 자수성가로 큰 부를 축적한 甲은 사망하기 2년 전에 출가한 딸 乙에게 10억 원을 사망하기 1년 2개월 전에 A양로원에 14억 원, 사망하기 6개월 전에 B재활원에 10억 원을 각각 증여하였다. 그리고 총재산 90억 원을 남기면서 사망할 때에 이를 Y대학의 발전 기금으로 기탁한다는 유언을 하였다. 그런데 甲의 사후 甲에게는 X은행에 부채가 47억 원이 있는 것으로 판명되었다. 甲의 처 丙과 자 丁이 유류분 청구를 하였을 경우 상속재산 중에서 丙과 丁에게 귀속되는 금액은 각각 얼마나 되는가?(乙, 丙, 丁 이외에 다른 상속인은 없는 것으로 전제함.)

위 사례에서 유류분의 산정의 기초가 되는 재산은 상속개시 시에 가진 재산의 가액 90억 원에 증여재산의 가액(乙 10억, B재활원 10억 원을 포함하며, A양로원 14억 원은 사망하기 1년 2개월 전의 증여이므로 포함되지 않는다)을 가산하고 채무잔액 47억 원을 공제하면 63억 원이 된다. 丙의 유류분은  $63억 \times \frac{3}{7} \times \frac{1}{2} = 13억 5천만 원$ , 丁의 유류분은  $63억 \times \frac{2}{7} \times \frac{1}{2} = 9억 원$ 이다.

238) 창원지방법원 1992. 09. 25. 선고 90가합9001 판결 : 항소.

## (2) 유류분권리자의 유류분 부족액 산정 방법

가) 유류분권리자의 유류분 부족액은 유류분액에서 특별수익액과 순상속분액을 공제하는 방법으로 산정하는데, 피상속인이 상속개시 시에 채무를 부담하고 있던 경우 유류분액은 민법 제1113조 제1항에 따라 피상속인이 상속개시 시에 가진 재산의 가액에 증여재산의 가액을 가산하고 채무의 전액을 공제하여 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 확정한다. 거기에 민법 제1112조에서 정한 유류분 비율을 곱하여 산정한다. 그리고 유류분액에서 공제할 순상속분액은 특별수익을 고려한 구체적인 상속분에서 유류분권리자가 부담하는 상속채무를 공제하여 산정하고, 이때 유류분권리자의 구체적인 상속분보다 유류분권리자가 부담하는 상속채무가 더 많다면 그 초과분을 유류분액에 가산하여 유류분 부족액을 산정하여야 한다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2017다265884 판결).

유언자가 자신의 재산 전부 또는 전 재산의 비율적 일부가 아니라 일부 재산을 특정하여 유증한 특정유증의 경우에는, 유증 목적인 재산은 일단 상속재산으로서 상속인에게 귀속되고 유증을 받은 자는 유증의무자에 대하여 유증을 이행할 것을 청구할 수 있는 채권을 취득하게 된다. 유언자가 임차권 또는 근저당권이 설정된 목적물을 특정유증하면서 유증을 받은 자가 그 임대차보증금반환채무 또는 피담보채무를 인수할 것을 부담으로 정한 경우에도 상속인이 상속개시 시에 유증 목적물과 그에 관한 임대차보증금반환채무 또는 피담보채무를 상속하므로 이를 전제로 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 확정하여 유류분액을 산정하여야 한다. 이 경우 상속인은 유증을 이행할 의무를 부담함과 동시에 유증을 받은 자에게 유증 목적물에 관한 임대차보증금반환채무 등을 인수할 것을 요구할 수 있는 이익 또한 얻었다고 할 수 있으므로, 결국 그 특정유증으로 인해 유류분권리자가 얻은 순상속분액은 없다고 보아 유류분 부족액을 산정하여야 한다. 나아가 위와 같은 경우에 특정유증을 받은 자가 유증 목적물에 관한 임대차보증금반환채무 또는 피담보채무를 임차인 또는 근저당권자에게 변제하였다고 하더라도 상속인에 대한 관계에서는 자신의 채무 또는 장차 인수하여야 할 채무를 변제한 것이므로 상속인에 대하여 구상권을 행사할 수 없다고 봄이 타당하다. 위와 같은 법리는 유증 목적물에 관한 임대차계약에 대항력이 있는지 여부와 무관하게 적용된다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2017다265884 판결).

나) 유류분 제도가 생기기 전에 피상속인이 상속인이나 제3자에게 재산을 증여하고 이행을 완료하여 소유권이 수증자에게 이전된 때에는 피상속인이 1977. 12. 31. 법률 제3051호로 개정된 민법(이하 ‘개정 민법’이라 한다) 시행 이후에 사망하여 상속이 개시되더라도 소급하여 증여재산이 유류분 제도에 의한 반환청구의 대상이 되지는 않는다. 개정

민법의 유류분 규정을 개정 민법 시행 전에 이루어지고 이행이 완료된 증여에까지 적용한다면 수증자의 기득권을 소급입법에 의하여 제한 또는 침해하는 것이 되어 개정 민법 부칙 제2항의 취지에 반하기 때문이다. 개정 민법 시행 전에 이미 법률관계가 확정된 증여재산에 대한 권리관계는 유류분 반환청구자이든 반환의무자이든 동일하여야 하므로, 유류분 반환청구자가 개정 민법 시행 전에 피상속인으로부터 증여받아 이미 이행이 완료된 경우에는 그 재산 역시 유류분산정을 위한 기초재산에 포함되지 아니한다고 보는 것이 타당하다.

그러나 유류분 제도의 취지는 법정상속인의 상속권을 보장하고 상속인 간의 공평을 기하기 위함이고, 민법 제1115조 제1항에서도 ‘유류분권리자가 피상속인의 증여 및 유증으로 인하여 그 유류분에 부족이 생긴 때에는 부족한 한도 내에서 그 재산의 반환을 청구할 수 있다’고 규정하여 이미 법정 유류분 이상을 특별수익한 공동상속인의 유류분 반환청구권을 부정하고 있다. 이는 개정 민법 시행 전에 증여받은 재산이 법정 유류분을 초과한 경우에도 마찬가지로 보아야 하므로, 개정 민법 시행 전에 증여를 받았다는 이유만으로 이를 특별수익으로도 고려하지 않는 것은 유류분 제도의 취지와 목적에 반한다고 할 것이다. 또한 민법 제1118조에서 제1008조를 준용하고 있는 이상 유류분 부족액 산정을 위한 특별수익에는 그 시기의 제한이 없고, 민법 제1008조는 유류분 제도 신설 이전에 존재하던 규정으로 민법 부칙 제2조와도 관련이 없다.

따라서 개정 민법 시행 전에 이행이 완료된 증여 재산이 유류분 산정을 위한 기초재산에서 제외된다고 하더라도, 위 재산은 당해 유류분 반환청구자의 유류분 부족액 산정 시 특별수익으로 공제되어야 한다(대법원 2018. 7. 12. 선고 2017다278422 판결).

### (3) 구체적 사례

#### (가) 유류분의 침해가 없는 경우

##### [신분관계]

소외 1은 1933. 3. 7. 소외 2와 혼인하여, 그 사이에 소외 3, 피고 1, 원고 1, 소외 4, 5, 6, 원고 2등 7명의 자녀들을 두었는데, 자녀들 중 소외 3은 1980. 2. 26.에, 소외 5는 1981. 10. 18.에, 남편인 소외 2는 1988. 8. 7. 각 사망하였다. 소외 5의 사망 당시 유족으로는 처인 소외 7과 딸인 피고 2가 있었는데, 소외 7은 이후 소외 1이 사망하기 전 재혼하여 소외 5의 처로서의 신분을 상실함으로써 소외 1의 대습상속인이 될 수 없게 되었고, 소외 3은 1977. 8. 13. 남편이었던 소외 8과 이혼한 이후 직계비속이 없는 상태에서 사망하였다. 소외 1(이하 ‘망인’이라 한다)은 2002.

9. 24. 사망하였는데, 이에 따라 원고 1, 2, 피고 1, 2, 소외 4, 6이 각 6분의 1의 상속지분만큼 망인의 재산을 공동 상속하였다.

[증 여]

망인은 1993. 9.경 원고들 및 소외 4, 6에게 각 1억 원씩 모두 4억 원을, 2002. 1. 18.경 원고들에게 각 3,000만 원씩을, 2002. 8. 30.경에는 피고 2에게 1억 7,400만 원을 증여하였다.

[유류분 산정의 기초재산(A)]

유류분 산정의 기초재산을 계산해 보면, 망인이 1993. 9.경 원고들 및 소외 4, 6에게 증여한 4억 원, 2002. 1. 18.경 원고들에게 증여한 6,000만 원, 2002. 8. 30.경 피고 2에게 증여한 1억 7,400만 원을 합산한 증여액 합계 6억 3,400만 원(= 4억 원 + 6,000만 원 + 1억 7,400만 원)이 이에 해당된다.

[원고들의 각 유류분 비율(B)]

피상속인의 직계비속의 유류분은 그 법정상속분의 1/2이므로 원고들의 각 유류분 비율(B)은  $1/12 (= 1/6 \times 1/2)$ 이다.

[원고들의 각 특별수익분(C)]

각 1억 3,000만 원(= 1억 원 + 3,000만 원)

[원고들의 각 순 상속분(D)]

없음

[원고들의 각 유류분 부족액의 계산]

원고들의 각 유류분 부족액 = (-) 77,166,666원 {=(유류분 산정의 기초가 되는 재산액 6억 3,400만 원  $\times$  원고들의 각 유류분의 비율  $1/12$ ) - 원고들의 각 특별수익분 1억 3,000만 원}

## (나) 유류분침해가 있는 경우

## [신분관계]

망 소외인은 1948. 9. 3. 원고 1과 혼인하여 자녀로 원고 2, 3을 두었고, 1953. 3. 5. 피고 2와 다시 혼인하여 자녀로 피고 1과 소외인을 두었다. 망 소외인은 1996. 5. 16. 사망하였다.

## [상속분]

중혼 배우자라 하더라도 그 상속인 지위에는 영향이 없으므로, 당사자들의 상속분은 배우자인 원고 1과 중혼 배우자인 피고 2는 각  $3/14$ , 자녀들인 원고 2, 3, 피고 1과 소외인은 각  $2/14$ 이다.

## [신분관계]

망 소외인은 1948. 9. 3. 원고 1과 혼인하여 자녀로 원고 2, 3을 두었고, 1953. 3. 5. 피고 2와 다시 혼인하여 자녀로 피고 1과 소외인을 두었다.

망 소외인은 1996. 5. 16. 사망하였다.

## [상속분]

중혼 배우자라 하더라도 그 상속인 지위에는 영향이 없으므로, 당사자들의 상속분은 배우자인 원고 1과 중혼 배우자인 피고 2는 각  $3/14$ , 자녀들인 원고 2, 3, 피고 1과 소외인은 각  $2/14$ 이다.

## [유류분 산정의 기초가 되는 재산의 가액]

피고 1이 생전에 증여받은 재산 가액 합계 656,234,230원( $1,152,294,000 \times 1/2 + 139,717,660 \times 1/2 + 20,456,800 \times 1/2$ )과 상속 개시 당시 재산인 위 아파트 480,000,000원을 합한 1,136,234,230원이다.

## [원고들의 유류분]

원고 1은 121,739,381원( $= 1,136,234,230 \times 3/14 \times 1/2$ ), 원고 2와 3은 각 81,159,587원( $= 1,136,234,230 \times 2/14 \times 1/2$ )이다.

## [실제 원고들의 상속분]

상속 개시 당시 상속 재산으로 별지 제4 목록 기재 아파트가 있었고, 1996. 5. 16. 당시 시가는 480,000,000원이었다.

원고 1 :  $480,000,000 \times 3/12 = 120,000,000$ 원

원고 2, 3 : 각  $480,000,000 \times 2/12 = 80,000,000$ 원

## [유류분 침해]

위 각 유류분 가액에서 상속개시당시 재산 가액을 뺀 것이 유류분 부족분이다.

원고 1은 1,739,381원(=121,739,381-120,000,000), 원고 2, 3은 각 1,159,587원(=81,159,587-80,000,000) 만큼 유류분이 침해되었다.

## 바. 반환의 대상이 되는 증여와 유증이 있을 경우 반환의 순서

증여에 대하여는 유증을 반환 받은 후가 아니면 반환청구를 할 수 없다(민법 제1116조). 즉, 증여와 유증이 있는 경우에 유증에 대하여 먼저 반환을 받아야 하고, 그것으로써 유류분권이 보전되지 않을 때에는 증여의 반환을 청구할 수 있다(유증→사인증여→생전증여).

유류분반환청구의 목적인 증여나 유증이 병존하고 있는 경우에는 유류분권리자는 먼저 유증을 받은 자를 상대로 유류분침해액의 반환을 구하여야 하고, 그 이후에도 여전히 유류분침해액이 남아 있는 경우에 한하여 증여를 받은 자에 대하여 그 부족분을 청구할 수 있는 것이며, 사인증여의 경우에는 유증의 규정이 준용될 뿐만 아니라 그 실제적 기능도 유증과 달리 볼 필요가 없으므로 유증과 같이 보아야 할 것이다.<sup>239)</sup>

## 5. 유류분의 침해

## 가. 의 의

망인(피상속인)이 그의 재산에 관하여 증여 또는 유증을 한 결과 유류분권자인 상속인이 받을 상속재산의 가액이 유류분액에 미달하는 경우가 유류분의 침해이다.

민법 제1115조 제1항에서는 유류분권리자가 피상속인의 증여 및 유증으로 인하여 그 유류분에 부족이 생긴 때에는 부족한 한도에서 그 재산의 반환을 청구할 수 있다고 하여 유류분을 침해하는 망인의 처분행위는 그대로 유효한 것으로 되고 유류분을 침해하는 한도

239) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001다6947 판결.

에서 상속인은 재산의 반환청구권(유류분반환청구권)만을 인정하고 있다.

유언자가 부담부 유증을 하였는지는 유언에 사용한 문언 및 그 외 제반 사정을 종합적으로 고려하여 탐구된 유언자의 의사에 따라 결정되어야 하는데, 유언자가 임차권 또는 근저당권이 설정된 목적물을 특정유증하였다면 특별한 사정이 없는 한 유증을 받은 자가 그 임대보증금반환채무 또는 피담보채무를 인수할 것을 부담으로 정하여 유증하였다고 볼 수 있다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2017다265884 판결).

### 나. 유류분침해액의 산정

그러나 유류분율만으로는 유류분이 구체적으로 얼마나 침해되어 있는지, 부족액이 어느 정도인지 정확히 알 수 없다.

유류분의 부족액은 유류분권리자가 상속에 의해서 실제로 취득한 재산액이 유류분액에 미달한 경우이다. 따라서 아래와 같은 식으로 계산을 하면 실제로 유류분액의 부족액이 어느 정도 인지 알 수 있다.

유류분의 부족액 = 유류분액 - 상속인의 순상속액

유류분액 = (적극재산액 + 증여액 - 상속채무액) × (상속인의 유류분액) - (상속인의 수증액)

상속인의 순상속액 = (적극상속재산액 × 상속분율) - (상속채무액 × 상속분율)

유류분침해액의 산정기준이 되는 상속액은 피상속인의 적극재산, 소극재산 및 특별수익분을 포함하여 공동상속인들이 피상속인의 사망으로 인하여 받게 되는 구체적 이익이라고 보아야 한다.<sup>240)</sup>

### 다. 심 리

유류분액 및 그 침해액을 산정하기 위해서는 유류분 산정의 기초가 되는 전 재산의 가액에 대한 심리가 전제되어야 한다는 점에서 유류분반환청구소송에서 당사자가 새로운 증여재산을 추가하여 청구취지를 확장하자마자 그 가액에 대한 입증 기회도 부여하지 아니한 채 바로 변론을 종결한 원심은 심리미진의 위법이 있다.<sup>241)</sup>

240) 서울북부지방법원 1999. 01. 27. 선고 96가단37296, 46863 판결: 항소·상고기각.

241) 대법원 2002. 04. 26. 선고 2000다8878 판결.

### 제3관 유류분반환청구

(민사사건)

#### 1. 의 의

##### 가. 민사사건이다

반환청구는 재판상 또는 재판외의 방법으로 할 수 있으며(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000다8878 판결), 재판상의 방법으로 하는 경우에는 민사소송절차에 따라 진행된다.

현행 가사소송법이 이를 가사사건으로 열거하지 아니하므로 가사사건이 아닌 민사사건이다. 문제는 유류분반환청구의 상대방이 공동상속인 중의 1인이거나 수인이고, 그 반환청구가 상속재산분할의 전제로서 주장되는 경우이다. 이는 상속재산분할은 마류 가사비송사건이고 유류분반환청구권의 유무 및 범위에 관한 판단을 전제로 하지 않고서는 상속재산의 범위는 물론 그 분할 방법도 결정하기 어렵기 때문이다. 통설은 유류분반환청구권을 청구권이 아닌 형성권으로 파악하고 그 행사의 방법에도 제한이 없다고 보는 점에 비추어 당사자가 명백히 상속재산분할과는 별개의 청구로서 유류분반환을 구하는 경우에는 그 부분을 분리하여 지방법원으로 이송하고 그 판결결과를 기다려 상속재산분할의 심판을 할 것이고, 단순히 상속재산분할심판절차 내에서의 공격방어방법으로 주장함에 그치는 경우에는 그 심판 절차 내에서의 유류분반환청구의 당부를 가려 상속재산분할의 처분을 할 수 있다.<sup>242)</sup>

하급심 판례<sup>243)</sup>에서 “유류분반환청구는 원칙적으로 민사소송의 대상이나, 유증 등으로 인한 유류분 침해자가 재산상속인이고 유류분 권리자가 그 권리를 행사하였다면 재산상속인들 사이의 상속재산분할에 영향을 미치게 되므로 유류분반환청구의 구체적 실현은 가사비송사건인 상속재산분할절차와 함께 이루어져야 한다.”고 한다. 실제로 주청구로 상속재산분할청구를 하고, 예비적으로 유류분 반환청구를 하는 경우가 많다. 따라서 가정법원이 처리함이 타당하다고 사료된다.

##### 나. 반환의 순서

유증을 반환받은 후가 아니면 수증자가 증여받은 것을 청구할 수 없다(민법 제1116조). 유류분 반환순서에 있어서 사인증여의 경우에는 유증의 규정이 준용될 뿐만 아니라 그

242) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅰ)], 25~26면.

243) 서울가정법원 1994. 04. 21. 자 92ㄴ7359 심판: 항고.



실제적 기능도 유증과 달리 볼 필요가 없으므로 유증과 같이 본다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001다6947 판결).

## 라. 유류분반환의 범위

유류분반환의 범위는 상속개시 당시 피상속인의 순재산과 문제 된 증여재산을 합한 재산을 평가하여 그 재산액에 유류분청구권자의 유류분비율을 곱하여 얻은 유류분액을 기준으로 산정하는데, 증여받은 재산의 시가는 상속개시 당시를 기준으로 산정해야 한다.

어느 공동상속인 1인이 특별수익으로서 여러 부동산을 증여받아 그 증여재산으로 유류분권리자에게 유류분 부족액을 반환하는 경우 반환해야 할 증여재산의 범위는 특별한 사정이 없는 한 민법 제1115조 제2항을 유추적용하여 증여재산의 가액에 비례하여 안분하는 방법으로 정함이 타당하다. 따라서 유류분반환 의무자는 증여받은 모든 부동산에 대하여 각각 일정 지분을 반환해야 하는데, 그 지분은 모두 증여재산의 상속개시 당시 총가액에 대한 유류분 부족액의 비율이 된다.

다만 증여 이후 수증자나 수증자로부터 증여재산을 양수받은 사람이 자기의 비용으로 증여재산의 성상(성상) 등을 변경하여 상속개시 당시 그 가액이 증가되어 있는 경우, 유류분 부족액을 산정할 때 기준이 되는 증여재산의 가액에 관해서는 위와 같이 변경된 성상 등을 기준으로 증여재산의 상속개시 당시 가액을 산정하면 유류분권리자에게 부당한 이익을 주게 되므로, 그와 같은 변경이 있기 전 증여 당시의 성상 등을 기준으로 상속개시 당시 가액을 산정해야 한다.

반면 유류분 부족액 확정 후 증여재산별로 반환 지분을 산정할 때 기준이 되는 증여재산의 총가액에 관해서는 상속개시 당시의 성상 등을 기준으로 상속개시 당시의 가액을 산정함이 타당하다. 이 단계에서는 현재 존재하는 증여재산에 관한 반환 지분의 범위를 정하는 것이므로 이와 같이 산정하지 않을 경우 유류분권리자에게 증여재산 중 성상 등이 변경된 부분까지도 반환되는 셈이 되어 유류분권리자에게 부당한 이익을 주게 되기 때문이다(대법원 2022. 2. 10. 선고 2020다250783 판결).

## 다. 반환의 방법

### (1) 유류분의 통상적 반환방법(=원물반환)

민법은 유류분의 반환방법에 관하여 별도의 규정을 두고 있지 않다. 그러나 증여 또는 유증대상 재산 그 자체를 반환하는 것이 통상적인 반환방법이므로, 유류분권리자가 원물반

환의 방법으로 유류분반환을 청구하고 그와 같은 원물반환이 가능하다면 특별한 사정이 없는 한 법원은 유류분권리자가 청구하는 방법에 따라 원물반환을 명하여야 한다.

증여나 유증 후 그 목적물에 관하여 제3자가 저당권이나 지상권 등의 권리를 취득한 경우에는 원물반환이 불가능하거나 현저히 곤란하므로, 반환의무자가 목적물을 저당권 등의 제한이 없는 상태로 회복하여 이전해 줄 수 있다는 등의 예외적인 사정이 없는 한 유류분권리자는 반환의무자를 상대로 원물반환 대신 그 가액의 반환을 구할 수 있다. 그러나 그렇다고 해서 유류분권리자가 스스로 위험이나 불이익을 감수하면서 원물반환을 구하는 것까지 허용되지 않는다고 볼 것은 아니므로, 그 경우에도 법원은 유류분권리자가 청구하는 방법에 따라 원물반환을 명하여야 한다(대법원 2022. 2. 10. 선고 2020다250783 판결).

유류분을 반환청구하는 경우에 증여를 받은 사람이 여러 명인 때에는 각자가 얻은 증여가액의 비례로 반환해야 한다(민법 제1115조제2항).

#### [사 례]

피상속인의 상속재산을 유증받은 A(유증가액 1000만원)와 사전증여받은 B(수증가액 1500만원)와 C(수증가액 1500만원)가 있으며, 유류분권리자가 총 1500만원의 유류분액을 침해받은 경우의 반환방법

위의 경우에 유류분권리자는 먼저 유증을 받은 사람을 상대로 유류분침해액의 반환을 구하여야 하고, 그 이후에도 여전히 유류분침해액이 남아 있는 경우에 한하여 증여를 받은 사람에 대하여 그 부족분을 청구할 수 있는 것이므로 A에게 A의 유증가액 1000만원을 먼저 청구해야 한다(민법 제1116조, 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001다6947 판결).

이때 나머지 500만원의 부족분은 B와 C가 수증가액에 비례해서 반환의무를 지게 되므로(민법 제1115조제2항), B와 C에게 각각 250만원( $500\text{만원} \times 1/2$ )씩의 반환을 청구할 수 있다. 즉, 유류분권리자는 먼저 A에게 1000만원을 청구하고, B와 C에게 250만원을 청구할 수 있다. 만약 유류분청구 당시 유증이 이행되지 않았다면 상속재산관리인에게 1000만원을 청구하면 된다.

#### (2) 사인증여의 경우

유류분반환청구의 목적인 증여나 유증이 병존하고 있는 경우에는 유류분권리자는 먼저 유증을 받은 자를 상대로 유류분침해액의 반환을 구하여야 하고, 그 이후에도 여전히 유류분침해액이 남아 있는 경우에 한하여 증여를 받은 자에 대하여 그 부족분을 청구할 수 있는 것이며, 사인증여의 경우에는 유증의 규정이 준용될 뿐만 아니라 그 실제적 기능도

유증과 달리 볼 필요가 없으므로 유증과 같이 보아야 할 것이다.<sup>244)</sup>

### (3) 유류분 보전을 원인으로 한 재산반환청구가 필요적 공동소송인지 여부

유류분 보전을 원인으로 한 재산반환청구가 필요적 공동소송인지 여부에 대하여 유류분 보전을 원인으로 한 재산반환청구는 상속인 전원이 공동으로 당사자가 되어야 하는 필요적 공동소송이라고 볼 수 없다.<sup>245)</sup>

### (4) 유류분반환권청구권의 행사가 신의성실의 원칙에 반한다고 본 사례

유류분반환청구권 행사에 관하여는 단기소멸시효 외에는 그것을 제한하는 규정은 없지만 신의칙이나 권리남용금지의 법리가 적용된다.

모가 8년간이나 투병생활을 하는 동안 자식으로서의 의무를 저버리고 오로지 다른 형제 1인에게만 병간호 등 모든 것을 부담시키다가 모가 사망하자, 그 형제가 이미 10년 전에 증여받은 모의 재산에 관하여 분배를 요구하면서 유류분반환청구권을 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 위반되어 허용될 수 없다.<sup>246)</sup>

## 2. 유류분반환청구권의 성질

### 가. 형성권설

다수설인 이 설에 의하면 반환청구권을 행사하면 유증 또는 증여계약은 실효하고 유류분 권리자는 물권적청구권에 기하여 목적물반환을 청구할 수 있으며 그 유증 또는 증여가 아직 이행되지 않았을 때에는 반환청구권자는 이행의 의무를 면하며, 이미 이행되었을 때에는 반환을 청구할 수 있다고 한다.<sup>247)</sup>

### 나. 청구권설

청구권설은 유류분반환청구권을 행사하면 유증·증여는 유류분을 침해한 한도에서 당연히 반환청구를 한 유류분권리자에게 귀속한다. 즉, 유류분에 부족한 만큼의 재산의 인도나 반환을 유증 받은 자나 증여받은 자에 대하여 요구하는 채권적 청구권이며 아직 이행하지 않는 증여나 유증에 있어서는 이행의무의 소멸을 청구하고 이행을 거절할 수 있을 뿐이

244) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001다6947 판결.

245) 부산고등법원 1991. 01. 23. 선고 90나3188 제2부판결: 확정.

246) 부산지방법원 동부지원 1993. 06. 17. 선고 92가합4498 제1민사부판결: 확정.

247) 김주수·김상용, 앞의 책, 743면; 박병호, 앞의 책, 480면.

라고 한다.<sup>248)</sup>

## 다. 판례

판례의 입장은 명확하지 않다. 하급심판례<sup>249)</sup>는 “형성권인 유류분반환청구권의 성질상 그 반환청구권의 행사에 의하여 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 산입되는 재산의 증여나 유증은 유류분을 침해하는 한도에서 당연히 실효되고 증여나 유증을 받을 자의 권리는 그 한도에서 유류분권리자에게 귀속되나, 그와 같은 유류분권을 침해하는 범위는 상속인들의 유류분, 그 산정의 기초가 되는 재산, 유류분액과 구체적인 상속이익 등을 따져 보아야 하는 것으로 특정재산의 일정 부분(유류분율)이 바로 유류분반환청구권의 대상이 되는 것은 아니다.”라고 판시하고 있다. 또한 대법원 2000다8878에 따르면 형성권설에 따른다고 할 수 있다.

반면 “민법 제1117조의 규정내용 및 형식에 비추어 볼 때 같은 법조 전단의 1년의 기간은 물론 같은 법조 후단의 10년의 기간도 그 성질은 소멸시효기간이다.”라는 판례<sup>250)</sup>를 보면 청구권설에 가깝다.

## 라. 검토

형성권설에 의하면 부동산의 경우 거래의 안전을 해친다는 점, 법적근거가 없다는 점을 고려하면 다소 유류분권리자의 보호에 미흡한 점이 있는 청구권설이 우리 민법상 더 타당하다고 본다.

## 3. 유류분 반환청구절차

### 가. 유류분반환청구권 행사의 방법

#### (1) 일반적인 경우

유류분권리자가 피상속인의 증여 및 유증으로 인하여 그 유류분에 부족이 생긴 때에는 부족한 한도에서 그 재산의 반환을 청구할 수 있다(민법 제1115조제1항).

유류분반환청구권의 행사는 재판상 또는 재판 외에서 상대방(수유자나 수증자 등)에 대한 의사표시로 한다. 즉, 상대방 있는 단독행위라고 보아야 할 것이다.

248) 박윤직, 앞의 책(상속법), 294면; 이경희, 앞의 책, 590면; 송덕수, 앞의 책, 1977면.

249) 서울북부지방법원 1999. 01. 27. 선고 96가단37296, 46863 판결: 항소·상고기각.

250) 대법원 1993. 04. 13. 선고 92다3595 판결.

유류분반환청구의 의사표시는 침해를 받은 유증 또는 증여행위를 지정하여 이에 대한 반환청구의 의사를 표시하면 그것으로 족하고 그로 인하여 생긴 목적물의 이전등기청구권이나 인도청구권 등을 행사하는 것과는 달리 그 목적물을 구체적으로 특정하여야 하는 것은 아니다.<sup>251)</sup>

원고들이 공동으로 상속한 재산을 피고가 매수한 사실이 없음에도 불구하고 이를 매수한 것처럼 관계서류를 위조하여 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였으니 이는 원인무효의 등기로서 말소되어야 한다는 내용의 주장 속에는 유류분반환의 의사표시까지 포함되어 있다고 볼 수 없다.<sup>252)</sup>

## (2) 유류분권리자가 복수인 경우

각 유류분권리자의 반환청구권은 각각 독립된 별개의 권리이므로 각각 행사하여야 하며, 한 사람이 자기의 반환청구권을 행사하여도 다른 권리자에게는 아무런 영향이 없다.

## (3) 조건부권리 등의 일부에 대한 경우

조건부권리나 존속기간이 불확정한 권리가 증여 또는 유증의 목적으로 되고 그 일부에 대하여 유류분권리자가 유류분반환청구를 한 경우에는 민법 제1113조 제2항의 규정을 유추적용함에 가정법원이 선임한 감정인이 평가한 가격에 의하여 반환을 청구할 수 있다.

## (4) 유류분반환청구권과 채권자대위권·채권자취소권

민법은 유류분을 침해하는 피상속인의 유증 또는 증여에 대하여 일단 그 의사대로 효력을 발생시킴으로써 피상속인의 재산처분에 관한 자유를 우선적으로 존중해 주는 한편 유류분반환청구권을 행사하여 그 침해된 유류분을 회복할 것인지 여부를 유류분권리자의 선택에 맡기고 있고, 이 경우 유류분권리자는 피상속인의 의사나 피상속인과의 관계는 물론 수증자나 다른 상속인과의 관계 등도 종합적으로 고려하여 유류분반환청구권의 행사 여부를 결정하게 된다. 따라서 유류분반환청구권은 그 행사 여부가 유류분권리자의 인격적 이익을 위하여 그의 자유로운 의사결정에 전적으로 맡겨진 권리로서 행사상의 일신전속성을 가진다고 보아야 하므로, 유류분권리자에게 그 권리행사의 확정적 의사가 있다고 인정되는 경우가 아니라면 원칙적으로 채권자대위권의 목적이 될 수 없다고 한다.<sup>253)</sup> 그러나

251) 대법원 2001. 09. 14. 선고 2000다66430, 66447 판결; 대법원 2002. 4. 26. 선고 2000다8878 판결.

252) 서울고등법원 1989. 11. 24. 선고 88나40636 판결 : 확정.

253) 대법원 2010. 05. 27. 선고 2009다93992 판결.

확설은 대체적으로 유류분반환청구권을 대위행사 할 수 있다고 한다.

한편, 망인의 과도한 증여나 유증 등 처분행위가 사해행위에 해당 될 때 상속채권자가 채권자취소권을 행사할 수 있음은 물론이다. 그리고 상속인의 유류분 포기에 대해 사해행위에 해당되는가는 견해의 대립이 있으나 상속포기처럼 사해행위가 아니라는 견해<sup>254)</sup>가 타당하다. 최근 하급심 판례<sup>255)</sup>에서 상속포기는 채권자취소의 대상이 될 수 없다고 하였다.

**(5) 증여가 유류분권리자에게 손해를 가할 것을 알고 행해진 것이라고 보기 위한 요건과 그 판단의 기준 시기(=증여 당시) 및 이에 관한 증명책임의 소재(=유류분반환청구권을 행사하는 상속인)**

공동상속인이 아닌 제3자에 대한 증여는 원칙적으로 상속개시 전의 1년간에 행한 것에 한하여 유류분반환청구를 할 수 있고, 다만 당사자 쌍방이 증여 당시에 유류분권리자에게 손해를 가할 것을 알고 증여를 한 때에는 상속개시 1년 전에 한 것에 대하여도 유류분반환청구가 허용된다(민법 제1114조). 증여 당시 법정상속분의 2분의 1을 유류분으로 갖는 배우자나 직계비속이 공동상속인으로서 유류분권리자가 되리라고 예상할 수 있는 경우에, 제3자에 대한 증여가 유류분권리자에게 손해를 가할 것을 알고 행해진 것이라고 보기 위해서는, 당사자 쌍방이 증여 당시 증여재산의 가액이 증여하고 남은 재산의 가액을 초과한다는 점을 알았던 사정뿐만 아니라, 장래 상속개시일에 이르기까지 피상속인의 재산이 증가하지 않으리라는 점까지 예견하고 증여를 행한 사정이 인정되어야 하고, 이러한 당사자 쌍방의 가해의 인식은 증여 당시를 기준으로 판단하여야 하는데, 그 증명책임은 유류분반환청구권을 행사하는 상속인에게 있다(대법원 2022. 8. 11. 선고 2020다247428 판결).

**(6) 제3자에게 유류분 산정의 기초재산에 포함되는 증여를 한 것으로 보기 위한 요건 및 이때 유류분 산정의 기초재산에 포함되는 증여 가액을 이미 납입한 보험료 총액 중 피상속인이 납입한 보험료가 차지하는 비율을 보험금액에 곱하여 산출한 금액으로 할 수 있는지 여부(원칙적 적극)**

피상속인이 자신을 피보험자로 하되 공동상속인이 아닌 제3자를 보험수익자로 지정한 생명보험계약을 체결하거나 중간에 제3자로 보험수익자를 변경하고 보험회사에 보험료를

254) 박동섭, 앞의 책(친족상속법), 787면; 김능한, “유류분반환청구”, 법원행정처, 1998, 68면.

255) 서울중앙지방법원 2008. 10. 10. 선고 2007가단433075 판결: 확정.

납입하다 사망하여 그 제3자가 생명보험금을 수령하는 경우, 피상속인은 보험수익자인 제3자에게 유류분 산정의 기초재산에 포함되는 증여를 하였다고 봄이 타당하다. 또한 공동 상속인이 아닌 제3자에 대한 증여이므로 민법 제1114조에 따라 보험수익자를 그 제3자로 지정 또는 변경한 것이 상속개시 전 1년간에 이루어졌거나 당사자 쌍방이 그 당시 유류분권리자에 손해를 가할 것을 알고 이루어졌어야 유류분 산정의 기초재산에 포함되는 증여가 있었다고 볼 수 있다. 이때 유류분 산정의 기초재산에 포함되는 증여 가액은 피상속인이 보험수익자 지정 또는 변경과 보험료 납입을 통해 의도한 목적, 제3자가 보험수익자로서 얻은 실질적 이익 등을 고려할 때, 특별한 사정이 없으면 이미 납입된 보험료 총액 중 피상속인이 납입한 보험료가 차지하는 비율을 산정하여 이를 보험금액에 곱하여 산출한 금액으로 할 수 있다(대법원 2022. 8. 11. 선고 2020다247428 판결).

#### (7) 유류분 부족액을 산정할 때 유류분액에서 공제하여야 하는 순상속분액을 산정하는 방법

유류분권리자가 반환을 청구할 수 있는 ‘유류분 부족액’은 ‘유류분액’에서 유류분권리자가 받은 특별수익액과 순상속분액을 공제하는 방법으로 산정하는데, 유류분액에서 공제할 순상속분액은 특별수익을 고려한 구체적인 상속분에서 유류분권리자가 부담하는 상속채무를 공제하여 산정한다. 이처럼 유류분액에서 순상속분액을 공제하는 것은 유류분권리자가 상속개시에 따라 받은 이익을 공제하지 않으면 유류분권리자가 이중의 이익을 얻기 때문이다.

유류분권리자의 구체적인 상속분보다 유류분권리자가 부담하는 상속채무가 더 많다면, 즉 순상속분액이 음수인 경우에는 그 초과분을 유류분액에 가산하여 유류분 부족액을 산정하여야 한다. 이러한 경우에는 그 초과분을 유류분액에 가산해야 단순승인 상황에서 상속채무를 부담해야 하는 유류분권리자의 유류분액 만큼 확보해줄 수 있기 때문이다.

그러나 위와 같이 유류분권리자의 구체적인 상속분보다 유류분권리자가 부담하는 상속채무가 더 많은 경우라도 유류분권리자가 한정승인을 했다면, 그 초과분을 유류분액에 가산해서는 안 되고 순상속분액을 0으로 보아 유류분 부족액을 산정해야 한다.

유류분권리자인 상속인이 한정승인을 하였으면 상속채무에 대한 한정승인자의 책임은 상속재산으로 한정되는데, 상속채무 초과분이 있다고 해서 그 초과분을 유류분액에 가산하게 되면 법정상속을 통해 어떠한 손해도 입지 않은 유류분권리자가 유류분액을 넘는 재산을 반환받게 되는 결과가 되기 때문이다. 상속채권자로서는 피상속인의 유증 또는 증여로 피상속인이 채무초과상태가 되거나 그러한 상태가 더 나빠지게 되었다면 수증자를 상대로

채권자취소권을 행사할 수 있다(대법원 2022. 8. 11. 선고 2020다247428 판결).

## 나. 청구권자 및 상대방

### (1) 청구권자

유류분반환청구권자는 피상속인의 직계비속, 배우자, 직계존속, 형제자매이다. 직계비속과 형제자매의 대습자도 피대습자의 유류분 범위 내에서 청구권을 갖는다.

태아도 살아서 출생하면 유류분 권리자가 될 수 있다. 이 청구권이 행사상·귀속상 일신전속권으로 보지 않는 견해라면 포괄승계인(포괄수유자, 상속분 양수인)도 유류분청구를 할 수 있을 것이다. 그러나 최근 판례<sup>256)</sup>는 원칙적으로 유류분반환청구권은 채권자대위권의 목적이 될 수 없다고 한다. 즉, 원칙적 행사상의 일신전속권으로 보고 있다. 한편, 유류분반환청구권의 행사에 의하여 반환되어야 할 유증 또는 증여의 목적이 된 재산이 타인에게 양도된 경우 그 양수인이 양도 당시 유류분권리자를 해함을 안 때에는 양수인에 대하여도 그 재산의 반환을 청구할 수 있다고 한다.<sup>257)</sup>

반환청구권의 상대방은 상속인, 유언집행자, 증여받은 자, 유증 받은 자이다. 유류분권자가 여러 사람이 되는 경우 각자 별도로 행사하여야 하며, 한 사람이 행사하더라도 다른 사람에게 영향이 미치지 않는다.

증여 또는 유증을 받은 다른 공동상속인이 수인인 경우에 증여 또는 유증을 받은 다른 공동상속인이 수인인 때에는 민법이 정한 유류분제도의 목적과 같은 법 제1115조 제2항의 규정취지에 비추어 유류분권리자는 그 다른 공동상속인들 중 증여 또는 유증을 받은 재산의 가액이 자기 고유의 유류분액을 초과하는 상속인을 상대로 하여 구 유류분액을 초과한 금액의 비율에 따라 반환청구를 할 수 있다고 보아야 한다.<sup>258)</sup>

증여 받은 사람이 그 목적물을 제3자에게 양도한 때에는 유류분 권리자는 제3자에게 반환청구를 하지 못하고 증여 받은 사람에게 그 가액을 청구할 수 있다고 본다. 그러나 유류분반환청구권의 행사에 의하여 반환되어야 할 유증 또는 증여의 목적이 된 재산이 타인에게 양도된 경우 그 양수인이 양도 당시 유류분권리자를 해함을 안 때에는 양수인에 대하여도 그 재산의 반환을 청구할 수 있다고 보아야 한다.<sup>259)</sup>

256) 대법원 2010. 05. 27. 선고 2009다93992 판결.

257) 대법원 2002. 04. 26. 선고 2000다8878 판결.

258) 대법원 1995. 06. 30. 선고 93다11715 판결.

259) 대법원 2002. 04. 26. 선고 2000다8878 판결.



## (2) 반환의 상대방

자신의 유류분액을 침해하여 유증 또는 증여를 받은 사람이 유류분청구의 상대방이 된다.

### 다. 소장 작성

#### (1) 서식 작성방법

작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

#### (2) 청구취지 기재례

1. 피고는 원고들에게 서울 ○○구 ○○동 100-3 대 176㎡ 중 각 136분의 3 지분에 관하여 20○○. 5. 12. 유류분반환을 원인으로 한 소유권이전등기절차를 각 이행하라.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.  
라는 판결을 구합니다.

1. 원고들에게,
  - 가. 피고 1은 각 10,000,000원과 위 각 돈에 대하여 이 사건 소장 송달 다음 날부터 이 판결선고일까지는 연 5%, 그다음 날부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하고,
  - 나. 피고 2는 각 8,265,306원과 위 각 돈에 대하여 이 사건 소장 송달 다음 날부터 이 판결선고일까지는 연 5%, 그다음 날부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.
2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.  
라는 판결을 구합니다.

1. 피고 1은,

가. 원고 1에게 91,071,428원, 원고 2, 3에게 각 60,714,285원과 위 각 돈에 대하여 20〇〇. 1. 28.부터 20〇〇. 6. 30.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고,

나. 별지 제1, 2, 3 목록 기재 부동산의 각 1/2지분 가운데, 원고 1에게 1,739,381/656,234,230 지분에 관하여, 원고 2, 3에게 각 1,159,587/656,234,230 지분에 관하여, 각 유류분 반환을 원인으로 한 소유권 이전 등기 절차를 이행하라.

2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3. 제1의 (가)항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

1. 원고들 각자에게 피고 김〇〇은 금50,000,000원씩, 피고 김△△은 금 60,000,000원씩 및 각 이에 대한 20〇〇. 2. 25.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5분의, 그다음 날부터 완제일까지는 연 12%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라.

2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

### (3) 첨부서류

가족관계증명서 1통, 기본증명서 1통, 부동산등기부등본 1통, 기타 유류분권이 침해된 사실을 증명할 수 있는 증거서류, 기타서류 등이 필요하다.

### (4) 소송비용

#### (가) 수입인지

소송목적의 값은 원고가 청구취지로써 구하는 범위 내에서 원고의 입장에서 보아 전부 승소할 경우에 직접 받게 될 경제적 이익을 객관적으로 평가하여 정한 금액을 말하는바, 소송목적에 따라 산정표준이 다음과 같이 다르다.

## ※ 통상의 소

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 확인 의 소                    | 소극적 확인 의 소 포함. 권리의 가액                                           |
| 증서진부확인 의 소                | - 유가증권 : 그 가액의 2분의 1<br>- 기타증서 : 200,000원                       |
| 금전지급 청구 의 소               | - 청구금액(이자, 손해배상, 위약금 또는 비용의 청구가 소송의 부대 목적이 되는 때에는 가액에 산입하지 않는다. |
| 물건의 인도, 명도 또는 방해배제를 구하는 소 | - 소유권에 기한 경우 : 목적물건 가액의 2분의 1                                   |
| 상린관계상의 청구                 | - 부담을 받는 이웃 토지부분 가액의 3분의 1                                      |
| 공유물분할청구 의 소               | - 목적물건의 가액에 원고의 공유지분 비율을 곱하여 산출한 가액의 3분의 1                      |
| 경계확정 의 소                  | - 다툼이 있는 범위의 토지부분의 가액                                           |
| 사해행위취소 의 소                | - 취소되는 법률행위의 목적의 가액을 한도로 한 원고의 채권액                              |

## ※ 등기, 등록 등 절차에 관한 소

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 소유권 이전등기  | - 목적물건의 가액                                     |
| 지상권, 임차권  | - 목적물건의 가액의 2분의 1                              |
| 담보물권, 전세권 | - 목적물건의 가액을 한도로 한 피담보채권액<br>(근저당권의 경우에는 채권최고액) |
| 지역권       | - 승역지 가액의 3분의 1                                |

## (나) 송달료

일반 민사사건의 송달료는 당사자의 수×5,200원(1회분)×15회분이다. 법원 구내은행에 송달료예납납부서를 작성하여 납부한다.

## (5) 소장제출(관할법원) 및 기간

반환청구권은 유류분 권리자가 상속의 개시와 반환하여야 할 증여 또는 유증을 한 사실을 안 때로부터 1년 내에 청구하여야 하고, 상속이 개시한 때로부터 10년 이내에 청구하여야 한다.

## 다. 공동상속인 상호 간의 유류분반환청구

### (1) 의의 및 성질

공동상속의 경우에 상속인의 한 사람이 피상속인의 재산을 너무 많이 증여를 받았기 때문에 다른 상속인의 유류분을 침해하는 경우가 생길 수 있다. 공동상속인 사이에 유류분 반환청구권의 성질도 역시 청구권으로 보는 것이 타당하다.

유류분을 반환청구하는 경우에 증여를 받은 사람이 여러 명인 때에는 각자가 얻은 증여가액의 비례로 반환해야 한다(민법 제1115조제2항).

### (2) 유류분반환청구 규정의 준용

#### (가) 준용규정

민법의 유류분반환청구에 관한 규정(민법 제1115조 이하)은 상속인이 아닌 사람에 대한 증여·유증에 의한 유류분침해의 경우에만 규정하고, 일부상속에 대한 증여·유증으로 인한 다른 상속인의 유류분침해에 대하여는 따로 규정하지 않고 민법 제1008조를 준용하고 있다(민법 제1118조).

공동상속인 중에 피상속인으로부터 재산의 생전증여에 의하여 특별수익을 한 자가 있는 경우에는 민법 제111조의 규정은 그 적용이 배제되고, 따라서 그 증여는 상속개시 1년 이전의 것인지 여부, 당사자 양쪽이 손해를 가할 것을 알고서 하였는지 여부에 관계없이 유류분 산정을 위한 기초재산에 산입된다.<sup>260)</sup>

공동상속인 중 특별수익을 받은 유류분권리자의 유류분 부족액을 산정할 때에는 유류분액에서 특별수익액과 순상속분액을 공제하여야 하고, 이때 공제할 순상속분액은 당해 유류분권리자의 특별수익을 고려한 구체적인 상속분에 기초하여 산정하여야 한다.<sup>261)</sup>

#### (나) 초과 특별수익자가 있는 경우 구체적 상속분과 상속재산으로부터의 현실적 취득액을 계산하는 방법

공동상속인 중에 특별 수익자가 있는 경우의 구체적인 상속분의 산정을 위하여는, 피상속인이 상속 개시 당시에 가지고 있던 재산의 가액에 생전 증여 가액을 가산한 후, 이 가액에 각 공동상속인별로 법정 상속분율을 곱하여 산출된 상속분의 가액에서 특별 수익자의 수증 재산인 증여 또는 유증의 가액을 공제하는 계산 방법에 의하여야 하고, 그 결과 그 구체적 상속분을 초과하여 재산을 취득한 초과 특별 수익자는 상속 재산에서 실제 취득

260) 대법원 1996. 02. 09. 선고 95다17885 판결; 대법원 2021. 7. 15. 선고 2016다210498 판결

261) 대법원 2021. 8. 19. 선고 2017다235791 판결.

할 액수는 없고, 나머지 공동상속인은 초과 특별 수익자가 없는 경우와 같은 계산 방법으로 위 상속재산(적극적 재산액+증여액-상속 채무액)에서 취득할 액수의 비율로 상속 재산을 현실로 취득한다.<sup>262)</sup>

#### (다) 초과 특별수익자가 있는 경우, 유류분의 산정 방법

민법 제1118조가 같은 법 제1008조를 준용하므로 공동상속인 중 자기의 상속분을 초과하여 증여받은 초과 특별수익자가 있는 경우, 유류분산정식{유류분 산정의 기초가 되는 재산액(A)(적극적 상속재산+증여액-상속채무액)×당해 유류분권자의 유류분 비율(B)-당해 유류분권자의 특별수익액(C)-당해 유류분권자의 순상속분액(D)}에서 유류분 산정의 기초가 되는 재산액(A)에 그 특별수익을 산입할 뿐만 아니라, 당해 유류분권자가 상속에 의하여 얻은 재산액(D)에서도 위의 방법에 따라 상속액을 계산하여야 한다.<sup>263)</sup>

### (3) 반환청구의 대상

반환의 대상이 되는 것은 특별수익자의 유류분을 초과한 부분에 한하고, 또 특별수익자의 유류분을 초과한 부분 중에서도 다른 공동상속인의 유류분을 침해한 내에서만 반환대상이 된다.

### (4) 반환청구의 범위

#### (가) 공동상속인 경우

다른 공동상속인의 유류분 침해를 생기게 한 유증·증여는 그것을 받은 상속인의 유류분의 액을 넘은 한도에서 반환청구의 대상이 된다. 즉, 유류분 권리자가 유류분반환청구를 함에 있어 증여 또는 유증을 받은 다른 공동상속인이 수인일 때에는 민법이 정한 유류분 제도의 목적과 민법 제1115조 제2항의 취지에 비추어 다른 공동상속인들 중 각자 증여받은 재산 등의 가액이 자기 고유의 유류분액을 초과하는 상속인만을 상대로 하여 그 유류분액을 초과한 금액의 비율에 따라서 반환청구를 할 수 있다고 하여야 한다.<sup>264)</sup> 공동상속인 중 1인이 자신의 법정상속분 상당의 상속채무 분담액을 초과하여 유류분권리자의 상속채무 분담액까지 변제한 경우, 그러한 사정을 유류분권리자의 유류분 부족액 산정 시 고려할 것인지 여부에 대하여, 판례는 금전채무와 같이 급부의 내용이 가분인 채무가 공동상속된 경우, 이는 상속개시와 동시에 당연히 공동상속인들에게 법정상속분에 따라 상속된 것으로

262) 서울중앙지방법원 1999. 03. 31. 선고 97가합20231 판결: 항소기각·확정.

263) 서울중앙지방법원 1999. 03. 31. 선고 97가합20231 판결: 항소기각·확정.

264) 대법원 1996. 02. 09. 선고 95다17885 판결.

봄이 타당하므로, 법정상속분 상당의 금전채무는 유류분권리자의 유류분 부족액을 산정할 때 고려하여야 할 것이나, 공동상속인 중 1인이 자신의 법정상속분 상당의 상속채무 분담액을 초과하여 유류분권리자의 상속채무 분담액까지 변제한 경우에는 유류분권리자를 상대로 별도로 구상권을 행사하여 지급받거나 상계를 하는 등의 방법으로 만족을 얻는 것은 별론으로 하고, 그러한 사정을 유류분권리자의 유류분 부족액 산정 시 고려할 것은 아니라고 하였다.<sup>265)</sup>

공동상속인 중에 피상속인으로부터 재산의 생전 증여로 민법 제1008조의 특별수익을 받은 사람이 있으면 민법 제1114조가 적용되지 않으므로, 그 증여가 상속개시 1년 이전의 것인지 여부 또는 당사자 쌍방이 유류분권리자에 손해를 가할 것을 알고서 하였는지 여부와 관계없이 증여를 받은 재산이 유류분 산정을 위한 기초재산에 포함된다. 공동상속인이 다른 공동상속인에게 무상으로 자신의 상속분을 양도하는 것은 특별한 사정이 없는 한 유류분에 관한 민법 제1008조의 증여에 해당하므로, 그 상속분은 양도인의 사망으로 인한 상속에서 유류분 산정을 위한 기초재산에 포함된다. 위와 같은 법리는 상속재산 분할협의의 실질적 내용이 어느 공동상속인이 다른 공동상속인에게 자신의 상속분을 무상으로 양도하는 것과 같은 때에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 상속재산 분할협의를 따라 무상으로 양도된 것으로 볼 수 있는 상속분은 양도인의 사망으로 인한 상속에서 유류분 산정을 위한 기초재산에 포함된다고 보아야 한다(대법원 2021. 8. 19. 선고 2017다230338 판결).

#### (나) 공동상속인과 공동상속인이 아닌 제3자가 있는 경우

공동상속인과 공동상속인이 아닌 제3자가 있는 경우에는 그 제3자에게는 유류분이라는 것이 없으므로 공동상속인은 자기 고유의 유류분액을 초과한 금액을 기준으로 하여, 제3자는 그 수증가액을 기준으로 하여 각 그 금액의 비율에 따라 반환청구를 할 수 있다고 하여야 한다.<sup>266)</sup>

#### (5) 반환청구권행사의 효과

반환청구에 의하여 상대방 상속인이 유류분액 이상으로 취득하게 된 유증이나 증여가 반환청구권자의 유류분을 침해하는 경우, 상대방 상속인이 피상속인으로부터 받은 유증이나 증여는 유류분을 침해한 한도 내에서 그 효력을 잃는다.

265) 대법원 2013. 03. 14. 선고 2010다42624 판결.

266) 대법원 1996. 02. 09. 선고 95다17885 판결; 대법원 2006. 11. 10. 선고 2006다6346 판결.

## 라. 기여분과 유류분과의 관계

유류분의 산정에 있어서는 기여분을 공제하지 않기 때문에 기여분의 유무가 유류분의 산정에 영향을 주지 않는다. 기여분은 상속재산의 가액에서 유증의 가액을 공제한 액의 범위 내에서만 인정되므로 피상속인이 전 재산을 유증하였다면 그 재산에 특별한 기여가 있었다더라도 기여분은 전혀 인정되지 않는다. 즉, 유증과 증여가 기여분보다 우선한다. 기여분은 유류분반환 대상이 아니므로 공동상속인 중의 1인에게 많은 액수의 기여분이 주어져서 다른 상속인의 취득액이 유류분에 미달되더라도 반환청구를 할 수 없다. 즉, 유류분 보다는 기여분이 우선한다. 이에 대한 상세한 설명은 196면을 참조한다.

## 마. 유류분청구 소장사례<sup>267)</sup>

[소장] 유류분청구의 소(상속분 전부를 피고에게 증여)

### 소 장

- 원 고 1. 전 ○ ○ (주민등록번호 : )  
 주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)  
 등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)  
 전화번호 : 팩 스 :
2. 전 ○ ○ (주민등록번호 : )  
 주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)  
 등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)  
 전화번호 : 팩 스 :
3. 전 ○ ○ (주민등록번호 : )  
 주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)  
 등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)  
 전화번호 : 팩 스 :

267) 한국법률사무자동화(주) 답변서·준비서면프로그램에서 인용(사이트 [www.lawebook.com/](http://www.lawebook.com/))

- 피 고 1. 노 ○ ○ (주민등록번호 : )  
주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)  
등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)
2. 전 ○ ○ (주민등록번호 : )  
주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)  
등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)
3. 전 ○ ○ (주민등록번호 : )  
주 소 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)  
등록기준지 서울 서초구 ○○대로 ○○(○○동)

유류분청구의 소

청 구 취 지

1. 원고들 각자에게 피고들은 금18,250,000원씩 및 각 이에 대한 20○○. 2. 25.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5푼의, 그 다음날부터 완제일까지는 연 12%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라.
  2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.
  3. 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자의 지위  
소외 1은 소외 2와 혼인하여 원고들 및 피고 3 등 4남매를 출산하여 자녀로 두고 있다가 협의이혼신고를 마친 다음 피고 1과 재혼하여 1985. 9. 15. 혼인신고를 마치고 피고 2를 출산한 후 1998. 7. 1. 사망하였습니다.
2. 상속재산 및 상속분  
소외 1은 사망 당시 별지 제1목록 기재 각 부동산을 소유하고 있었고, 위 각 부동산의 상속개시 당시 및 이 사건 상속재산분할 일에 근접한 1993. 5. 17.



당시 가액은 같은 목록 제1 기재 아파트가 금 420,000,000원, 같은 목록 제2 기재 대지(2/3 지분)가 금 1,474,795,200원, 같은 목록 제3 기재 건물(2층 부분 제외)이 금 61,831,800원, 같은 목록 제4 기재 토지(16529/33058 지분)가 금 68,760,640원으로서 소외 1의 상속재산의 가액합계는 금 2,025,387,640원(420,000,000 + 1,474,795,200 + 61,831,800 + 68,760,640)입니다. 따라서 소외 1의 사망 당시 남편이던 피고 1과 그 자녀들인 원고들(3명) 및 피고 2, 3이 소외 1의 재산을 공동상속하게 되었다 할 것이고 그들의 법정상속분은 피고 1이 3/13이고, 원고들 및 피고 2, 3이 각 2/13이라 할 수 있습니다.

### 3. 유류분의 침해

원고들은 소외 1이 자신의 상속재산인 이 사건 부동산에 대한 20분의 6지분을 19〇〇. 4. 20. 피고에게 전부 증여함으로써 19〇〇. 12. 5. 사망 당시에 재산이 전혀 없게 되었고, 증여 당시에 소외 1은 78세 된 노인으로서 위 상속분 이외에 다른 재산이 전혀 없었으므로 위 상속분 전부를 피고에게 증여함으로써 유류분권 리자인 원고들에게 손해를 가하게 된다는 사실을 알고 있었다고 할 것이므로 피고는 원고들에게 유류분을 반환할 의무가 있습니다.

### 4. 결 론

그렇다면, 피고들은 원고들에게 구체적 상속분이 유류분에 미달하게 된 각 금 18,250,000원을 지급할 의무가 있다 할 것이므로 위 금원을 구하기 위해 이 건 청구에 이른 것입니다.

#### 입 증 방 법

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. 갑 제1호증의 1 내지 2 | 가족관계증명서(원고, 피고)   |
| 1. 갑 제2호증의 1 내지 2 | 주민등록등(초)본(원고, 피고) |
| 1. 갑 제3호증         | 제적등본              |
| 1. 갑 제4호증의 1 내지 3 | 부동산등기사항전부증명서      |

#### 첨 부 서 류

1. 입증방법각 1통
1. 소장부분 1통

1. 납부서 1통

2000. 5. .

원 고 1. 전 ○ ○ (인)

2. 전 ○ ○ (인)

3. 전 ○ ○ (인)

서울중앙지방법원 귀중

[소장] 유류분반환청구의 소(소유권이전등기 및 금전청구)

## 소 장

원 고 임 상 희 (주민등록번호 - )

서울 강남구 논현로123길 4

전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

피 고 장 순 영 (주민등록번호 - )

서울 강남구 논현로123길 4

전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

유류분 반환 청구의 소

## 청 구 취 지

1. 피고는 원고에게,

가. 별지 목록 기재 부동산 4분의1 지분에 관하여 이 사건 소장 송달일 유류분 반환을 원인으로 한 소유권 이전등기 절차를 이행하고,

나. 금19,778,420원 및 이에 대한 이 사건 소장 송달 다음날부터 완제일까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

3. 위 제1항 '나'부분에 대하여는 가집행 할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

## 청 구 원 인

1. 원고는 소외 망 임봉철(2000. 3. 19. 사망)과 성명미상 위 망인의 처 사이에서 태어난 딸이고, 피고는 위 망 임봉철과 1990. 10. 18. 혼인신고를 필한 법률상 부부였는데, 2000. 12. 5. 위 망인과 협의이혼을 하였습니다.

2. 피고는 위 망인과 협의이혼 하기전인 2000. 11.경 위 망인이 간종양등으로 신병이 악화되자 별지목록 기재 부동산(이하 이 사건 부동산이라 함)을 위 망인으로부터 증여받아 2000. 11. 20. 피고 앞으로 소유권 이전등기를 경료하였습니다.

위와 같이 피고가 위 망인의 부동산을 자신 앞으로 소유권 이전등기를 경료한 것은 원고가 전처 소생의 딸이라고 재산을 주지 않으려고 한 것이었고, 위 망인은 2000. 3. 19. 사망하기 직전 원고에게 피고가 계모란 사실을 뒤늦게 가르쳐 주었으며, 사망당시 망인의 재산이라고는 이 사건 부동산이 유일한 바, 원고는 위 망인의 직계비속으로서 그 법적상속분 2분의1에 해당하는 유류분을 갖고 있고 그 유류분은 지분이라 할 것입니다.

따라서 위 망인의 유일한 재산인 위 부동산이 피고에게 증여됨으로써 원고에게 위 유류분 부족이 생겼다 할 것입니다.

3. 한편, 위 망인은 생존시 1988.경부터 20여년 동안 소외 서울정밀화학 주식에 근무하다가 2000. 10.경 간종양으로 신병이 악화되어 퇴직하였고, 원고는 2000. 11. 25.부터 서울시 종로구 종로3가 소재 소외 한강산업(주)에 입사하여 근무하다가 2000. 12. 11. 퇴직 하였는데, 원고는 피고의 친딸인줄 알고 위 한강산업 근무 시 수령한 월급료와 상여금, 퇴직금 전부를 원고의 시집갈 때 혼례비용으로 피고에게 맡겼고, 원고의 그동안 교육비 생계비 등 일체는 전부 부(父)인 위 망 정한철이 부담하였습니다.

## 가. 급여 및 상여금 총액

(1) 2000년 급여액 금4,873,200원+상여금 730,400원-소득세 금52,560원-주민세 금4,020원=금 5,547,020원

(2) 2000년 급여액 금5,584,930원+상여금 749,630원-소득세 금79,950원-주민세 금5,990원=금6,248,620원

- (3) 20〇〇년 급여액 금5,206,300원+상여금 1,049,470원-소득세 금102,900원  
-주민세 금7,650원=금6,145,220원

나. 퇴 직 금

입사년월일 : 20〇〇. 11. 25.

퇴사년월일 : 20〇〇. 12. 1.

퇴직소득 수입금액 금1,837,560원

\*\* 계 산

금 5,547,020원 + 금6,248,620원 + 금6,145,220 + 금1,837,560 = 금  
19,778,420원

따라서 피고는 원고가 맡긴 혼례비용 금19,778,420원을 반환하여야 할 것입  
니다.

4. 그렇다면 피고는 원고에게, 별지목록 기재 부동산중 4분의1지분에 관하여 이사  
건 소장 송달일 유류분 반환을 원인으로 한 소유권 이전등기 절차를 이행하고,  
금19,778,420원 및 이에 대한 이 사건 소장 송달 다음날부터 완제일까지 소송촉  
진 등에 관한 특례법 소정의 연 12%의 비율에 의한 지연손해금을 지급하여야  
할 것입니다.

입 증 방 법

1. 토지·건물등기사항전부증명서(갑제 1호증의 1, 2)
1. 가족관계증명서, 제적등본(갑제 2호증의 1, 2)
1. 사망진단서(갑제 3호증)

첨 부 서 류

- |           |      |
|-----------|------|
| 1. 위 입증서류 | 각 1통 |
| 1. 소장부분   | 1통   |
| 1. 납부서    | 1통   |

20〇〇. 5.

## 위 원 고 임 상 회

서울중앙지방법원 귀중

## [소장] 유류분반환청구의 소(지분소유권이전등기청구)

## 소 장

원 고 이 순 숙 (주민등록번호 - )

울산 남구 개운로123길 4

소송대리인 변호사 김 민 호

울산 남구 신정로23

전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

피 고 박 미 화 (주민등록번호 - )

공부상주소 : 부산 서구 부민로602

송달주소 : 부산 북구 구포로616

전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

유류분반환 청구의 소

## 청 구 취 지

1. 피고는 원고에게 별지 목록 기재 부동산 중 13분의 1 지분에 관하여 이 사건 소장 송달일 유류분 반환을 원인으로 한 소유권 이전등기 절차를 이행하라.
  2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

## 청 구 원 인

1. 피고는 별지 목록 기재 부동산(이하 이 사건 부동산이라 함)을 소외 망 ○○원으로부터 20○○. 3. 22. 유증받고 위 같은 날 위 망인이 사망하자 20○○. 8. 17. 위 사망일자 유증을 원인으로 하여 피고 명의의 소유권 이전등기를 경료 하였습니다.

2. 그런데 위 망인의 유족으로는 처인 피고, 장남인 소외 ○○근, 딸인 원고, 차남인 소외 ○○근, 딸인 소외 ○○이, 3남인 소외 ○○근이 있는데, 피고는 위 ○○근, ○○근과 원고의 계모(위 망인의 본처는 혼인신고를 하지 않은채 위 ○○근, ○○근과 원고를 출산한후 일자불상경 사망)로서 위 망인 생존시 망인 소유의 재산을 명의 신탁해지로 자신앞으로 소유권 이전등기하거나 매각처분하였고, 사망 당시 망인의 재산이라고는 이 사건 부동산이 유일한 바, 원고는 위 망인의 직계비속으로서 그 법정 상속분 2분의 1에 해당하는 유류분을 갖고 있고, 그 유류분은 (×)지분이며, 위 망인이 피고에게 유증한 사실을 원고가 알게된 것은 이 사건 부동산에 대한 상속등기를 촉구하려고 관할 법원등기과로부터 20○○. 8. 22. 위 부동산 등기사항전부증명서를 교부받아 보고서야 알았습니다. 따라서 위 망인의 유일한 재산인 위 부동산이 유증됨으로써 원고에게 위 지분 상당의 유류분 부족이 생겼다 할 것입니다.

3. 그렇다면 피고는 원고에게 별지목록 기재 부동산 중 13분의1 지분에 관하여 이 사건 소장 송달일 유류분반환을 원인으로 한 소유권 이전등기 절차를 이행하여야 할 것입니다.

#### 입 증 방 법

1. 등기사항전부증명서(갑제 1호증의 1 내지 6)
1. 건축물관리대장등본(갑제 2호증의 1, 2)
1. 토지대장등본(갑제 3호증의 1 내지 4)
1. 토지가격 확인원(갑제 4호증의 1 내지 4)
1. 제적등본(갑제 5호증)
1. 가족관계증명서(갑제 6호증의 1 내지 4)
1. 기타 변론 시 적의 제출하겠음.

#### 첨 부 서 류

- |           |      |
|-----------|------|
| 1. 위 입증서류 | 각 1통 |
| 1. 소장부분   | 1통   |
| 1. 소송위임장  | 1통   |

20〇〇. 10.

원고 소송대리인

변호사 김 민 호

부산지방법원 귀중

[소장] 유류분반환청구의 소(피고들에 대한 증여는 유류분권리자를 해할 것을 알고 한 증여이거나 공동상속인의 특별수익분으로서 유류분산정 대상)

### 소 장

원 고 1. 〇〇병

〇〇 〇〇구 〇〇로 〇〇아파트 107-1404

2. 〇〇용

〇〇 〇〇구 〇〇로 〇〇아파트 111-1521

피 고 1. 〇〇훈

〇〇 〇〇구 〇〇로 〇〇아파트 107-1402

2. 〇〇세

92 〇〇 엘3터 1알4 〇〇〇

(92 〇〇 L3T 1R4 〇〇〇)

대한민국 주소 : 〇〇 〇〇구 〇〇로 11-74 〇〇빌라 306호

유류분반환청구의 소

### 청 구 취 지

1. 원고들 각자에게 피고 〇〇훈은 금 600,000,000원씩, 피고 〇〇세는 금 80,000,000원씩 및 각 이에 대한 20〇〇. 10. 3.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5푼의, 그 다음날부터 완제일까지는 연 12%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라.

2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3. 위 1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

### 청 구 원 인

#### 1. 신분관계

원고들과 피고들 및 소외 ○○성은 소외 ○○주가 20○○. 10. 2. 사망하여 그 재산을 공동상속한 재산상속인입니다.

#### 2. 상속관계 및 유류분의 침해

피상속인인 소외 망 ○○주는 그의 생존시인 20○○. 5. 2. 망인의 소유로서 피고들 명의로 등기되어 있던 ○○ ○○구 ○○동 809-12, 13 대지를 금 10,707,000,000원에 타에 처분(그 지상건물은 피고 ○○병의 소유로서 금 1,070,000,000원에 대지와 함께 처분되었습니다.)한 다음 그 대금을 같은 해 8 월경 수령하였다가 사망하기 4개월 전인 20○○. 6. 18.경 장남인 피고 ○○훈에게 금 6,707,000,000원, 2남인 피고 ○○세에게 금 2,800,000,000원을 증여 하였습니다. 따라서 위 증여에 의하여 원고들의 유류분이 침해당하였다고 할 것이며 피고들에 대한 반환청구 액수의 계산은 다음과 같습니다.

#### 3. 침해된 유류분의 계산

원고들과 피고들 및 소외 ○○성 등 각 상속인의 유류분은 원래의 상속지분  $1/5 \times \text{유류분} 1/2 = 1/10$ 이고

원고들의 유류분은  $10,707,000,000\text{원} \times 1/10 = 1,070,700,000\text{원}$ 입니다.

따라서 원고들의 유류분 피침해액은 1,070,700,000원입니다.

피고 ○○훈의 원래 상속지분은  $10,707,000,000 \times 1/5 = 2,141,400,000\text{원}$ 이고

피고 ○○병의 상속지분 초과액(유류분 침해액)은

$6,707,000,000 - 2,141,400,000 = 4,565,600,000\text{원}$ 이고 마찬가지로

피고 ○○세의 원래 상속지분은  $10,707,000,000 \times 1/5 = 2,141,400,000\text{원}$ 이고

피고 ○○세의 상속지분 초과액(유류분 침해액)은

$2,800,000,000\text{원} - 2,141,400,000\text{원} = 658,600,000\text{원}$ 입니다. 그러므로

피고들의 상속지분 초과액(유류분 침해액) 합계는



4,565,600,000원+658,600,000원=5,224,200,000원입니다. 여기서  
 피고 ○○훈의 원고들에 대한 반환의무액을 계산하면  
 $1,070,700,000\text{원} \times 4,565,600,000\text{원} / 5,224,200,000\text{원} = 935,719,000\text{원}$  (1,000  
 원미만 버립니다. 이하 같다.)  
 피고 ○○세의 원고들에 대한 반환의무액을 계산하면  
 $1,070,700,000\text{원} \times 658,600,000\text{원} / 5,224,200,000\text{원} = 134,980,000\text{원}$ 입니다.

#### 4. 유류분의 반환의무

그렇다면 원고들에게 피고 ○○훈은 각 금 935,719,000원씩을, 피고 ○○세는  
 각 금 134,980,000원씩을 각 반환할 의무가 있다고 할 것인바 원고들은 우선  
 그 일부청구로서 피고 ○○훈에 대하여는 금 600,000,000원씩을, 피고 ○○세  
 에 대하여는 금 80,000,000원씩 및 이에 대한 위 망인의 사망에 의한 상속개시  
 일인 20○○. 10. 2.부터 이 사건 소장 부분 송달의일까지는 연 5푼의, 그 다음  
 날부터 완제일까지는 연 12%의 법정지연손해금의 지급을 구하기 위하여 이 사  
 건 청구에 이르렀습니다.

#### 5. 산입될 증여

위 망인의 상속인들에 대한 위 증여시기가 위 20○○. 6. 18. 이전으로서 위  
 망인의 사망 1년전일 수도 있으나 그렇다하여도 망인의 피고들에 대한 증여는  
 유류분권리자를 해할 것을 알고 한 증여이거나 공동상속인의 특별 수익분으로  
 서 유류분산정의 대상이 되는 재산에 산입될 것이기 때문에 유류분반환청구의  
 대상이 되는데에도 지장이 없습니다. 또한 위 망인의 상속재산으로는 위 토지  
 외에 다른 부동산도 있으나 소송진행의 편의상 위 부동산에 관한 부분만 청구하  
 고 추후 변론에서 나머지 재산에 대하여도 주장할 것입니다.

#### 입 증 방 법

|                  |         |     |
|------------------|---------|-----|
| 1. 갑제1호증의 1, 2   | 각 제적등본  | 각1통 |
| 1. 갑제1호증의 3 내지 7 | 각 호적등본  | 1통  |
| 1. 갑제1호증의 1, 2   | 각 등기부등본 | 1통  |
| 1. 갑제3호증         | 공증서     | 1통  |
| 1. 갑제4호증         | 통고서     | 1통  |

그 밖의 입증방법은 변론시 수시로 제출하겠습니다.

### 첨 부 서 류

|             |      |
|-------------|------|
| 1. 위 각 입증방법 | 각 1통 |
| 1. 소장 부분    | 1통   |
| 1. 송달료 납부서  | 1통   |
| 1. 소송위임장    | 1통   |

20〇〇. 4. 17.

위 원고들 소송대리인 김〇〇 (인)

지방법원 귀중

### 바. 답변서와 준비서면 사례<sup>268)</sup>

[답변서] (유류분. 원고들은 유류분 반환소송을 제기 전부 승소 판결을 받았고, 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위한 항소를 제기해야 하는데 항소를 포기하여 소송이 확정된 바, 그 확정판결의 기판력이 미치므로 본 건 소는 기각되어야 한다는 피고의 항변)

※ 항소심 답변서는 하단 참조

### 답 변 서

사 건 : 20〇〇가합000 유류분 반환

원 고 : 〇〇호 외 2명

피 고 : 〇〇화 외 1명

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 답변합니다.

청구취지에 대한 답변

268) 한국법률사무자동화(주) 답변서 · 준비서면프로그램에서 인용(사이트 [www.lawebook.com/](http://www.lawebook.com/))

1. 원고들의 청구를 기각한다.
  2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

#### 청구원인에 대한 답변

##### 1. 귀원 20○○가합1234 유류분 반환소송의 내용과 판결

가. 원고들은 피고들을 상대로 귀원 20○○가합1234 유류분 반환소송에서 원고들이 산정한 유류분액 전부를 주장하였습니다.

원고들은 20○○. 4. 28. 피고들을 상대로 유류분 반환의 소를 제기하면서 피고들이 유증 받은 부동산 전부(갑 제1호증의 1~9 참조), 망 ○○관 명의 예금채권 및 피고 ○○화에 대한 현금 증여액 전부를 유류분 산정의 기초가 되는 재산액으로 특정하였고, 소장 말미에 괄호를 사용하여 “추후 망 ○○관의 증여재산 등에 대하여 감정평가 등을 거쳐 정확한 가액을 파악한 다음 청구취지를 확장할 계획입니다”라고 명시한 바 있습니다(을 제1호증, 원고 제출 귀원 20○○가합1234 유류분 반환소송 소장)

즉, 원고들은 귀원의 위 20○○가합1234 사건 소 제기시에 유류분 산정의 기초가 되는 재산 전부를 파악하여 소를 제기하였고, 다만, 소장 말미에서 망 ○○관의 증여재산 등에 대한 추후 정확한 가액을 파악한 다음 청구취지를 확장할 계획임을 밝혔을 뿐이며, 그에 따라 아래 1.의 다.항에서 후술하는 바와 같이 20○○. 12. 11. 청구취지를 확장하여 변경한 바 있습니다.

따라서, 원고들은 귀원의 위 20○○가합1234 사건 소를 제기를 하면서 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 아니하였다고 할 것입니다.

나. 피고들은 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다고 주장하였습니다.

피고들은 귀원의 위 20○○가합1234 사건에서 20○○. 9. 27.자 및 20○○. 12. 15.자 준비서면을 통해 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다고 주장한 바 있습니다(을 제2호증, 피고의 20○○. 9. 27.자 및 12. 15.자 준비서면).

이에 대하여, 원고들은 위 현금 9억300만원은 원래 망 ○○성이 20○○. 12. 20. 사전 증여받은 경기 ○○시 ○○동 1398 전 2,856평방미터의 매매대금으로서 유류분 재산액에 포함되어서는 아니 된다는 주장만을 하였습니다(을 제3호증, 원고의 20○○. 1. 11.자 준비서면).

#### 다. 원고들의 유류분액에 대한 청구취지 확장

원고들은 귀원의 위 20○○가합1234 사건에서 20○○. 12. 11. 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출하였는데, 피고들이 주장한 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함하여 계산한 것이 아니라 원고들이 최초로 계산한 유류분 산정의 기초가 되는 재산액 합계 금 1,572,603,674원에서 최초 소장(을 제1호증 참조) 별지 목록 기재 3, 4 부동산을 제외한 나머지 부동산의 감정평가 결과까지 종합한 다음 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 합계 금 1,950,413,174원으로 하여 원고들의 유류분액을 계산한 후 청구취지를 확장하여 유류분 전부를 청구(을 제4호증 청구취지 및 청구원인 변경신청서)하였습니다.

원고들이 제출한 위 20○○. 12. 11. 청구취지 및 청구원인 변경신청서에서는 유류분 전액을 청구하였을 뿐이고, 더 이상 유류분 일부 청구 취지임을 명시한 바 없음을 알 수 있습니다.

#### 라. 귀원 20○○가합1234 유류분 반환소송의 판결

원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합1234 유류분 반환소송에서 20○○. 4. 26. <원고들에게 피고 ○○화는 각 108,845,265원, 피고 ○○철은 각 53,689,167원을 지급하라>는 승소판결을 받아(갑 제2호증의 1 판결문 참조) 쌍방 항소를 포기하여 20○○. 5. 15. 확정(갑 제2호증의 2 확정증명원)된 바 있습니다.

위 판결은 피고들의 주장을 받아들여 즉 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜 산

출하였고 원고들이 청구한 유류분 반환금액보다 많았지만 원고들이 청구한 금액한도 내에서 판결이 선고되었습니다.

#### 마. 원고들의 항소포기

원고들은 판결문을 수령하여 원고들이 청구한 금액보다 많다는 사실을 알았고, 따라서 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위하여 항소를 제기할 이익이 있음에도 항소를 제기하지 않았습니다.

### 2. 귀원 위 20○○가합1234 사건 확정판결의 기판력이 본 건 소 제기에 미치는지 여부

#### 가. 판례의 태도

가분채권의 일부에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 아니한 이상 그 확정판결의 기판력은 청구하고 남은 잔부청구에까지 미치는 것이므로 그 나머지 부분을 별도로 다시 청구할 수 없고, 전소의 사실심 변론종결 당시까지 소유권이전을 소구할 수 있는 공유지분의 범위를 정확히 알 수 없어 결과적으로 전소에서 일부 공유지분에 관한 청구를 하지 못하게 되었다 할지라도 이를 일부청구임을 명시한 경우와 마찬가지로 취급하여 전소의 확정판결의 기판력이 그 잔부청구에 미친다는 것이 판례의 태도입니다(대법원 1993. 6. 25. 선고 92다33008호 판결 등).

#### 나. 이 사건의 경우 원고들이 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시했는지 여부

원고들은 처음부터 귀원 20○○가합1234 유류분 반환 소송을 하면서 원고들이 주장하는 금원 전부를 청구하였습니다.

피고들이 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다고 주장한 바, 만약 피고들의 주장이 받아들여진다면 원고들에게 돌아가는 금원이 더 많아지는 것을 알

면서도 예비적 청구 등 아무런 조치를 하지 않았습니다.

원고들은 위 20〇〇가합1234 사건에서 20〇〇. 12. 11. 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출하였는데 당시에는 위와 같이 피고들이 이미 망 〇〇성이 망 〇〇관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다는 주장을 하였음에도 불구하고 원고들이 주장하고 원고들이 계산한 유류분 전부만 청구하고, 청구취지 확장 신청서 그 어디에서도 유류분 일부청구 취지를 명시한 바 없습니다(을 제4호증 청구취지 및 청구원인 변경신청서 참조)

원고들의 청구취지 금원 확장도 감정평가 결과까지 종합하여 유류분 전부를 청구하였습니다.

이처럼 원고들은 귀원의 위 20〇〇가합1234 사건 소송의 사실심 변론종결 당시까지 유류분 전액을 청구하였고, 이는 유류분액의 범위를 전부를 예상하고 청구하였는데, 그 이유는 당시 위 20〇〇가합1234 사건의 원고는 현재 원고들 뿐만 아니라 망 〇〇성의 처 〇〇순 및 자녀 〇〇은도 원고이어서 피고들의 주장대로 현금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함되어 유류분이 계산된다면 위 20〇〇가합1234 사건의 원고 〇〇호, 〇〇순, 〇〇미에 대한 유류분 반환액은 증가하나, 위 〇〇순과 〇〇은의 유류분은 부족액이 없어서 소를 취하할 수 밖에 없는 상황이었기 때문입니다. 즉, 원고 대리인은 위 20〇〇가합1234 사건의 원고 〇〇호, 〇〇순, 〇〇미, 〇〇순, 〇〇은을 모두 대리하는 바람에 위 〇〇호, 〇〇순, 〇〇미와 위 〇〇순, 〇〇은의 이해가 충돌되는 상황에 이르렀기 때문에 피고들 주장의 현금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함된 사실을 충분히 알면서도 조치를 취하지 아니한 채 유류분 전부를 청구하였다고 할 것입니다.

더 나아가 판결이 선고되어 피고들의 주장대로 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함되어 계산된 바, 원고들은 판결문을 수령하여 원고들이 청구한 금액보다 많다는 사실을 알았고, 따라서 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위하여 항소를 제기할 이익이 있음에도 불구하고 위 〇〇호,

○○순, ○○미와 위 ○○순, ○○은의 이해가 충돌되는 상황 때문에 항소를 제기하지 못한 것입니다.

#### 다. 소 결

가분채권에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 그것이 나머지 부분을 유보하고 일부만 청구하는 것이라는 취지를 명시하지 아니한 경우에는 그 확정판결의 기판력은 나머지 부분에까지 미치는 것이어서 별도로써 나머지 부분에 관하여 다시 청구할 수는 없습니다.

가사 일부 청구에 관하여 전부 승소한 원고들이 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위한 항소가 예외적으로 허용되므로 전부 승소한 판결에 대해서도 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위한 항소를 제기해야 하는데 포기함으로써 전소송의 확정판결의 기판력이 이 사건 잔부청구에 미친다고 할 것입니다. 이와 같이 귀원 20○○가합1234 유류분 반환 소송의 변론 전 취지를 살펴봐도 원고들은 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 않고 전부 청구한 사실이 명백합니다.

#### 3. 결 론

원고들은 피고들을 상대로 귀원 20○○가합1234 유류분 반환소송을 제기하면서 유류분 전부에 대한 소를 제기하여 전부 승소 판결을 받았고, 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위한 항소를 제기해야 하는데 항소를 포기하여 소송이 확정된 바, 그 확정판결의 기판력이 미치므로 본 건 소는 기각되어야 합니다.

#### 입 증 방 법

- |               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 1. 을 제1호증     | 원고 제출 귀원 20○○가합1234 유류분반환 소장            |
| 1. 을 제2호증의1~2 | 피고의 20○○. 9. 27.자 및 20○○. 12. 15.자 준비서면 |
| 1. 을 제3호증     | 원고의 20○○. 1. 11.자 준비서면                  |
| 1. 을 제4호증     | 원고의 청구취지 및 청구원인 변경신청서                   |





(2) 이에 대하여, 항소인들(이하 ‘원고들’이라고 함)은 ○○지원 유류분 반환 청구 사건에서 20○○. 12. 11. 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출하였는데, 피고들이 주장한 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시키지 아니하였습니다(을 제4호증 청구취지 및 청구원인 변경신청서 참조)

(3) 또한, 원고들은 위 현금 9억300만원은 원래 망 ○○성이 20○○. 12. 20. 사전 증여받은 경기 시흥시 거모동 1398 전 2,856평방미터의 매매대금으로서 유류분 재산액에 포함되어서는 아니된다고 주장하였습니다(을 제3호증, 원고의 20○○. 1. 11.자 준비서면 참조).

위 준비서면을 보면 모두 현재 본 건 소의 원고들을 포함한 “원고들”이라고 특정하였을 뿐이고, “원고 ○○순, 원고 ○○은”이라고 특정한 적이 없는 점에 비추어 원고들도 위 ○○성의 증여금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되면 원고들에게 유리하다는 사실을 충분히 알면서도 위 ○○순 및 ○○은을 위해 위 ○○성의 증여금 9억300만원이 유류분 재산액에 포함되어서는 아니된다고 주장하였다고 할 것입니다.

(4) ○○지원 유류분 반환 청구 사건에서 피고들의 주장을 받아들여 즉, 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜 산출하였고 원고들이 청구한 유류분 반환금액보다 많았지만 원고들이 청구한 금액한도 내에서 판결이 선고되었고,(갑 제2호증의 1 판결문 참조) 쌍방 항소를 포기하여 20○○. 5. 15. 확정(갑 제2호증의 2 확정증명원)된 바 있습니다.

## 2. 피고들의 주장

(1) 원고들은 ○○지원 유류분 반환 청구 사건에서 원고들에게 유리한 피고들의 <망 ○○성에 대한 거모동 토지매매대금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 주장>을 받아들이지 아니하였습니다.

(2) ○○지원 유류분 반환 청구 사건에서 피고들의 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함시켜야 한다는 주장을 원고들의 이익으로 원용하

면 아래 표와 같이 피고들이 원고들에게 반환하여야 유류분 반환 총액은 원고들의 청구액 합계(650,137,728원)보다 많은 695,511,045원이 됨에도 불구하고, 이를 원용하지 아니한 단 한가지 이유는 원고들이 소외 ○○순, ○○은과 공모하여 피고들로부터 유류분을 반환받기로 하였는데, 위 주장을 받아들이면 위 ○○순, ○○은이 반환받아야 할 유류분 반환액이 “0원”이 되기 때문이었다고 할 것입니다.

| 유류분<br>원고 | 원고청구(사전증여액 9억3백만원 미포함)에 따른 피고들의 지급예정액 |             | 사전증여액 9억3백만원 포함에 따른 피고들의 지급예정액 |             | 판결에 따른 지급액   |             |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|           | ○○화                                   | ○○철         | ○○화                            | ○○철         | ○○화          | ○○철         |
| ○○순       | 65,307,159                            | 32,213,500  | 0                              | 0           | 0            | 0           |
| ○○은       | 43,538,106                            | 21,475,667  | 0                              | 0           | 0            | 0           |
| ○○호       | 108,845,265                           | 53,689,167  | 159,119,080                    | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| 박은순       | 108,845,265                           | 53,689,167  | 159,119,080                    | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| 박은미       | 108,845,265                           | 53,689,167  | 159,119,080                    | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| 합계        | 435,381,060                           | 214,756,668 | 477,357,240                    | 218,153,805 | 326,535,795  | 161,067,501 |
| 총 합계      | 650,137,728원                          |             | 695,511,045원                   |             | 487,603,296원 |             |

즉, 원고들은 ○○지원 유류분 반환 청구 사건에서 일단 피고들의 증여주장을 부인하여 증여부인 주장이 받아들여질 경우에는 원고들의 유류분 청구액 뿐 만 아니라 소외 ○○순, ○○은의 유류분반환액을 보장받고, 만약에 원고들의 증여부인 주장이 받아들여지지 아니할 경우에는 추후에 원고들만 별도로 본 건과 같은 유류분반환청구의 소를 제기하여 원고들의 유류분반환액을 확보하려는 꾀수를 사용하였다고 할 것입니다.

이는 ○○지원 유류분 반환 청구 사건의 원고들 중 현재 본 건 소외 원고들과 위 ○○순 및 ○○은의 이해관계가 충돌됨에도 불구하고 동일한 소송대리인이 소송수행을 하면서 동일한 주장을 한 불가피한 결과라고 할 것인 바, 이해관계가 충돌하는 당사자들이 공모하여 동일한 소송대리인으로 하여금 동일한 주장을 하도록 한 후에 재판부의 판단여하에 따라 자신들에게 유리한 결과를 선택하는 방법으로 소송절차를 악용한 것으로서 신의성실의 원칙을 위배한 권리남용이라고 할 것입니다.

(3) 원고들은 ○○지원 유류분 반환 청구 사건의 판결문을 통해 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 사실을 알면서도 청구취지

확장 등을 위한 항소를 포기하였습니다.

(4) 따라서, ○○지원 유류분 반환 청구 사건 진행과정을 통하여 원고들은 원고들에게 유리한 피고들의 <망 ○○성에 대한 ○○동 토지매매대금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 주장>을 배척한 바 있고, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 사실을 알면서도 청구취지 확장 등을 위한 항소를 포기하였음에도 불구하고, 다시 이 사건 소를 제기하여 위 ○○성 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함하여야 함을 주장하면서 잔존 유류분 반환을 구하는 것은 소송절차를 악용한 것으로서 권리남용 내지는 신의성실의 원칙에 위배된다고 할 것입니다.

### 3. 원고들의 항소이유에 대한 반박

○ 원고들은 피고들의 주장대로 본 건 거모동 토지 매매대금이 ○○성에 대한 증여금이라고 인정되든지, 혹은, 원고들 주장대로 위 거모동 토지를 증여받은 것으로 인정되든지 여부와 관계없이 피고들의 경제적인 차이는 크게 없을 뿐만 아니라, 피고들의 항소실익도 없다고 주장합니다.

그러나, 피고들로서는 ○○지원 유류분 반환 청구 사건 소송진행 경과를 지켜보면서 원고들의 청구를 인락하게 되면 피고들이 원고들에게 반환하여야 할 유류분 반환 총액은 본 건 거모동 토지 매매대금이 ○○성에 대한 증여금이라고 인정되는 경우의 695,511,045원보다 적은 650,137,728원(원고들의 청구액 합계)이 되므로 약 4,500만원을 감액시킬 수 있고,

○○지원 유류분 반환 청구 사건 원심 판결과 같이 판결이 확정되면 피고들이 원고들에게 반환하여야 할 유류분 반환 총액은 487,603,296원에 불과할 뿐만 아니라, 만약에 원고들이 ○○지원 유류분 반환 청구 사건의 원심 판결에 대해 항소하게 되면 피고들도 항소를 제기하여 항소심에서 원고들의 청구를 인락하게 되면 위와 같이 본 건 거모동 토지 매매대금이 ○○성에 대한 증여금이라고 인정되는 경우의 695,511,045원보다 적은 650,137,728원(원고들의 청구액 합계)이 되므로 약 4,500만원을 감액시킬 수 있다고 할 것입니다.

따라서, 본 건 거모동 토지 매매대금이 ○○성에 대한 증여금이라는 피고들의 주장으로 인한 피고들의 경제적인 차이가 크게 없을 뿐만 아니라, 피고들의 항소실익도 없다는 원고들의 주장은 설득력이 없다고 할 것입니다.

#### 4. 원심의 판단 및 이에 대한 의견

원고들과 ○○순, ○○은이 ○○지원 유류분 반환 청구 사건에서 피고들로부터 <망 ○○성에 대한 거모동 토지매매대금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 주장>이 담긴 20○○. 9. 27.자 준비서면을 송달받은 이후에 청구취지를 변경하였으나 ○○성 증여금을 유류분 산정의 기초가 되는 재산으로 산입하여 청구취지를 변경하지 않았을 뿐만 아니라, 오히려 적극적으로 위 ○○성 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜서는 아니된다고 주장하였고, 이에 원심은 ○○지원 유류분 반환 청구 사건의 소송 경과 및 내용을 종합적으로 고려하여 항소를 포기한 것으로 판시하였습니다.

따라서, 원고들의 본 건 소제기는 신의성실의 원칙상 허용되지 않는다는 피고들의 주장을 받아들여 원고들의 청구를 각하한 원심의 판결은 정당하므로 원고들의 항소는 기각되어야 할 것입니다.

#### 첨 부 서 류

- |              |    |
|--------------|----|
| 1. 소송위임장     | 1부 |
| 1. 담당변호사 지정서 | 1부 |

20○○. 3. .

위 피항소인(피고)의 소송대리인

법무법인

담당변호사 (인)

서울고등법원

제23민사부

귀중

[답변서와 준비서면] (유류분 반환. 유류분 반환청구권의 소멸시효 도과 항변)  
 (원고가 부동산이 피고 A에게 증여된 사실을 알았다는 자료가 없는 이상, 원고가 유류분의 존재 사실을 모두 알게 된 시점은 협의분할이 이루어진 시점이라고 할 것이므로 이미 본 건 유류분 반환청구권의 소멸시효는 도과하였다는 피고의 항변)<sup>269)</sup>

※ 준비서면은 하단 참조

## 답 변 서

사 건 20〇〇가단20036 유류분 반환

원 고 〇〇연 외 1명

피 고 〇〇연 외 1명

위 사건에 관하여 피고들은 다음과 같이 답변합니다.

### 청구취지에 대한 답변

1. 원고의 청구를 기각한다.
  2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

### 청구원인에 대한 답변

1. 본 건 유류분 반환청구권의 소멸시효는 도과하였음이 역수상 명백합니다.  
 피고 〇〇연의 부 망 〇〇정은 20〇〇. 5. 20. 사망(을 제1호증 〇〇정 제적등본)하였고, 피고 〇〇연의 모 망 〇〇남은 20〇〇. 1. 20. 사망(을 제2호증 〇〇남 기본증명서)하였는데, 망 〇〇남 사망 당시에 피고(을 제3호증 가족관계증명서)는 원고와 함께 상속재산을 모두 협의분할 하여 상속받았기 때문에 원고도 유류분의 존재 사실을 모두 알게 되었습니다.

또한, 원고는 20〇〇. 10. 5.경 피고들에게 유류분 반환청구 최고(을 제4호증 내

269) 한국법률사무자동화(주) 답변서·준비서면프로그램에서 인용(사이트www.lawebook.com/)

용증명 우편)를 하였으나, 그로부터 2년이 경과한 이후에 본 건 소를 제기하였습니다.

따라서, 본 건 유류분 반환청구권의 소멸시효는 도과하였음이 역수상 명백합니다.

2. 피고 ○○자는 ○○도 ○○시 ○○동 12-1 대지의 소유자로 등기한 이후 10년 이상 점유하여 왔습니다.

피고 ○○자는 ○○도 ○○시 ○○동 12-1 대지의 망 ○○남 지분 전부에 대해 20○○. 3. 16. 소유자로 등기한 이후 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의이며 과실 없이 10년 이상 점유(을 제5호증 등기부등본)하여 왔습니다.

위 ○○도 ○○시 ○○동 12-1 대지는 20○○. 4.경부터 시부모님 모시고 함께 일귀오던 부동산으로서 특히, 20○○. 5.경 시아버님이 사망하신 뒤부터는 위 망 ○○남 대신에 경작해 오던 부동산입니다. 그런 이유로 20○○. 3.경 피고 ○○자 명의로 소유권이전등기를 경료한 것입니다.(을 제6호증 피고 진술서)

3. 따라서, 유류분 반환 청구권 소멸시효가 도과한 점이 역수상 명백할 뿐만 아니라, 위 부동산에 대해 시효취득하였으므로 원고의 청구를 기각하여 주시기 바랍니다.

#### 입 증 방 법

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1. 을 제1호증 | 망 ○○정 제적등본  |
| 1. 을 제2호증 | 망 ○○남 기본증명서 |
| 1. 을 제3호증 | 피고 가족관계 증명서 |
| 1. 을 제4호증 | 내용증명 우편     |
| 1. 을 제5호증 | 등기부등본       |
| 1. 을 제6호증 | 진술서         |

#### 첨 부 자 료

- |           |      |
|-----------|------|
| 1. 위 입증방법 | 각 1부 |
|-----------|------|

위 피고 ○○연, ○○자 (인)

○○지방법원 ○○지원 민사5단독

귀중

[준비서면] (위 같은 사건)

준 비 서 면

사 건 20○○가단20036 유류분 반환

원 고 ○○연 외 1명

피 고 ○○연 외 1명

위 당사자 간의 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 준비서면을 제출합니다.

다 음

1. 본 건 유류분 반환청구권의 소멸시효는 도과하였음이 역수상 명백합니다.  
원고는 20○○. 1. 29.경에 이르러 비로소 반환하여야 할 증여 사실을 알았다고 주장하나,  
피고 ○○연의 모 망 ○○남은 20○○. 1. 20. 사망(을 제2호증 ○○남 기본증명서 참조)하였고, 망 ○○남 사망 당시에 이미 피고 ○○자가 망 ○○남으로부터 20○○. 3. 16. 경기도 ○○시 ○○동 12-1 대지의 망 ○○남 지분 전부(이하 '본 건 부동산'이라고 함)에 대해 소유자로 등기한 사실을 알고서 나머지 상속재산을 모두 협의분할(을 제7호증 상속재산 분할협의서 참조)하여 상속받았는데, 망 ○○남 사망당시 망 ○○남의 상속재산을 확인하고 협의 분할하여 상속받은 사실에 대해서는 원고도 인정하고 있는 바 이는 피고의 이익으로 원용하고자 합니다.  
위와 같이 망 ○○남 사망당시에 협의분할 과정에서 원고도 유류분의 존재 사실을 모두 알게 되었음에도 불구하고, 원고는 5년이 경과한 20○○. 10. 5.경 피고들에게 유류분 반환청구 최고(을 제4호증 내용증명 우편 참조)를 하였던 바, 원

고들의 주장에 의하더라도 2000. 10. 5.경 피고들에게 유류분 반환청구 최고를 할 당시에 이미 피고 00자가 망 00남으로부터 본 건 부동산을 이전받은 사실을 충분히 알고 있었다고 할 것입니다.

따라서, 원고가 2000. 1. 29.경에 이르러 비로소 본 건 부동산이 피고 00자에게 증여된 사실을 알았다는 자료가 없는 이상, 원고가 유류분의 존재 사실을 모두 알게 된 시점은 망 00남 사망 이후 협의분할이 이루어진 시점이라고 할 것이므로 이미 본 건 유류분 반환청구권의 소멸시효는 도과하였음이 역수상 명백합니다.

2. 피고 00자가 증여 받은 본 건 부동산이 피고 00연의 특별수익자는 경기도 00시 00동 12-1 대지의 망 00남 지분 전부(이하 '본 건 부동산'이라고 함)에 대하여 근로의 대가로 받은 것이지 증여받은 것이 아닙니다.

본 건 부동산은 1900. 4.경부터 시부모님 모시고 함께 일궈오던 부동산으로서 특히, 1900. 5.경 시아버님이 사망하신 뒤부터는 위 망 00남 대신에 경작해 오던 부동산이었습니다.

피고 00자는 1900. 6.경부터 본 건 부동산을 경작하여 왔기 때문에 그 동안의 근로의 대가를 매매대금으로 산정하여 2000. 3. 16. 매매를 원인으로 망 00남으로부터 그 소유권을 이전받은 것이지 증여 받은 것이 아닙니다.

3. 가사, 증여라고 하더라도, 본 건 부동산은 상속 개시 1년 전의 증여로서 유류분 산정에 산입될 재산이라고 보기 어렵습니다.

공동상속인이 아닌 제3자에 대한 증여는 원칙적으로 상속개시 전의 1년간에 행한 것에 한하여 유류분 반환청구를 할 수 있고, 다만 당사자 쌍방이 증여 당시에 유류분 권리자에 손해를 가할 것을 알고 증여를 한 때에는 상속개시 1년 전에 행한 것에 대하여도 유류분반환청구가 허용된다. 증여 당시 법정상속분의 2분의 1을 유류분으로 갖는 직계비속들이 공동상속인으로서 유류분권리자가 되리라고 예상할 수 있는 경우에, 제3자에 대한 증여가 유류분권리자에게 손해를 가할 것을 알고 행해진 것이라고 보기 위해서는, 당사자 쌍방이 증여 당시 증여재산의 가액이 증여하고 남은 재산의 가액을 초과한다는 점을 알았던 사정뿐만 아니라, 장래 상속개시일에 이르기까지 피상속인의 재산이 증가하지 않으리라는 점까지 예견하고 증여를 행한 사정이 인정되어야 하고, 이러한 당사자 쌍방의 가



해의 인식은 증여 당시를 기준으로 판단하여야 합니다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010다50809 판결)

원고들도 인정하는 바와 같이 본 건 부동산의 가액은 원고와 피고 ○○연이 상속받은 나머지 상속재산의 가액보다 현저히 낮은 점, 본 건 부동산은 망 ○○남이 그 동안 근로의 대가로 피고 ○○자에게 소유권을 이전하여 준 점 등에 비추어 당사자 쌍방이 증여 당시에 유류분 권리자에 손해를 가할 것을 알고 증여하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 입증할만한 자료도 없습니다.

4. 따라서, 위에서 살펴 본 바와 같이 원고의 주장은 이유가 없으므로 원고의 청구를 기각하여 주시기 바랍니다.

#### 첨 부 서 류

○ 소송 위임장

1부

20○○. 2. .

위 피고의 소송대리인 법무법인 ○○

담당변호사 ○○재 (인)

○○지방법원 ○○지원 민사5단독

귀중

#### [준비서면] (위 같은 사건)

#### 준 비 서 면

사 건 20○○단20036 유류분 반환

원 고 ○○연 외 1명

피 고 ○○연 외 1명

위 당사자 간의 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 준비서면을 제출합니다.

## 다 음

### 1. 피고 ○○자 소유 본 건 부동산의 등기이전 사실 인식 여부

(1) 20○○. 1. 20. 사망한 망 ○○남(을 제2호증 ○○남 기본증명서 참조)은 19○○. 7. 11. 남편(원고와 피고 ○○연의 부) 망 ○○정 소유인 경기 ○○시 ○○동 12 소재 대지 지분 596분의 459를 협의분할에 의한 상속을 원인으로 등기이전 경료(을 제9호증 등기부등본)하였기 때문에 원고와 피고 모두 망 ○○남이 위 대지를 상속받은 사실을 인식하고 있었다고 봄이 합리적이라고 할 것입니다.

(2) 따라서, 그 이후 망 ○○남 사망 당시에 망 ○○남의 상속재산을 모두 협의분할(을 제7호증 상속재산 분할협의서 참조)하였기 때문에 그 과정에서 위와 같이 망 ○○남이 19○○. 7. 11. 상속받은 위 ○○동 12 소재 대지의 존재 및 피고 ○○자가 망 ○○남으로부터 20○○. 3. 16. 경기도 ○○시 ○○동 12-1 대지의 망 ○○남 지분 전부에 대해 소유자로 등기한 사실에 대해서 원고들이 인식하고 있었다고 할 것입니다.

### 2. 원고와 피고 ○○연의 상속재산 분할협의 경위

(1) 피고 ○○연은 자신 소유의 토지를 농협에 담보(을 제10호증 ○○동 60-4 번지 등기사항증명서)하여 원고 ○○연 및 소외 ○○연(원고 ○○연의 딸)에게 20○○년도에 5,000만원, 20○○년도에 3,000만원을 대여<sup>270)</sup>한 바 있습니다. 빌려간 뒤(○○연, 3개월에 한번 85만원 이자부담)

(2) 피고 ○○연이 20○○년 경기 ○○시 ○○동 52번지“답”(을 제11호증 ○○동 52번지 등기사항증명서) 을 6,200만원에 매매하자, 피고 ○○연은 소문을 듣고 재차 위 ○○연을 보내 사업이 어렵다는 구실로 현금 3,000만원을 빌려간 사실이 있습니다.

(3) 피고 ○○분은 피고 ○○연이 마련해준 마을 인접 양어장 및 사택에 24년째 거주하고 있으며, 피고 ○○연의 토지에 농사를 지으며 살고 있는 중인데, 19○

270) 원리금 중 지금까지 이자 85만원을 지급받은 게 전부입니다.

○년 피고 ○○연으로부터 현금 8,000만원을 빌려<sup>271)</sup> 서울 ○○구 ○○동에 차녀 ○○주의 명의로 빌라를 구입한 바 있습니다.

(4) 위와 같이 원고 ○○연은 피고 ○○연에게 1억1,000만원의 채무를, 원고 ○○분은 피고 ○○연에게 8,000만원의 채무를 부담하고 있었기 때문에 망 ○○남 사망 당시에 상속재산 분할협의서(을 제7호증 참조)와 같이 망 ○○남의 상속재산을 모두 협의분할한 것입니다.

(5) 따라서, 원고는 아래 표 1.와 같이 유류분 부족분이라 주장하나, 위와 같은 당사자간 채무관계를 고려한 상속재산 분할협의 내용은 아래 표 2.와 같다고 할 것인데,

표 1. 원고주장 유류분

| 상속인          | 상속재산가액      | 유류분산정액         | 유류분부족액(원)      |
|--------------|-------------|----------------|----------------|
| (1) 피고(1)○○연 | 377,034,000 | (-)233,750,000 | (+)143,284,000 |
| (2) 원고(1)○○연 | 217,360,000 | (-)233,750,000 | (-)16,390,000  |
| (3) 원고(2)○○분 | 64,780,000  | (-)233,750,000 | (-)168,970,000 |

표 2. 채무관계 반영한 분할협의 내용

| 상속인         | 상속재산가액      | 채무액         | 상속재산가액(원)   | 상속자산      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| (1)피고(1)○○연 | 377,034,000 | -           | 377,034,000 | 고향집과 도로   |
| (2)원고(1)○○연 | 217,360,000 | 110,000,000 | 327,360,000 | 개발보상예정 토지 |
| (3)원고(2)○○분 | 64,780,000  | 80,000,000  | 144,780,000 | 개발보상예정토지  |

상속분할협의 당시에 원고와 피고간의 위 채무관계 및 향후 개발이익 등을 고려하여, 부모를 장기간 부양한 큰형인 피고 ○○연은 고향집과 그 앞 도로(○○동 9 소재 대지 및 9-1 소재 도로)를, 둘째인 원고 ○○연은 공익사업 보상예정(도로)인 ○○동 9-3 소재 대지 (현 9-3 ,9-6번지 분할)를, 막내인 원고 ○○

271) 현재까지 원리금을 전혀 변제받지 못하고 있습니다.

분은 공익사업 보상예정(도로)인 ○○동 9-5 소재 대지를 각각 나누어 갖기로 합의하게 된 것입니다.

3. 가사, 증여라고 하더라도, 본 건 부동산은 상속 개시 1년 전의 증여로서 유류분 산정에 산입될 재산이라고 보기 어렵습니다.

공동상속인이 아닌 제3자에 대한 증여는 원칙적으로 상속개시 전의 1년간에 행한 것에 한하여 유류분 반환청구를 할 수 있고, 다만 당사자 쌍방이 증여 당시에 유류분 권리자에 손해를 가할 것을 알고 증여를 한 때에는 상속개시 1년 전에 한 것에 대하여도 유류분반환청구가 허용됩니다. 증여 당시 법정상속분의 2분의 1을 유류분으로 갖는 직계비속들이 공동상속인으로서 유류분권리자가 되리라고 예상할 수 있는 경우에, 제3자에 대한 증여가 유류분권리자에게 손해를 가할 것을 알고 행해진 것이라고 보기 위해서는, 당사자 쌍방이 증여 당시 증여재산의 가액이 증여하고 남은 재산의 가액을 초과한다는 점을 알았던 사정뿐만 아니라, 장래 상속개시일에 이르기까지 피상속인의 재산이 증가하지 않으리라는 점까지 예견하고 증여를 행한 사정이 인정되어야 하고, 이러한 당사자 쌍방의 가해의 인식은 증여 당시를 기준으로 판단하여야 합니다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010다50809 판결)

원고들도 인정하는 바와 같이 20○○. 3. 8. 기준 본 건 부동산의 가액 공시지가 기준 7억43,330,000원인데 반하여, 나머지 상속재산 가액은 907,034,000원(상속받은 재산 가액 659,174,000원 및 ○○아에 대한 수증재산<sup>272)</sup> 247,860,000원)이므로 원고와 피고 ○○연이 상속받은 나머지 상속재산의 가액보다 낮은 점, 본 건 부동산은 망 ○○남이 그 동안 근로의 대가로 피고 ○○자에게 소유권을 이전하여 준 점 등에 비추어 당사자 쌍방이 증여 당시에 유류분 권리자에 손해를 가할 것을 알고 증여하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 입증할만한 자료도 없습니다.

4. 따라서, 위에서 살펴 본 바와 같이 원고의 주장은 이유가 없으므로 원고의 청구를 기각하여 주시기 바랍니다.

272) 증여일이 20○○. 12. 15. 이므로 본 건 부동산에 대한 ○○자의 등기이전일 20○○. 3. 8. 당시는 망 ○○남의 재산이었음

## 입 증 방 법

- 을 제 9호증 등기부등본
- 을 제 10호증 등기부등본
- 을 제 11호증 등기부등본

## 첨 부 서 류

- 위 입증방법 각 1부

2000. 5. .

위 피고의 소송대리인 법무법인 ○○

담당변호사 ○○재 (인)

○○지방법원 ○○지원 민사5단독

귀중

[답변서와 준비서면](유류분 반환. 유류분제도의 반환청구대상, 사전증여 등)  
 (사전 증여받은 부동산매매대금으로서 유류분 재산액에 포함되어서는 안된다는 원고의  
 주장, 위 부동산매매대금은 위 유류분 재산액에 포함시켜야 한다는 피고의 항변)<sup>273)</sup>

※ 준비서면은 하단 참조

## 답 변 서

사 건 : 2000가합6556 유류분 반환

원 고 : ○○순 외 4명

피 고 : ○○화 외 1명

위 사건에 관하여 피고 소송대리인은 다음과 같이 답변합니다.

청구취지에 대한 답변

273) 한국법률사무자동화(주) 답변서·준비서면프로그램에서 인용(사이트www.lawebook.com/)

1. 원고의 청구를 기각한다.
  2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

#### 청구원인에 대한 답변

1. 유증 재산목록 중 별지목록 1 기재 부동산은 유류분 산정 재산에서 제외되어야 합니다.

별지목록1 부동산은 대지이고, 별지목록2 부동산은 위 별지목록1 지상의 단독주택인 바, 개별주택은 건물 및 그 부속 토지를 포함한다고 할 것이므로 별지목록2 주택 가격에는 그 주택이 소재한 대지 가격이 포함되어 있어서 별지목록1 부동산은 유류분 산정 재산에서 제외되어야 합니다.

2. 소장 2.의 마.항 기재 현금증여 141,833,374원은 유류분 산정 재산에서 제외되어야 합니다.

피고 ○○화는 망 ○○관으로부터 소장 2.의 마.항 기재와 같이 현금을 증여받은 바 없고, 망 ○○관의 예금은 모두 망 ○○관의 의사에 따라 인출되어 병원비, 간병비, 약값 등으로 사용되었습니다.

원고 ○○미는 20○○. 3. 21. ○○병원에서 망 ○○관으로부터 현금 50만원을 교부받은 바 있는 점에 비추어 보더라도 피고 ○○화가 망 ○○관의 현금을 모두 사용하였다고 보기 어렵습니다.

3. 원고의 <피고 ○○화가 일정한 직업 없이 망 ○○관의 경제력에 기대어 거주함을 기화로 망 ○○관으로부터 상당한 유증을 받았다는 주장>에 대하여

○ 피고 ○○화는 처 ○○순과 이혼하면서 원고 소유인 ○○시 ○○구 ○○동 아파트를 매매(을 제1호증 아파트 등기부등본)하고 남은 금액과 ○○시 ○○동 건물을 매매(을 제2호증 건물 등기부등본)한 대금으로 망 ○○관을 부양하여 왔습니다.

또한, 피고 ○○화는 20○○. 9.경부터 서울 ○○구 ○○동에서 단란주점을 운영 중에 있고(을 제3호증 사업자등록증명), 20○○. 11.경부터는 ○○시 ○○동에서 공인중개사 사무소를 운영하면서(을 제4호증 사업자등록증명) 망 ○○

관을 부양하여 왔기 때문에 피고 ○○화가 일정한 직업 없이 망 ○○관의 경제력에 기대어 거주함을 기화로 망 ○○관으로부터 상당한 유증을 받았다는 주장은 믿기 어렵다고 할 것입니다.

4. 피고 ○○철에 대한 유류분 산정에 있어서도 이상에서 살펴본 바와 같이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 재산정해야 할 것입니다.

#### 5. 결론

이상과 같이 피고 ○○화, 피고 ○○철에 대한 별지목록 1 부동산 및 피고 ○○화에 대한 현금 증여재산부분은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에서 제외되어야 하므로 이 부분에 대한 원고의 청구는 이유 없다고 할 것이므로 원고의 청구는 기각되어야 합니다.

#### 입 증 방 법

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 을 제1호증 | 아파트 등기부등본 |
| 1. 을 제2호증 | 건물 등기부등본  |
| 1. 을 제3호증 | 사업자등록증    |
| 1. 을 제4호증 | 사업자등록증    |

#### 첨 부 서 류

- |           |      |
|-----------|------|
| 1. 위 입증방법 | 각 1통 |
| 1. 소송위임장  | 1부   |

20○○. 6. 7.

위 피고 소송대리인

법무법인 ○○ 담당변호사 ○○재(인)

○○지방법원 ○○지원 제1민사부

귀중

[준비서면] (위 같은 사건)

준 비 서 면

사    건    20〇〇가합6556        유류분 반환  
원    고    〇〇순 외 4명  
피    고    〇〇화 외 1명

위 당사자 간의 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 준비서면을 제출합니다.

- 다        음 -

1. 유류분 산정의 기초가 되는 재산액 중 피고 〇〇화에 대한 현금 증여에 대하여 피고 〇〇화는 결혼 전부터 거의 매주 부모님을 찾아뵈었고, 해소기침이 발병한 어머니의 병을 치료하고자 수 십 년을 혼자 병원에 모시고 다녔으며, 20〇〇. 2. 경 전입하여 약 3년간은 일주일에 2~3일씩 부모님과 함께 지내다가 어머니 이 세상을 떠나신 20〇〇년 1월까지 약4년 동안은 부모님을 모시고 살았습니다.(을 제5호증 피고 〇〇화 주민등록초본)  
또한, 피고 〇〇화는 20〇〇. 4.경부터 농사일도 혼자서 했습니다.(을 제6호증 농지원부)

그리고, 20〇〇. 1.경부터 망 〇〇성 및 원고 〇〇호가 홀로되신 망 〇〇관을 모시기를 거부하여 셋째인 피고 〇〇화가 5년2개월간 병약한 아버님을 모시게 되었습니다. 원고 〇〇호는 20〇〇년경부터 약1년 동안 한 번도 아버님 자택을 오지 않았고, 〇〇순 및 〇〇미는 2~3개월에 한 번씩 1~2시간 정도 머무르다가 돌아간 게 전부입니다.

20〇〇. 1.경부터 망 〇〇관이 돌아가실 때까지 망 〇〇관의 병원 치료비는 물론 모든 장례절차와 비용을 피고 〇〇화가 집행했습니다. 원고들에게 접수된 부의금은 전액 원고들에게 되돌려 주었습니다.

따라서, 망 〇〇관의 계좌에서 인출된 현금은 망 〇〇관의 의사에 따라 망 〇〇



관에 대한 병원비, 간병비 등 용도로 사용한 것이지 증여한 것은 아니라고 할 것이므로 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에서 제외되어야 할 것입니다.

2. 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 재산은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 합니다.

○ 망 ○○관은 19○○년대 말경 ○○시 ○○동 373번지에 거주하는 망 ○○수로부터 ○○시 ○○동 1398번지(2,856㎡)(을 제7호증 폐쇄등기부증명서)를 매입하여 19○○. 12. 20. 망 ○○성 명의로 명의신탁하여 소유권이전등기를 경료하였습니다.

최초 매입당시 망 ○○성은 초등학생이었고, 매매잔금은 어머니의 오빠인 망 ○○종씨로부터 차용하여 지불하였다고 부모님으로부터 수회 들어 알고 있습니다.

또한, 위 ○○동 1398번지 2,856㎡는 20○○년에 매도할 때까지 망 ○○관이 직접 점유하여 사용하였습니다. 답으로 있던 토지를 19○○. 1.경 망 ○○관이 공사대금 일금 팔백만원을 투자하여 답을 매립해서 전으로 지목을 변경하였습니다(을 제9호증 토지대장).

그 후 망 ○○관은 19○○. 7. 15. 외사촌인 ○○연씨 명의로 명의신탁 하였다가 20○○. 11. 30. 매도하여(을 제8호증 토지 등기부등본) 그 매매대금을 망 ○○성에게(상속자 : ○○순, ○○은) 전액 사전증여하였습니다.

따라서, 망 ○○성은 망 ○○관이 ○○연 명의로 명의신탁한 위 토지 매매대금을 증여받은 것이므로 이를 사전증여로 인정하여 유류분에 포함시켜야 할 것입니다.

### 3. 입증방법

○○시 ○○동 1398번지 명의신탁 및 매매대금 증여 관련하여 ○○연을 증인으로 신청합니다.

#### 입 증 방 법

- |           |               |
|-----------|---------------|
| 1. 을 제5호증 | 피고 ○○화 주민등록초본 |
| 1. 을 제6호증 | 농지원부          |
| 1. 을 제7호증 | 폐쇄등기부증명서      |

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1. 을 제8호증 | 토지 등기부등본 |
| 1. 을 제9호증 | 토지대장     |

첨 부 서 류

1. 위 입증방법 1부

20〇〇. 9. .  
피고의 소송대리인  
변호사 〇〇재(인)

〇〇지방법원 〇〇지원 제1민사부 귀중

[준비서면] (위 같은 사건)

준 비 서 면

사 건 20〇〇가합6556 유류분 반환  
원 고 〇〇순 외 4명  
피 고 〇〇화 외 1명

위 당사자 간의 사건에 관하여 피고 〇〇철의 소송대리인은 다음과 같이 준비서면을 제출합니다.

- 다 음 -

1. 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 원고 〇〇순, 원고 〇〇은이 〇〇지방법원 〇〇지원 20〇〇가단24000 소유권이전등기 소송 판결로 취득한 부동산도 포함시켜야 합니다.

피고 〇〇철은 〇〇시 〇〇동 561의 4 대지 246평방미터 및 〇〇시 군자동 561의 8 도로 25평방미터를 유증받았으나(갑 제5호증 참조), 〇〇지방법원 〇〇지원 20〇〇가단24000 소유권이전등기 소송 판결(을 제10호증 판결문)로 인해

원고 ○○순에게 위 부동산 중 5분의 2지분, 원고 ○○은에게 위 부동산 중 15분의 4 지분이 각 이전되었습니다.

그러므로, 원고 ○○순은 위 부동산 중 원고 ○○순의 유류분을 제외한 5분이 1지분을, 원고 ○○은은 위 부동산 중 원고 ○○은의 유류분을 제외한 15분이 2지분을 피고 ○○철에게 이전하여야 할 것입니다.

따라서, 위 부동산 중 ○○지방법원○○지원 20○○가단24000 소유권이전등기 소송 판결로 인해 원고 ○○순 및 원고 ○○은에게 이전등기가 경료된 지분은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 할 것입니다.

입 증 방 법

1. 을 제10호증

판결문

첨 부 서 류

1. 위 입증방법

1부

20○○. 11. .

피고의 소송대리인 변호사 ○○재(인)

○○지방법원 ○○지원 제1민사부

귀중

[준비서면] (위 같은 사건)

준 비 서 면

사 건 20○○가합6556 유류분 반환  
원 고 ○○순 외 4명  
피 고 ○○화 외 1명

위 당사자 간의 사건에 관하여 피고들의 소송대리인은 다음과 같이 준비서면을 제출합니다.

- 다 음 -

1. 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 합니다.

망 ○○관은 자신의 소유인 ○○시 ○○동 1398번지 2,856㎡에 대해 19○○. 7. 15. 외사촌인 ○○연씨 명의로 명의신탁 하였다가 20○○. 11. 30. 매도한 (을 제11호증 토지 매매계약서) 후, 그 매매대금 9억300만원을 망 ○○성에게 (상속자 : ○○순, ○○은) 전액 사전 증여하였습니다(을 제12호증 확인서). 따라서, 망 ○○성은 망 ○○관이 위 ○○연 명의로 명의신탁한 위 토지를 매도한 매매대금을 증여받은 것이므로 이를 사전증여로 인정하여 증여액 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 할 것입니다.

입 증 방 법

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. 을 제11호증 | 토지 매매계약서   |
| 1. 을 제12호증 | ○○연 작성 확인서 |

첨 부 서 류

- |           |    |
|-----------|----|
| 1. 위 입증방법 | 1부 |
|-----------|----|

20○○. 12. .  
피고의 소송대리인  
법무법인 ○○, 담당변호사 ○○재(인)

○○지방법원 ○○지원 제1민사부 귀중

[준비서면] (위 같은 사건)

준 비 서 면

|   |   |            |        |
|---|---|------------|--------|
| 사 | 건 | 20○○가합6556 | 유류분 반환 |
| 원 | 고 | ○○순 외 4명   |        |

피 고 ○○화 외 1명

위 당사자 간의 사건에 관하여 피고들의 소송대리인은 다음과 같이 준비서면을 제출합니다.

- 다 음 -

1. 망 ○○관이 자신의 소유인 ○○시 ○○동 1398번지 2,856㎡에 대해 19○○.

12. 20. 망 ○○성에게 증여하였다는 주장에 대하여

원고는 망 ○○관이 자신의 소유인 ○○시 ○○동 1398번지 2,856㎡에 대해 19○○. 12. 20. 망 ○○성에게 증여하였으므로 유류분 제도의 반환청구 대상이 되지 아니한다고 주장합니다.

그러나, 피고 ○○화가 갑 제25호증 확인서에서 19○○. 12. 20. 사전증여라고 표기한 것은 명의신탁과 증여를 구분하지 못한 상태에서 망 ○○성 명의로 소유권이전등기가 경료 되었기 때문에 증여라고 생각하고 표기한 것뿐입니다.

가사, 원고의 주장과 같이 사전증여라고 하더라도, 19○○. 7. 15. 망 ○○성에 대한 증여를 해제하여 매매를 원인으로 하여 외사촌인 ○○연 명의로 소유권이전등기를 경료하는 방법으로 명의신탁해 두었다가 20○○. 11. 30. 매도한(을 제11호증 토지 매매계약서 참조) 후, 그 매매대금 9억300만원을 망 ○○성에게(상속자 : ○○순, ○○은) 전액 사전 증여한 것입니다(을 제12호증 확인서).

## 2. 결 론

따라서, 망 ○○성은 망 ○○관이 위 ○○연 명의로 명의신탁한 위 토지를 매도한 매매대금을 증여받은 것이므로 이를 사전증여로 인정하여 증여액 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 할 것입니다.

20○○. 1. .

피고의 소송대리인

법무법인 ○○, 담당변호사 ○○재(인)

○○지방법원 ○○지원 제1민사부

귀중

[답변서와 준비서면](유류분반환. 청구금액보다 더 많은 금액을 반환하겠다고  
피고들은 주장하였으나 원고들은 이를 배척하고, 다시 본건 소를 제기)  
(원고들이 다시 본건 소를 제기한 이유는 이해관계가 충돌하는 당사자들이 공모하여  
동일한 소송대리인으로 하여금 동일한 주장을 하도록 한 후에 재판부의 판단여하에 따라  
자신들에게 유리한 결과를 선택하는 방법으로 소송절차를 악용한 것으로서 신의성실의  
원칙을 위배한 권리남용이고, 위 다른 사건 유류분 반환소송 확정판결의 기판력이 본  
건에 미친다는 피고의 항변)<sup>274)</sup>

※ 항소심 준비서면은 하단 참조

## 답 변 서

사 건 : 20○○가합7037 유류분 반환

원 고 : ○○호 외 2명

피 고 : ○○화 외 1명

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 답변합니다.

### 청구취지에 대한 답변

1. 원고들의 청구를 기각한다.
  2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

### 청구원인에 대한 답변

1. 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송의 내용과 판결  
가. 원고들은 피고들을 상대로 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 원고  
들이 산정한 유류분액 전부를 주장하였습니다.  
원고들은 20○○. 4. 28. 피고들을 상대로 유류분 반환의 소를 제기하면서 피  
고들이 유증 받은 부동산 전부(갑 제1호증의 1~9 참조), 망 ○○관 명의 예금

274) 한국법률사무자동화(주) 답변서·준비서면프로그램에서 인용(사이트www.lawebook.com/)

채권 및 피고 ○○화에 대한 현금 증여액 전부를 유류분 산정의 기초가 되는 재산액으로 특정하였고, 소장 말미에 괄호를 사용하여 “추후 망 ○○관의 증여 재산 등에 대하여 감정평가 등을 거쳐 정확한 가액을 파악한 다음 청구취지를 확장할 계획입니다”라고 명시한 바 있습니다(을 제1호증, 원고 제출 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송 소장)

즉, 원고들은 귀원의 위 20○○가합6556 사건 소 제기시에 유류분 산정의 기초가 되는 재산 전부를 파악하여 소를 제기하였고, 다만, 소장 말미에서 망 ○○관의 증여재산 등에 대한 추후 정확한 가액을 파악한 다음 청구취지를 확장할 계획임을 밝혔을 뿐이며, 그에 따라 아래 1.의 다.항에서 후술하는 바와 같이 20○○. 12. 11. 청구취지를 확장하여 변경한 바 있습니다.

따라서, 원고들은 귀원의 위 20○○가합6556 사건 소를 제기를 하면서 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 아니하였다고 할 것입니다.

나. 피고들은 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다고 주장하였습니다.

피고들은 귀원의 위 20○○가합6556 사건에서 20○○. 9. 27.자 및 20○○. 12. 15.자 준비서면을 통해 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다고 주장한 바 있습니다(을 제2호증, 피고의 20○○. 9. 27.자 및 12. 15.자 준비서면). 이에 대하여, 원고들은 위 현금 9억300만원은 원래 망 ○○성이 20○○. 12. 20. 사전 증여받은 경기 ○○시 ○○동 1398 전 2,856평방미터의 매매대금으로서 유류분 재산액에 포함되어서는 아니 된다는 주장만을 하였습니다(을 제3호증, 원고의 20○○. 1. 11.자 준비서면).

다. 원고들의 유류분액에 대한 청구취지 확장

원고들은 귀원의 위 20○○가합6556 사건에서 20○○. 12. 11. 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출하였는데, 피고들이 주장한 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함하여 계산한 것이 아니라 원고들이 최초로 계산한 유류분 산정의 기초가 되는 재산액 합계 금 1,572,603,674원에서 최초

소장(을 제1호증 참조) 별지 목록 기재 3, 4 부동산을 제외한 나머지 부동산의 감정평가 결과까지 종합한 다음 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 합계 금 1,950,413,174원으로 하여 원고들의 유류분액을 계산한 후 청구취지를 확장하여 유류분 전부를 청구(을 제4호증 청구취지 및 청구원인 변경신청서)하였습니다.

원고들이 제출한 위 20○○. 12. 11. 청구취지 및 청구원인 변경신청서에서는 유류분 전액을 청구하였을 뿐이고, 더 이상 유류분 일부 청구 취지임을 명시한 바 없음을 알 수 있습니다.

#### 라. 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송의 판결

원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 20○○. 4. 26. <원고들에게 피고 ○○화는 각 108,845,265원, 피고 ○○철은 각 53,689,167원을 지급하라>는 승소판결을 받아(갑 제2호증의 1 판결문 참조) 쌍방 항소를 포기하여 20○○. 5. 15. 확정(갑 제2호증의 2 확정증명원)된 바 있습니다.

위 판결은 피고들의 주장을 받아들여 즉 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜 산출하였고 원고들이 청구한 유류분 반환금액보다 많았지만 원고들이 청구한 금액한도 내에서 판결이 선고되었습니다.

#### 마. 원고들의 항소포기

원고들은 판결문을 수령하여 원고들이 청구한 금액보다 많다는 사실을 알았고, 따라서 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위하여 항소를 제기할 이익이 있음에도 항소를 제기하지 않았습니다.

### 2. 귀원 위 20○○가합6556 사건 확정판결의 기판력이 본 건 소 제기에 미치는지 여부

#### 가. 판례의 태도

가분채권의 일부에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 나머지를 유보하고 일부



만을 청구한다는 취지를 명시하지 아니한 이상 그 확정판결의 기판력은 청구하고 남은 잔부청구에까지 미치는 것이므로 그 나머지 부분을 별도로 다시 청구할 수 없고, 전소의 사실심 변론종결 당시까지 소유권이전을 소구할 수 있는 공유지분의 범위를 정확히 알 수 없어 결과적으로 전소에서 일부 공유지분에 관한 청구를 하지 못하게 되었다 할지라도 이를 일부청구임을 명시한 경우와 마찬가지로 취급하여 전소의 확정판결의 기판력이 그 잔부청구에 미친다는 것이 판례의 태도입니다(대법원 1993. 6. 25. 선고 92다33008호 판결 등).

나. 이 사건의 경우 원고들이 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시했는지 여부

원고들은 처음부터 귀원 20○○가합6556 유류분 반환 소송을 하면서 원고들이 주장하는 금원 전부를 청구하였습니다.

피고들이 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다고 주장한 바, 만약 피고들의 주장이 받아들여진다면 원고들에게 돌아가는 금원이 더 많아지는 것을 알면서도 예비적 청구 등 아무런 조치를 하지 않았습니다.

원고들은 위 20○○가합6556 사건에서 20○○. 12. 11. 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출하였는데 당시에는 위와 같이 피고들이 이미 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다는 주장을 하였음에도 불구하고 원고들이 주장하고 원고들이 계산한 유류분 전부만 청구하고, 청구취지 확장 신청서 그 어디에서도 유류분 일부청구 취지를 명시한 바 없습니다(을 제4호증 청구취지 및 청구원인 변경신청서 참조)

원고들은 청구취지 금원을 확장함에 있어 증여재산을 파악하고 감정평가 결과까지 종합하여 유류분 전부를 청구하였습니다.

이처럼 원고들은 귀원의 위 20○○가합6556 사건 소송의 사실심 변론종결 당시까지 유류분 전액을 청구하였고, 이는 유류분액의 범위를 전부를 예상하고 청구

하였는데, 그 이유는 당시 위 20○○가합6556 사건의 원고는 현재 원고들 뿐만 아니라 망 ○○성의 처 ○○순 및 자녀 ○○은도 원고이어서 피고들의 주장대로 현금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함되어 유류분이 계산된다면 위 20○○가합6556 사건의 원고 ○○호, ○○순, ○○미에 대한 유류분 반환액은 증가하나, 위 ○○순과 ○○은의 유류분은 부족액이 없어서 소를 취하할 수 밖에 없는 상황이었기 때문입니다. 즉, 원고 대리인은 위 20○○가합6556 사건의 원고 ○○호, ○○순, ○○미, ○○순, ○○은을 모두 대리하는 바람에 위 ○○호, ○○순, ○○미와 위 ○○순, ○○은의 이해가 충돌되는 상황에 이르렀기 때문에 피고들 주장의 현금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함된 사실을 충분히 알면서도 조치를 취하지 아니한 채 유류분 전부를 청구한 것이므로 추후에 다시 위 ○○호, ○○순, ○○미의 부족분에 대해 본 건 소를 제기하는 것은 권리의 남용에 해당한다고 할 것입니다.

| 유류<br>분<br>원고 | 원고청구(사전증여액 9억3백만원 미포함)에 따른 피고들의 지급예정액 |             | 사전증여액 9억3백만원 포함에 따른 피고들의 지급예정액 |             | 판결에 따른 지급액   |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|               | ○○화                                   | ○○철         | ○○화                            | ○○철         | ○○화          | ○○철         |
| ○○순           | 65,307,159                            | 32,213,500  | 0                              | 0           | 0            | 0           |
| ○○은           | 43,538,106                            | 21,475,667  | 0                              | 0           | 0            | 0           |
| ○○호           | 108,845,265                           | 53,689,167  | 159,119,080                    | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| ○○순           | 108,845,265                           | 53,689,167  | 159,119,080                    | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| ○○미           | 108,845,265                           | 53,689,167  | 159,119,080                    | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| 합계            | 435,381,060                           | 214,756,668 | 477,357,240                    | 218,153,805 | 326,535,795  | 161,067,501 |
| 총 합계          | 650,137,728원                          |             | 695,511,045원                   |             | 487,603,296원 |             |

더 나아가 판결이 선고되어 피고들의 주장대로 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함되어 계산된 바, 원고들은 판결문을 수령하여 원고들이 청구한 금액보다 많다는 사실을 알았고, 따라서 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위하여 항소를 제기할 이익이 있음에도 불구하고 위 ○○호, ○○순, ○○미와 위 ○○순, ○○은의 이해가 충돌되는 상황 때문에 항소를 제기하지 못한 것입니다.

다. 소 결

가분채권에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 그것이 나머지 부분을 유보하고 일

부만 청구하는 것이라는 취지를 명시하지 아니한 경우에는 그 확정판결의 기판력은 나머지 부분에까지 미치는 것이어서 별도로써 나머지 부분에 관하여 다시 청구할 수는 없습니다.

가사 일부 청구에 관하여 전부 승소한 원고들이 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위한 항소가 예외적으로 허용되므로 전부 승소한 판결에 대해서도 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위한 항소를 제기해야 하는데 포기함으로써 전소송의 확정판결의 기판력이 이 사건 잔부청구에 미친다고 할 것입니다. 이와 같이 귀원 20○○가합6556 유류분 반환 소송의 변론 전 취지를 살펴보아도 원고들은 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 않고 전부 청구한 사실이 명백합니다.

### 3. 결 론

원고들은 피고들을 상대로 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송을 제기하면서 유류분 전부에 대한 소를 제기하여 전부 승소 판결을 받았고, 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위한 항소를 제기해야 하는데 항소를 포기하여 소송이 확정된 바, 그 확정판결의 기판력이 미치므로 본 건 소는 기각되어야 합니다.

#### 입 증 방 법

- |               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 1. 을 제1호증     | 원고 제출 귀원 20○○가합6556 유류분반환 소장            |
| 1. 을 제2호증의1~2 | 피고의 20○○. 9. 27.자 및 20○○. 12. 15.자 준비서면 |
| 1. 을 제3호증     | 원고의 20○○. 1. 11.자 준비서면                  |
| 1. 을 제4호증     | 원고의 청구취지 및 청구원인 변경신청서                   |

#### 첨 부 서 류

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 위 입증방법           | 각 1부 |
| 1. 소송위임장 및 담당변호사지정서 | 각 1부 |

20○○. 7. .

위 피고들의 소송대리인 법무법인 ○○

[준비서면] (위 같은 사건)

준 비 서 면

사 건 : 20○○가합7037(20○○머4176) 유류분 반환

원 고 : ○○호 외 2명

피 고 : ○○화 외 1명

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다 음

1. 유류분 사건에서 유류분 산정의 기초가 되는 재산은 증여 또는 유증받은 특정 당사자를 불문하고 유류분 사건의 당사자 모두에게 적용되는 재산입니다.

원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 원고들일부인 소외 ○○순, ○○은이 피고들과 본 건 망 ○○성에 대한 증여액 9억 300만원의 증여 사실을 다투었기 때문에 원고들은 위 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산에서 제외하고 나머지 재산만을 상대로 유류분 청구를 하였다고 주장합니다.

그러나, 유류분 산정의 기초가 되는 재산은 증여 또는 유증받은 특정 당사자를 불문하고 유류분 사건의 당사자 모두에게 적용되는 재산입니다.

위 9억300만원의 증여 여부는 위 ○○순, ○○은 및 피고들 사이에서만 다툼이 있었던 사안이 아니라, 귀원 20○○가합6556 유류분 사건 당사자 7명 모두에게 적용되는 사안이었습니다. 왜냐하면, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되는지 여부에 따라 원고 및 피고들의 유류분액이 달라지기 때문입니다. 즉, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되면 소외 ○○순, ○○은의 유류분 반환액은 줄어드나, 원고들의 유류분 반환액은 늘어나기 때문입니다.

2. 원고들은 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 “망 ○○성에 대한 증여액 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되면 유류분액이 증가하는” 원고들에게 유리한 주장을 포기하였습니다.

원고들은 귀원의 위 20○○가합6556 사건에서 20○○. 12. 11. 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출하였는데, 피고들이 주장한 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함하여 계산하지 아니하였습니다.(을 제4호 증 청구취지 및 청구원인 변경신청서 참조).

즉, 귀원의 20○○가합6556 사건 원고 중 위 ○○순, ○○은은 피고들이 주장한 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시키면 유류분액이 감소하므로 포함하지 아니한 것은 당연하나, 피고들이 주장한 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시키면 유류분액이 증가하는 원고들이 이를 주장하지 아니한 것은 납득하기 어렵다고 할 것입니다.

원고들은 위 9억300만원의 증여 여부에 대해 수수방관할 것이 아니라 적극적으로 위 9억300만원이 증여에 해당하여 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다고 주장하였어야 함에도 불구하고, 귀원 20○○가합6556 유류분 사건의 원고들 사이의 이해가 상충되는 사안에 대하여 소외 ○○순 및 ○○은과 함께 동일한 대리인을 선임하여 소를 제기하는 바람에 주장을 하지 못한 것이기 때문에 위 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함시킬 수 있는 권리 또는 주장을 포기한 것이라고 할 것입니다.

이와 관련하여 원고의 20○○. 7. 24.자 준비서면에서 <원고 ○○순, ○○은과 피고들 사이에 ○○동 토지의 매매대금을 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함시켜야 하는지를 놓고 사실관계에 대한 다툼을 하고 있었기 때문에 나머지 원고들(이 사건 원고들)은 피고들을 상대로 유류분 청구를 함에 있어서 일응 명시적으로 ○○동 토지매매대금 상당을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에서 제외시키고 나머지 대상재산만을 상대로 유류분 청구를 하였습니다>라는 주장(준비서면 3쪽 두 번째 단락)은 위 9억300만원의 존재를 알고도 유류분 청구 대상재산에서 제외하였다는 취지로서 피고들의 이익으로 원용하고자 합니다.

즉, 원고들은 위 9억300만원의 증여 주장이 받아들여지면 원고들의 유류분액이 증가하므로 예비적으로 이를 주장하였어야 함에도 불구하고 소이 ○○순, ○○은과의 관계 때문에 이를 포기한 것입니다.

3. 원고들은 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송 판결문을 통해 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 사실을 알면서도 항소를 포기하였습니다.

원고들은 판결문을 수령하여 원고들이 청구한 금액보다 많다는 사실을 알았고, 따라서 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위하여 항소를 제기할 이익이 있음에도 항소를 제기하지 않았습니다.

따라서, 원고들은 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 사실을 알면서도 청구취지 확장을 위한 항소를 포기하였는 바, 본 건 소 제기는 권리남용에 해당한다고 할 것입니다.

4. 원고들은 일부청구임을 명시한 바도 없습니다.

원고들은 위 ○○동 토지매매대금 9억300만원을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에서 제외시키고 나머지 대상재산만을 상대로 유류분 청구를 하였기 때문에 일부청구라고 주장합니다.

그러나, 위 ○○동 토지매매대금 9억300만원을 추후에 청구한다는 사실을 명시적으로 밝힌 바도 없고, 일부러 위 9억300만원을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에서 제외한다는 명시적인 표현도 없는 점에 비추어 위 9억300만원을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에서 제외시킨 사실만으로는 일부청구를 명시하였다고 보기 어렵다고 할 것입니다.

왜냐하면, 원고의 주장대로 한다면 <가분채권에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 그것이 나머지 부분을 유보하고 일부만 청구하는 것이라는 취지를 명시하지 아니한 경우에는 그 확정판결의 기판력은 나머지 부분에까지 미치는 것이어서 별소로써 나머지 부분에 관하여 다시 청구할 수는 없다>는 판례의 태도와는 달리 오히려 일부청구임을 명시하지 않은 채 일부만을 주장한 모든 청구가 일부

청구에 해당한다는 모순적인 결론(예를 들어, 100만원 청구가 가능한데 70만원만 청구한 사안에서, 현재 판례는 100만원까지 청구가능하나 일부인 70만원만 청구하고 나머지는 추후 청구하겠다는 명시적인 의사를 표시하여야만 일부청구가 인정되나, 원고 주장대로 한다면 명시적으로 30만원을 제외한 채 70만원을 청구하였으니 당연히 나머지 청구가 가능하다는 결론에 이르게 됩니다)에 이르게 될 것이기 때문입니다.

### 5. 결 론

원고들은 피고들을 상대로 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송 과정에서 ① “망 ○○성에 대한 증여액 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되면 유류분액이 증가한다” 는 원고들에게 유리한 주장을 포기하였고, ② 귀원 20○○가합6556 유류분 반환 소송의 변론 전 취지를 살펴보아도 원고들은 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 않고 전부 청구한 사실이 명백하며, ③ 망 ○○성에 대한 증여액 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 판결을 받았음에도 불구하고, 청구를 확장하기 위한 항소를 포기하여 소송이 확정된 바, 그 확정판결의 기판력이 미치므로 본 건소는 기각되어야 합니다.

20○○. 7. .

위 피고들의 소송대리인 법무법인 ○○  
담당변호사 ○○재 (인)

○○지방법원 ○○지원 제1민사부

귀중

### [준비서면] (위 같은 사건)

#### 준 비 서 면

사 건 : 20○○가합7037(20○○머4176) 유류분 반환

원 고 : ○○호 외 2명

피 고 : ○○화 외 1명

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

## 다 음

1. 원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 원고들에게 유리한 피고들의 <망 ○○성에 대한 ○○동 토지매매대금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 주장>을 받아들이지 아니하였으므로 본 건 소 제기는 권리남용 또는 신의칙에 위반된다고 할 것입니다.

원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 원고들일부인 소외 ○○순, ○○은이 피고들과 본 건 망 ○○성에 대한 증여액 9억300만원의 증여 사실을 다투었고, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산이 되어야 하는지는 확정된 바 없었기 때문에 원고들은 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되어야 하는 여부를 알지 못하였다고 주장합니다.

그러나, 원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 아래 사진 6부에서 보는 바와 같이 20○○. 10. 11.자 준비서면 및 20○○. 1. 11.자 준비서면(을 제5호증의 1~2 준비서면)을 통해 원고들도 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산이 되어야 하는지에 대해 충분히 다투었음을 알 수 있습니다.

원고들 주장대로 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산이 되어야 하는지에 대해 다투지 않았다거나 위 ○○순 및 ○○은만 다투었다면 준비서면에서 그 의사를 표시하였어야 하는데도 불구하고 위 준비서면 2부(을 제5호증의 1~2 참조)를 보면 모두 현재 본 건 소의 원고들을 포함한 “원고들”이라고 특정하였을 뿐이고, “원고 ○○순, 원고 ○○은”이라고 특정한 적이 없습니다.

특히, 원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 피고들이 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함시켜야 한다고 주장하였는 바, 피고들의 주장대로 한다면 원고들의 유류분액이 증가하여 반



환액이 증가하므로 피고들의 주장을 원고들의 이익으로 원용하면 그만인데도 불구하고 그 권리 또는 주장마저 하지 아니한 채 포기하였으므로 이제와서 본 건 소를 제기하는 것은 권리남용 또는 신의칙에 반한다고 할 것입니다.

원고들이 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 피고들의 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함시켜야 한다는 주장을 원고들의 이익으로 원용하면 피고들이 귀원 20○○가합6556 유류분 반환 사건의 원고들에게 반환하여야 유류분 반환 총액은 원고들이 청구액 합계 650,137,728원보다 많은 695,511,045원이 됨에도 불구하고(20○○. 7. 19.자답변서 8쪽 참조)이를 원용하지 아니한 단 한가지 이유는 원고들이 원고 ○○순, ○○은과 공모하여 피고들로부터 유류분을 반환받기로 하였는데, 위 주장을 받아들이면 원고 ○○순, ○○은이 반환받아야 할 유류분 반환액은 “0”가 되기 때문입니다.

2. 원고들은 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송 판결문을 통해 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 사실을 알면서도 항소를 포기하였습니다.

위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되어야 한다는 사실은 전소판결이 위 ○○순과 ○○은 및 피고들이 항소를 하지 아니하여 확정됨으로써 비로소 원고들과 피고들과 사이의 유류분 청구의 소에서 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되어야 한다는 사실이 확정되었기 때문에 그 이전에는 원고들은 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되어야 하는 여부를 알지 못하였다고 주장합니다.

그러나, 원고들은 당시 귀원 20○○가합6556 유류분 사건에서 피고들의 준비서면을 담당 변호사를 통해 모두 송달받아 그 내용을 자세히 알고 있었고, 특히, 원고 ○○호는 소송대리인과는 별도로 20○○. 5. 9. 열람 및 복사신청을 통해 위 사건 판결문을 직접 교부받아(을 제6호증 대법원 사건검색내역) 그 내용을 모두 알고 있으면서도 스스로 항소를 포기한 것입니다.

즉, 원고들은 판결문을 수령하여 원고들이 청구한 금액보다 많다는 사실을 알았고, 따라서 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위하여 항소를 제기할 이익이 있음에도 항소를 제기하지 않았습니다(원고들의 주장대로 한다면 판결확정되기 전에는 사실관계를 확정적으로 알 수가 없는 것이므로 항소제도는 있을 수가 없습니다).

따라서, 원고들은 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 사실을 알면서도 청구취지 확장을 위한 항소를 포기하였는 바, 본 건 소 제기는 권리남용에 해당한다고 할 것입니다.

3. 유류분 사건에서 유류분 산정의 기초가 되는 재산은 증여 또는 유증받은 특정 당사자를 불문하고 유류분 사건의 당사자 모두에게 적용되는 재산입니다.

원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 원고들일부인 소외 ○○순, ○○은이 피고들과 본 건 망 ○○성에 대한 증여액 9억300만원의 증여 사실을 다투었고, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산이 되어야 하는지는 확정된 바 없었기 때문에 원고들은 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되어야 하는 여부를 알지 못하였다고 주장합니다.

그러나, 유류분 산정의 기초가 되는 재산은 증여 또는 유증받은 특정 당사자를 불문하고 유류분 사건의 당사자 모두에게 적용되는 재산인 바, 위 9억300만원의 증여 여부는 위 ○○순, ○○은 및 피고들 사이에서만 다툼이 있었던 사안이 아니라, 귀원 20○○가합6556 유류분 사건 당사자 7명 모두에게 적용되는 사안이었습니다. 왜냐하면, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되는지 여부에 따라 원고 및 피고들의 유류분액이 달라지기 때문입니다. 즉, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되면 소외 ○○순, ○○은의 유류분 반환액은 줄어드나, 원고들의 유류분 반환액은 늘어나기 때문입니다.

따라서, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되어야 한다

는 사실에 대해서 판결이 확정되지 아니하여 몰랐다는 원고들의 주장은 믿기 어렵다고 할 것입니다.

#### 4. 원고들은 일부청구임을 명시한 바도 없습니다.

원고들은 전소의 진행결과에 따라 위 ○○동 토지매매대금 9억300만원을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에 포함시킨 유류분 반환 청구 의사를 유보하였으므로 일부청구라고 주장합니다.

그러나, 위 ○○동 토지매매대금 9억300만원을 추후에 청구한다는 사실을 명시적으로 밝힌 바도 없고, 위 준비서면(을 제5호증의 1~2)에서도 일부러 위 9억300만원을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에서 제외한다는 명시적인 표현도 없는 점에 비추어 위 ○○동 토지매매대금 9억300만원을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에 포함시킨 유류분 반환 청구 의사를 유보하였다고 보기 어렵다고 할 것입니다.

#### 5. 결 론

원고들은 피고들을 상대로 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송 과정에서 ① “망 ○○성에 대한 증여액 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되면 유류분액이 증가한다” 는 원고들에게 유리한 피고들의 주장을 원용하지 아니하여 포기하였고, ② 귀원 20○○가합6556 유류분 반환 소송의 변론 전 취지를 살펴보아도 원고들은 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 않고 전부 청구한 사실이 명백하며, ③ 망 ○○성에 대한 증여액 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 판결을 받았음에도 불구하고, 청구를 확장하기 위한 항소를 포기하여 소송이 확정된 바, 그 확정판결의 기판력이 미치므로 본 건 소는 기각되어야 합니다.

#### 입 증 방 법

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. 을 제5호증의 1~2 | 준비서면 2부    |
| 1. 을 제6호증      | 대법원 사건검색내역 |

#### 첨 부 서 류

1. 위 입증방법

각 1부

20〇〇. 7. .

위 피고들의 소송대리인 법무법인 〇〇

담당변호사 〇〇재 (인)

〇〇지방법원 〇〇지원 제1민사부

귀중

[준비서면] (위 같은 사건)

준 비 서 면

사 건 : 20〇〇가합7037(20〇〇머4176) 유류분 반환

원 고 : 〇〇호 외 2명

피 고 : 〇〇화 외 1명

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다 음

1. 원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20〇〇가합6556 소송이 확정됨으로써 <망 〇〇성에 대한 〇〇동 토지매매대금 9억300만원이 증여되었다는 사실을 알았고, 그 사실이 유류분을 침해하여 반환청구를 할 수 있게 됨을 알게 되었다>고 주장합니다.

원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20〇〇가합6556 유류분 반환소송이 확정됨으로써 <망 〇〇성에 대한 〇〇동 토지매매대금 9억300만원이 증여되었다는 사실을 알았고, 그 사실이 유류분을 침해하여 반환청구를 할 수 있게 됨을 알게 되었다>고 주장합니다.

그러나, 원고들이 근거로 제시한 대법원 93다52563호 판결은 <유류분권리자가

수증자와의 재판과정에서 수증자의 증여주장 및 그에 부합하는 증언의 존재를 알았다는 것만으로는 증여사실을 알았다고 할 수 없다는 취지>의 판결인 바, 위 판결은 수증자가 피상속인을 승계한 유류분권리자를 상대로 한 소유권이전 등기 소송의 판시사항으로서 본 건과는 쟁점이 다르므로 위 판결을 본 건에 곧바로 적용하기는 어렵다고 할 것입니다.

왜냐하면, 본 건은 피고들이 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송의 기판력 및 원고들의 권리남용을 다투는 사안인 반면에 위 대법원 93다52563호 판결은 수증자가 유류분권리자의 유류분반환청구권이 소멸시효로 도과되었다는 쟁점에 관한 것이기 때문입니다.

참고로, 피고들은 원고들의 본 건 유류분반환청구권 소멸시효 도과 주장을 한 바 없습니다.

또한, 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 피고들의 위 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다는 주장은 원고들에게 100% 절대적으로 유리한 주장이었므로 원고들이 위와 같은 피고들의 주장을 원고들의 이익으로 원용하여 청구취지 및 청구원인을 확장변경였다면 당사자 사이에 다툼이 없는 사실로 정리될 사안이었음에 비추어 위 유류분 소송이 확정되기 전이어서 위 9억300만원을 유류분 재산에 포함시켜 유류분반환청구를 할 수 없었다는 원고들의 주장은 납득하기 어렵습니다.

원고들의 주장대로 한다면 확정판결에 기한 사실관계 특정 전에는 아무것도 할 수 없으므로 민사소송에서의 예비적 청구취지 및 청구원인은 존재할 수 없다고 할 것입니다.

2. 원고들은 피고들을 상대로 한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 유류분 반환의무자인 피고들의 <망 ○○성에 대한 ○○동 토지매매대금 9억300만원은 증여되었으므로 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다>는 주장을 배척한 바 있습니다.

- (1) 원고들에게 유리한 피고들의 주장을 배척하고 권리를 포기

원고들이 소외 ○○순 및 ○○은과 함께 피고들을 상대로 제기한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 피고들은 망 ○○성에 대한 증여액 9억300만원의 증여를 인정하면서 원고들의 청구금액보다 더 많은 금액을 반환하겠다고 주장 하였으나 원고들은 그 사실을 충분히 알면서도 이를 받아들이지 아니하고 배척 하였습니다(을 제5호증의 1~2 준비서면 참조).

원고들이 당시 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 피고들의 <망 ○○ 성에 대한 ○○동 토지매매대금 9억300만원 증여 주장>을 받아들이고 청구취 지를 확장하였다면 아래 표에서 보시는 바와 같이 원고들과 함께 소를 제기한 소외 ○○순, ○○은의 유류분 부족액은 없어서 반환받을 유류분액은 없게 되는 반면에 원고들이 반환받을 금액은 증가하므로 원고들은 피고 ○○화로부터 50,273,815원씩을, 피고 ○○철로부터 19,028,768원씩을 더 반환받을 수 있었 음에도 불구하고 피고들의 주장을 원고들의 이익으로 원용하지도 아니한 채 그 권리를 스스로 포기하였고, 더 나아가 적극적으로 배척하였습니다.

단위 : 원

| 유류<br>분<br>원고 | 원고청구(사전증여액 9억3<br>백만원 미포함)에 따른 피고<br>들의 지급예정액 |             | 사전증여액 9억3백만원 포함<br>에 따른 피고들의 지급예정<br>액 |             | 판결에 따른 지급액   |             |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|               | ○○화                                           | ○○철         | ○○화                                    | ○○철         | ○○화          | ○○철         |
| ○○순           | 65,307,159                                    | 32,213,500  | 0                                      | 0           | 0            | 0           |
| ○○은           | 43,538,106                                    | 21,475,667  | 0                                      | 0           | 0            | 0           |
| ○○호           | 108,845,265                                   | 53,689,167  | 159,119,080                            | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| ○○순           | 108,845,265                                   | 53,689,167  | 159,119,080                            | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| ○○미           | 108,845,265                                   | 53,689,167  | 159,119,080                            | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| 합계            | 435,381,060                                   | 214,756,668 | 477,357,240                            | 218,153,805 | 326,535,795  | 161,067,501 |
| 총 합계          | 650,137,728원                                  |             | 695,511,045원                           |             | 487,603,296원 |             |

(2) 이해관계가 충돌하는 당사자들이 공모하여 동일한 소송대리인으로 하여금 동일한 주장을 하도록 하는 방법으로 소송절차를 악용

위 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 원고들이 피고들의 <망 ○○성 에 대한 ○○동 토지매매대금 9억300만원 증여 주장>을 받아들여 청구취지를 확장하였다면 위와 같이 이익이 될 뿐만 아니라 본 건과 같은 추가적인 소 제기 가 필요 없다는 사실을 잘 알고 있음에도 불구하고 피고들의 증여주장을 배척한 이유는 피고들의 주장을 받아들일 경우에는 당시 원고들과 함께 소를 제기한

소의 ○○순, ○○은이 반환받을 유류분이 위 표에서 보는 바와 같이 0원이 되기 때문이라고 할 것입니다.

즉, 원고들은 위 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서는 일단 피고들의 증여주장을 부인하여 증여부인 주장이 받아들여질 경우에는 원고들의 유류분 청구액 뿐 만 아니라 소의 ○○순, ○○은의 유류분반환액을 보장받고, 만약에 원고들의 증여부인 주장이 받아들여지지 아니할 경우에는 추후에 원고들만 별도로 본 건과 같은 유류분반환청구의 소를 제기하여 원고들의 유류분반환액을 확보하려는 꾀수를 사용하였다고 할 것입니다.

이는 위 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송의 원고들 중 현재 본 건 소의 원고들과 위 ○○순 및 ○○은의 이해관계가 충돌됨에도 불구하고 동일한 소송대리인이 소송수행을 하면서 동일한 주장을 한 불가피한 결과라고 할 것입니다.

### (3) 소 결

따라서, 원고들이 위 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 원고들에게 절대적으로 유리한 피고들의 주장을 알면서도 원고들의 이익으로 원용하지 아니한 채 배척하고서도 다시 본 건 소를 제기한 것은 이해관계가 충돌하는 당사자들이 공모하여 동일한 소송대리인으로 하여금 동일한 주장을 하도록 한 후에 재판부의 판단여하에 따라 자신들에게 유리한 결과를 선택하는 방법으로 소송절차를 악용한 것으로서 신의성실의 원칙을 위배한 권리남용이라고 할 것입니다.

### 3. 결 론

따라서, 원고들이 피고들을 상대로 제기한 귀원 20○○가합6556 유류분 반환소송 확정판결의 기판력이 본 건에 미치고, 본 건은 권리남용에 해당하므로 본 건 소는 기각되어야 합니다.

20○○. 8. .

위 피고들의 소송대리인 법무법인 ○○

담당변호사 ○○재 (인)

[항소심 답변서] (위 같은 사건)

답 변 서

사            건    20○○나2008298    유류분 반환

항 소 인(원고)    ○○호 외 2명

피항소인(피고)    ○○화 외 1명

위 당사자간 사건에 관하여 피항소인의 소송대리인은 다음과 같이 답변서를 제출합니다.

- 다       음 -

1. 기초 사실

(1) 피항소인들(이하 ‘피고들’이라고 함)은 ○○지방법원 ○○지원의 20○○가합6556 유류분 반환 사건에서 20○○. 9. 27.자 및 20○○. 12. 15.자 준비서면을 통해 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다고 주장한 바 있습니다(을 제2호증, 피고의 20○○. 9. 27.자 및 12. 15.자 준비서면 참조)

(2) 반면에, 항소인들(이하 ‘원고들’이라고 함)은 위 ○○지원 20○○가합6556 사건에서 20○○. 12. 11. 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출하였는데, 피고들이 주장한 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시키지 아니하였습니다(을 제4호증 청구취지 및 청구원인 변경신청서 참조)

(3) 또한, 원고들은 위 현금 9억300만원은 원래 망 ○○성이 20○○. 12. 20. 사전 증여받은 경기 ○○시 ○○동 1398 전 2,856평방미터의 매매대금으로서 유류분 재산액에 포함되어서는 아니된다고 주장하였습니다(을 제3호증, 원고의 20○○. 1. 11.자 준비서면 참조).

위 준비서면을 보면 모두 현재 본 건 소의 원고들을 포함한 “원고들”이라고 특정하였을 뿐이고, “원고 ○○순, 원고 ○○은”이라고 특정한 적이 없는 점에 비



추어 원고들도 위 ○○성의 증여금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되면 원고들에게 유리하다는 사실을 충분히 알면서도 위 ○○순 및 ○○은을 위해 위 ○○성의 증여금 9억300만원이 유류분 재산액에 포함되어서는 아니된다고 주장하였다고 할 것입니다.

(4) 위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 피고들의 주장을 받아들여 즉, 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜 산출하였고 원고들이 청구한 유류분 반환금액보다 많았지만 원고들이 청구한 금액한도 내에서 판결이 선고되었고, (갑 제2호증의 1 판결문 참조) 쌍방 항소를 포기하여 20○○. 5. 15. 확정 (갑 제2호증의 2 확정증명원)된 바 있습니다.

## 2. 피고들의 주장

(1) 원고들은 위 ○○지원 20○○가합6556 사건에서 원고들에게 유리한 피고들의 <망 ○○성에 대한 ○○동 토지매매대금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 주장>을 받아들이지 아니하였습니다.

(2) 위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서 피고들의 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함시켜야 한다는 주장을 원고들의 이익으로 원용하면 아래 표와 같이 피고들이 원고들에게 반환하여야 유류분 반환 총액은 원고들의 청구액 합계(650,137,728원)보다 많은 695,511,045원이 됨에도 불구하고, 이를 원용하지 아니한 이유는 원고들이 소외 ○○순, ○○은과 공모하여 피고들로부터 유류분을 반환받기로 하였는데, 위 주장을 받아들이면 위 ○○순, ○○은이 반환받아야 할 유류분 반환액이 “0원”이 되기 때문이었다고 할 것입니다.

| 유류<br>분<br>원고 | 원고청구(사전증여액 9억3<br>백만원 미포함)에 따른 피고<br>들의 지급예정액 |             | 사전증여액 9억3백만원 포함<br>에 따른 피고들의 지급예정<br>액 |             | 판결에 따른 지급액   |             |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|               | ○○화                                           | ○○철         | ○○화                                    | ○○철         | ○○화          | ○○철         |
| ○○순           | 65,307,159                                    | 32,213,500  | 0                                      | 0           | 0            | 0           |
| ○○은           | 43,538,106                                    | 21,475,667  | 0                                      | 0           | 0            | 0           |
| ○○호           | 108,845,265                                   | 53,689,167  | 159,119,080                            | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| ○○순           | 108,845,265                                   | 53,689,167  | 159,119,080                            | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| ○○미           | 108,845,265                                   | 53,689,167  | 159,119,080                            | 72,717,935  | 108,845,265  | 53,689,167  |
| 합계            | 435,381,060                                   | 214,756,668 | 477,357,240                            | 218,153,805 | 326,535,795  | 161,067,501 |
| 총 합계          | 650,137,728원                                  |             | 695,511,045원                           |             | 487,603,296원 |             |

즉, 원고들은 위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환소송에서는 일단 피고들의 증여주장을 부인하여 증여부인 주장이 받아들여질 경우에는 원고들의 유류분 청구액 뿐 만 아니라 소외 ○○순, ○○은의 유류분반환액을 보장받고, 만약에 원고들의 증여부인 주장이 받아들여지지 아니할 경우에는 추후에 원고들만 별도로 본 건과 같은 유류분반환청구의 소를 제기하여 원고들의 유류분반환액을 확보하려는 꾀수를 사용하였다고 할 것입니다.

이는 위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환소송의 원고들 중 현재 본 건소의 원고들과 위 ○○순 및 ○○은의 이해관계가 충돌됨에도 불구하고 동일한 소송대리인이 소송수행을 하면서 동일한 주장을 한 불가피한 결과라고 할 것인바, 이해관계가 충돌하는 당사자들이 공모하여 동일한 소송대리인으로 하여금 동일한 주장을 하도록 한 후에 재판부의 판단여하에 따라 자신들에게 유리한 결과를 선택하는 방법으로 소송절차를 악용한 것으로서 신의성실의 원칙을 위배한 권리남용이라고 할 것입니다.

(3) 원고들은 위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환소송 판결문을 통해 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 사실을 알면서도 청구취지 확장 등을 위한 항소를 포기하였습니다.

(4) 따라서, 위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환 사건 진행과정을 통하여 원고들은 원고들에게 유리한 피고들의 <망 ○○성에 대한 ○○동 토지매매대금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 주장>을 배척

한 바 있고, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 사실을 알면서도 청구취지 확장 등을 위한 항소를 포기하였음에도 불구하고, 다시 이 사건 소를 제기하여 위 ○○성 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함하여야 함을 주장하면서 잔존 유류분 반환을 구하는 것은 소송절차를 악용한 것으로서 권리남용 내지는 신의성실의 원칙에 위배된다고 할 것입니다.

### 3. 원고들의 항소이유에 대한 반박

원고들은 피고들의 주장대로 본 건 ○○동 토지 매매대금이 ○○성에 대한 증여금이라고 인정되든지, 혹은, 원고들 주장대로 위 ○○동 토지를 증여받은 것으로 인정되든지 여부와 관계없이 피고들의 경제적인 차이는 크게 없을 뿐만 아니라, 피고들의 항소실익도 없다고 주장합니다.

그러나, 피고들로서는 위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환 사건 소송진행 경과를 지켜보면서 원고들이 피고들의 주장을 원용하면 원고들의 청구를 인락함으로써 피고들이 원고들에게 반환하여야 할 유류분 반환 총액은 본 건 ○○동 토지 매매대금이 ○○성에 대한 증여금이라고 인정되는 경우의 695,511,045원보다 적은 650,137,728원(원고들의 청구액 합계)이 되므로 약 4,500만원을 감액시킬 수 있었고,

위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환 사건 원심 판결과 같이 판결이 확정되면 피고들이 원고들에게 반환하여야 할 유류분 반환 총액은 487,603,296원에 불과할 뿐만 아니라, 만약에 원고들이 위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환 사건의 원심 판결에 대해 항소하게 되면 항소심에서 원고들의 청구를 인락함으로써 위와 같이 본 건 ○○동 토지 매매대금이 ○○성에 대한 증여금이라고 인정되는 경우의 695,511,045원보다 적은 650,137,728원(원고들의 청구액 합계)이 되므로 약 4,500만원을 감액시킬 수 있었다고 할 것입니다.

위와 같이 원고들이 피고들의 <본 건 ○○동 토지 매매대금이 ○○성에 대한 증여금>이라는 주장을 원용하는지 여부에 따라 청구 인락 및 항소포기 등의 방법으로 소송에 대응함으로써 청구 인용금액을 감액하거나 본 건과 같은 다른

소송을 제기당하지 않을 수 있었는 바, 피고들은 위 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환 사건에서 원고들의 적극적인 주장을 신뢰하여 청구 인락의 기회도 갖지 못한 채 항소 포기에 이르렀고, 본 건 소를 제기당한 것입니다.

따라서, 본 건 ○○동 토지 매매대금이 ○○성에 대한 증여금이라는 피고들의 주장으로 인한 피고들의 경제적인 차이가 크게 없고, 피고들의 항소실익도 없다는 원고들의 주장은 설득력이 없다고 할 것입니다.

#### 4. 원심의 판단 및 이에 대한 의견

원고들과 ○○순, ○○은이 귀원 20○○가합6556 유류분 반환 소송에서 피고들로부터 <망 ○○성에 대한 ○○동 토지매매대금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 주장>이 담긴 20○○. 9. 27.자 준비서면을 송달받은 이후에 청구취지를 변경하였으나 ○○성 증여금을 유류분 산정의 기초가 되는 재산으로 산입하여 청구취지를 변경하지 않았을 뿐만 아니라, 오히려 적극적으로 위 ○○성 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜서는 아니된다고 주장하였고, 피고들은 귀원 20○○가합6556 유류분 반환 소송 경과 및 내용을 종합적으로 고려하여 항소를 포기한 것으로 판시하였습니다.

따라서, 원고들의 본 건 소제기는 신의성실의 원칙상 허용되지 않는다는 피고들의 주장을 받아들여 원고들의 청구를 각하한 원심의 판결은 정당하므로 원고들의 항소는 기각되어야 할 것입니다.

#### 첨 부 서 류

- |              |    |
|--------------|----|
| 1. 소송위임장     | 1부 |
| 1. 담당변호사 지정서 | 1부 |

20○○. 3. .

위 피항소인(피고)의 소송대리인 법무법인 ○○  
담당변호사 ○○재 (인)

## [항소심 준비서면] (위 같은 사건)

## 준 비 서 면

사 건 : 20○○나2008298 유류분 반환

원 고 : ○○호 외 2명

피 고 : ○○화 외 1명

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

## 다 음

## 1. 기관력에 관한 원심판결의 요지와 사실오인 및 법리오인

## (1) 기관력에 관한 원심판결의 요지

피고들은 원심에서 이 사건 소송에 선행 소송인 ○○지방법원 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환 소송(이하 ‘선행 소송’이라고 합니다)의 기관력이 미친다>고 주장하였습니다.

그러나, 원심은 <유류분반환청구권의 행사는 재판상 또는 재판 외에서 상대방에 대한 의사표시의 방법으로 할 수 있고, 이 경우 그 의사표시는 침해를 받은 유증 또는 증여행위를 지정하여 이에 대한 반환청구의 의사를 표시하면 그것으로 족하며, 그로 인하여 생긴 목적물의 이전등기청구권이나 인도청구권 등을 행사하는 것과는 달리 그 목적물을 구체적으로 특정하여야 하는 것은 아니라 할 것인 바, 이러한 법리에 비추면 유류분 반환청구권을 행사한 결과 유류분권자는 수유자 등에 대하여 소유권 등에 기하여 물권적인 인도 혹은 이전등기청구권 혹은 말소등기청구권을 가지게 되는 것인데, 유류분반환의 소송에서 근거가 되는 것은 이러한 물권적인 청구권이므로 결국 개개의 목적물에 대한 청구권만이 소송물이 되게 되고, 기관력도 이에 대하여만 미치게 된다고 봄이 상당하다. 원고들이 선행 소송의 변론종결시까지 ○○성 증여금을 제외한 별지 목록 기재 제1 내지 7항 부동산 및 ○○관 명의의 예금채권만을 유류분 반환의 대상으로 하였던 사실이 인정된다. 따라서 ○○성의 증여금에 관하여 유류분 반환을 구하

는 이 사건 소는 선행 소송과 그 소송물을 달리한다는 이유로 기판력에 관한 피고들의 주장을 배척한 바 있습니다.

## (2) 기판력에 관한 원심판결의 사실 오인

원고들이 20〇〇. 5. 18. 제출한 원심 소송의 소장(소장 6쪽 곁어 참조)에 의하면 “선행 소송에서 부족 되게 청구한 나머지 유류분 반환청구금액의 지급을 구하기 위하여 이 사건 소송을 제기하게 되었습니다”라고 주장하였을 뿐, 별도로 〇〇성의 증여금을 특정하여 유류분 반환을 구한다고 한 바는 없습니다.

즉, 원고는 선행소송에서 유증재산인 부동산 자체에 대한 반환을 청구한 것이 아니라 망 〇〇성에 대한 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시키지 아니한 채 피고들의 유류분 반환범위를 산정한 후 원고들의 유류분 부족액의 반환을 청구하였고, 원심 소송에서도 유증재산인 부동산 자체 또는 증여재산인 증여금 자체에 대한 반환을 청구한 것이 아니라 망 〇〇성에 대한 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜 피고들의 유류분 반환범위를 산정한 후 선행 소송에서 지급받지 못한 원고들의 유류분 부족액의 반환을 청구하는 것인 바, 원심 및 선행 소송 모두 수익자인 피고들을 상대로 한 유류분 부족액 반환 청구라는 금전지급청구 소송이라는 점에서 소송물이 동일하다고 할 것입니다.

또한, 원고들 주장대로 증여금 9억300만원에 대한 유류분 반환 주장을 한 것이 아니라고 한다면 원심에서 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜 유류분을 산정한 것은 잘못이라는 취지로 항소를 제기하였어야 함에도 불구하고 원고들은 항소를 포기한 바 있습니다

그러나, 원심은 원고들의 청구원인을 “망 〇〇관의 망 〇〇성에 대한 증여금에 관하여 유류분 반환을 구한다”는 취지로 오인하였을 뿐만 아니라 최소한 원고들의 항소포기 시점에서는 증여금 9억300만원의 반환 주장도 한 것이라고 판단하여야 함에도 불구하고 이를 간과한 채 선행소송과 이 사건 소송의 소송물이 다르다고 판단한 잘못이 있습니다.

## (3) 기판력에 관한 원심판결의 법리 오인

원심은 원고들이 선행 소송의 변론종결시까지 ○○성 증여금을 제외한 별지 목록 기재 제1 내지 7항 부동산 및 ○○관 명의의 예금채권만을 유류분 반환의 대상으로 하였던 사실이 인정되는 바, ○○성의 증여금에 관하여 유류분 반환을 구하는 이 사건 소는 선행 소송과 그 소송물을 달리한다는 이유로 기판력에 관한 피고들의 주장을 배척한 바 있습니다.

그러나, 원고들은 원심의 선행 소송에서 아래 표와 같이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원을 포함시켜 유류분 반환액을 산정하여야 원고들에게 유리함에도 불구하고 이를 포함시키지 아니하였고, 원심에서는 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원을 포함시켜 유류분 반환액을 산정하는 등 원심 소송과 선행 소송은 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 산정하는 방법만 차이가 있을 뿐이고, 증여금 9억300만원이 쟁점으로 현출되어 선행 소송에서 다루어진 점에 비추어 두 소송 모두 수익자인 피고들을 상대로 한 원고들의 유류분 부족액의 반환을 구하는 소송이라고 할 것입니다.

| 유류분<br>원고 | ○○성에 대한 사전증여액 9억3<br>백만원 미포함한 경우 유류분 반<br>환액(단위, 원) |             | ○○성에 대한 사전증여액<br>9억3백만원 포함한 경우 유류분 반환액<br>(단위, 원)                       |                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|           | ○○화                                                 | ○○철         | ○○화                                                                     | ○○철                                                                     |
| ○○순       | 58,119,124                                          | 29,309,865  | 0                                                                       | 0                                                                       |
| ○○은       | 38,746,082                                          | 19,539,910  | 0                                                                       | 0                                                                       |
| ○○호       | 96,865,207                                          | 48,849,775  | 합계 136,037,908<br>(○○화 부담액<br>98,853,446<br>○○순, ○○은 부담액<br>37,184,462) | 합계 62,169,764<br>(○○철 부담액<br>45,176,345<br>○○순, ○○은 부담액<br>16,993,419원) |
| ○○순       | 96,865,207                                          | 48,849,775  |                                                                         |                                                                         |
| ○○미       | 96,865,207                                          | 48,849,775  |                                                                         |                                                                         |
| 합계        | 387,460,827                                         | 195,399,100 | 408,113,724                                                             | 186,509,292                                                             |
| 총 합계      | 582,859,927원                                        |             | 594,623,016원                                                            |                                                                         |

즉, 증여재산에 대한 유류분 반환 청구가 유증재산에 대한 유류분 반환청구와 다른 소송물이 되는 경우는 유증재산에 대한 유류분 반환청구에서 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 산정함에 있어서 증여재산을 모르거나 증여재산이 발견이 안되어 증여재산을 제외하고 유류분액을 산정할 때 해당되는 경우이고, 본 건과 같이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액을 산정할 때 당사자들의 주장과

증거에 의하여 증여재산을 포함하는 경우에는 증여재산인 증여금 9억300만원이 쟁점으로 현출되어 선행 소송에서 다루어진 점에 비추어 동일한 소송물이라고 할 것입니다.

한편, 유류분 반환순서에 대한 대법원 판례의 태도를 보면 <민법 제1116조에 따라 증여에 대하여는 유증을 반환받은 후가 아니면 이것을 청구할 수 없는 바, 먼저 유증을 받은 자를 상대로 유류분 침해분의 반환을 구하여야 하고 그 이후에도 여전히 유류분 침해분이 남아 있는 경우에 한하여 증여를 받은 자에 대하여 그 부족분을 청구할 수 있다>고 판시하고 있습니다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001다6947 판결 등)

따라서, 민법 제1116조 및 위와 같은 대법원 판례의 태도에 비추어 원고들은 증여재산인 망 ○○관의 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원의 유류분의 반환에 대해서는 피고들을 상대로 소를 제기할 수 없으므로 피고들을 상대로 한 유류분 반환 청구는 당연히 망 ○○관의 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원을 포함하여 산정한 유류분 부족액 범위내에서 유류분의 반환을 청구하는 소송일 수 밖에 없는 바, 원심 사건과 선행소송은 모두 피고들을 상대로 유류분 부족액의 반환을 청구하는 것으로서 그 소송물이 동일하다고 할 것이므로 이 사건 소송에 선행 소송의 기판력이 미친다고 할 것입니다.

가사, 견해를 달리하여, 원심 사건이 선행 소송의 소송물과 달리 망 ○○관의 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원의 유류분 반환을 구하는 소송이라면 피고들은 망 ○○관의 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원의 수증자가 아니므로 당사자적격이 없다고 할 것임에도 불구하고 이를 간과한 채 법리오인으로 인해 판단을 그르친 잘못이 있다고 할 것입니다.

2. 원고들은 선행소송에서 일부청구임을 명시한 바도 없습니다.

(1) 유류분 사건에서 유류분 산정의 기초가 되는 재산은 증여 또는 유증받은 특정 당사자를 불문하고 유류분 사건의 당사자 모두에게 적용되는 재산입니다.

유류분 산정의 기초가 되는 재산은 증여 또는 유증받은 특정 당사자를 불문하고



유류분 사건의 당사자 모두에게 적용되는 재산입니다.

따라서, 위 9억300만원의 증여 여부는 위 ○○순, ○○은 및 피고들 사이에서만 다툼이 있었던 사안이 아니라, 선행소송 당사자 7명 모두에게 적용되는 사안이었습니다. 왜냐하면, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되는지 여부에 따라 원고 및 피고들의 유류분액이 달라지는 바, 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되면 소외 ○○순, ○○은의 유류분 반환액은 줄어드나, 원고들의 유류분 반환액은 늘어나기 때문입니다.

## (2) 원고들의 선행 소송에서의 일부 청구 주장에 대하여

원고들은 피고들을 상대로 한 선행 소송에서 원고들 일부인 소외 ○○순, ○○은만이 피고들과 본 건 망 ○○성에 대한 증여액 9억300만원의 증여 사실을 다투었고, 특히, 위 9억300만원을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에서 제외시키고 나머지 대상 재산만을 상대로 유류분 청구를 하였기 때문에 일부청구라고 주장합니다.

그러나, 위 ○○동 토지매매대금 9억300만원을 추후에 청구한다는 사실을 명시적으로 밝힌 바도 없고, 일부러 위 9억300만원을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에서 제외한다는 명시적인 표현도 없는 점에 비추어 위 9억300만원을 유류분 청구의 기초가 되는 재산에서 제외시킨 사실만으로는 일부청구를 명시하였다고 보기 어렵다고 할 것입니다.

왜냐하면, 원고의 주장대로 한다면 <가분채권에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 그것이 나머지 부분을 유보하고 일부만 청구하는 것이라는 취지를 명시하지 아니한 경우에는 그 확정판결의 기판력은 나머지 부분에까지 미치는 것이어서 별소로써 나머지 부분에 관하여 다시 청구할 수는 없다>는 판례의 태도와는 달리 오히려 일부청구임을 명시하지 않은 채 일부만을 주장한 모든 청구가 일부 청구에 해당한다는 모순적인 결론(예를 들어, 100만원 청구가 가능한데 70만원만 청구한 사안에서, 현재 판례는 100만원까지 청구가능하나 일부인 70만원만 청구하고 나머지는 추후 청구하겠다는 명시적인 의사를 표시하여야만 일부청구가 인정되나, 원고 주장대로 한다면 명시적으로 30만원을 제외한 채 70만원을 청구하였으니 당연히 나머지 청구가 가능하다는 결론에 이르게 됩니다)에

이르게 될 것이기 때문입니다.

오히려, 원고들은 선행 소송에서 아래에서 보는 바와 같이 20〇〇. 1. 11.자 준비서면을 통해 원고들도 위 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산이 되어야 하는지에 대해 충분히 다투었음을 알 수 있습니다.

위 9억300만원을 유류분 산정의 기초재산에 포함하여야 하는지 여부에 대해 다투지 않았거나 위 〇〇순 및 〇〇은만 다투었다면 준비서면에서 그 의사를 표시하였어야 함에도 불구하고 본 건 소의 원고들을 포함한 “원고들”이라고 특정하였을 뿐이고, “원고 〇〇순, 원고 〇〇은”이라고 특정한 적이 없습니다.

### (3) 소 결

원고들은 선행 소송 과정에서 ① 원고들에게 유리한 “망 〇〇성에 대한 증여액 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되면 유류분액이 증가한다”는 피고들의 주장을 위와 같이 적극적으로 배척하였고, ② 선행 소송의 변론 전 취지를 살펴보아도 원고들은 나머지를 유보하고 일부만을 청구한다는 취지를 명시하지 않고 전부 청구한 사실이 명백하며, ③ 망 〇〇성에 대한 증여액 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함된다는 판결을 받았으면, 원고들의 청구취지 및 청구원인과는 다르게 망 〇〇성에 대한 증여액 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되었으니 이를 제외하여 유류분액을 산정하여야 한다고 주장하거나 청구를 확장하기 위하여 항소를 제기하여야 함에도 불구하고 항소를 포기하여 소송이 확정된 점에 비추어 원고들은 선행 소송에서 유류분의 일부 청구를 주장한 바는 없다고 할 것입니다.

### 3. 원고들의 권리남용 또는 신의성실의 원칙 위반

원고들은 선행 소송에서 피고들이 <망 〇〇성이 망 〇〇관으로부터 사전 증여 받은 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜야 한다>고 주장한 사실(을 제2호증, 피고의 20〇〇. 9. 27.자 및 12. 15.자 준비서면 참조)을 알고 있었으므로 이를 원고들의 이익으로 원용하면 위 1.의 (3).항에 있는 표와 같이 원고들의 유류분액 및 피고들의 유류분 반환액이 증가함에도 불구하고, 위 증여금 9억300만원은 원래 망 〇〇성이 1974. 12. 20. 사전 증여

받은 경기 ○○시 ○○동 1398 전 2,856평방미터의 매매대금으로서 유류분 재산액에 포함되어서는 아니 된다는 주장만을 하였을 뿐만 아니라(을 제3호증, 원고의 20○○. 1. 11.자 준비서면 참조), 선행 소송 판결문을 수령하여 망 ○○성이 망 ○○관으로부터 사전 증여받은 현금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜 유류분이 산출된 사실 및 원고들의 유류분 부족액이 원고들이 청구한 금액보다 많다는 사실을 알았기 때문에 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위하여 항소를 제기할 이익이 있음에도 불구하고 항소를 제기하지 않았습니다.

원고들이 선행 소송에서 원고들에게 유리한 피고들의 주장을 받아들이지 아니한 이유는 당시 위 선행 사건의 원고는 현재 원고들과 망 ○○성의 대습상속인인 망 ○○성의 처 ○○순 및 자녀 ○○은이었는데 피고들의 주장대로 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함되어 유류분이 계산된다면 위 ○○순과 ○○은의 유류분 부족액은 0원이 되어 위 ○○순 및 ○○은이 피고들로부터 반환받을 유류분이 없어지기 때문이었습니다.

즉, 선행 소송에서 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함되면 위 ○○순 및 ○○은에게는 손해가 되고, 원고들에게는 이익이 되는 등 원고들과 위 ○○순, ○○은은 서로 이해가 충돌됨에도 불구하고, 원고들은 위 ○○순, ○○은과 동일한 소송대리인을 통해 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함되어서는 아니된다는 동일한 주장(을 제3호증, 원고의 20○○. 1. 11.자 준비서면 참조)을 하였기 때문에 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원이 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함된 사실을 충분히 알면서도 청구취지 변경 등 조치를 취하지 아니하였을 뿐만 아니라 항소조차 제기하지 아니한 것인 바, 추후 다시 원고들의 유류분 부족분에 대해 본 건 소를 제기하는 것은 권리의 남용 내지 신의성실의 원칙에 위배된다고 할 것입니다.

왜냐하면, 피고들은 원고들이 선행 소송에서 당연히 소외 위 ○○순 및 ○○은과의 관계를 고려하여 원고들에게 피고들의 주장을 배척한 것으로 믿을 수 밖에 없었는데, 만약에 원고들이 피고들의 주장을 원용하였다면 ① 위 1.의 (3)항

표에서 보는 바와 같이 망 ○○성에 대한 증여금 주장을 하지 아니할 때 피고들의 유류분 반환액이 적으므로 망 ○○성에 대한 증여금 주장을 철회하거나 원고 청구를 그대로 인락하였을 것이고, ② 또한, 민법 제1116조 및 위와 같은 대법원 판례의 태도를 논거로 “원고들은 증여재산인 망 ○○관의 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원에 대해 피고들을 상대로 소를 제기할 수 없다”는 취지의 당사자적격 문제를 주장하였을 것이기 때문입니다.

또한, 원고들 주장대로 증여금 9억300만원에 대한 유류분 반환 주장을 한 것이 아니거나 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시키지 아니한 채 일부 청구를 한 것이라면 원심에서 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시켜 유류분을 산정한 것은 잘못이라는 취지로 항소를 제기하였어야 함에도 불구하고 원고들이 항소를 포기하였기 때문에 원고들도 원심 판결을 존중한 것으로 믿고 원고들의 소송행위를 신뢰하여 피고들도 항소를 포기한 것입니다.

따라서, 원고들이 선행소송에서 원고들에게 유리한 피고들의 주장을 알면서도 배척하면서 다투었을 뿐만 아니라 항소를 제기할 기회를 스스로 포기하고서도 다시 본 건 소를 제기한 것은 이해관계가 충돌하는 당사자들이 공모하여 동일한 소송대리인으로 하여금 동일한 주장을 하도록 한 후에 재판부의 판단여하에 따라 자신들에게 유리한 결과를 선택하는 방법으로 소송절차를 악용한 것으로서 권리남용에 해당한다고 할 것이고, 피고들은 원고들의 선행소송에서의 주장과 항소 포기 등 소송 과정에서의 피고들의 소송행위를 신뢰<sup>275)</sup>하고 선행 소송의 인용 액수 등을 종합적으로 고려하여 선행 소송의 판결에 대하여 항소를 제기하지 아니한 것이므로 원고들의 본 건 소 제기는 신의성실의 원칙을 위배한 것이라고 할 것입니다.

#### 4. 피고들의 유류분 반환액 범위

##### (1) 유류분 반환범위 및 순서에 관한 판례의 태도

대법원은 <증여 또는 유증을 받은 재산 등의 가액이 자기 고유의 유류분액을

275) 원고들이 큰 형님인 망 ○○성의 대습상속인인 ○○순과 ○○은이 피고들로부터 유류분을 반환받도록 하기 위하여 일부러 증여금 주장을 배척한다고 믿었습니다.

초과하는 수인의 공동상속인이 유류분권리자에게 반환하여야 할 재산과 그 범위를 정함에 있어서, 수인의 공동상속인이 유증받은 재산의 총 가액이 유류분권리자의 유류분 부족액을 초과하는 경우에는 그 유류분 부족액의 범위 내에서 각자의 수유재산을 반환하면 되는 것이지 이를 놓아두고 수증재산을 반환할 것은 아니다. 이 경우 수인의 공동상속인이 유류분권리자의 유류분 부족액을 각자의 수유재산으로 반환함에 있어서 분담하여야 할 액은 각자 증여 또는 유증을 받은 재산 등의 가액이 자기 고유의 유류분액을 초과하는 가액의 비율에 따라 안분하여 정하되, 그중 어느 공동상속인의 수유재산의 가액이 그의 분담액에 미치지 못하여 분담액 부족분이 발생하더라도 이를 그의 수증재산으로 반환할 것이 아니라, 다른 공동상속인들 중 자신의 수유재산의 가액이 자신의 분담액을 초과하는 공동상속인들이 위 분담액 부족분을 위 비율에 따라 다시 안분하여 그들의 수유재산으로 반환하여야 한다고 판시한 바 있고(대법원 2014. 8. 26. 선고 2012다77594 판결),

또한, <민법 제1115조 제1항은 유류분 권리자가 피상속인의 제1114조에 규정된 증여 및 유증으로 인하여 그 유류분에 부족이 생긴 때에는 부족한 한도에서 그 재산의 반환을 청구할 수 있다고 하고, 제2항은 제1항의 경우에 증여 및 유증을 받은 자가 수인인 때에는 각자가 얻은 증여 가액의 비례로 반환하여야 한다고 규정하고 있으므로, 유류분 권리자가 유류분반환 청구를 함에 있어 증여 또는 유증을 받은 다른 공동상속인이 수인일 때에는 민법이 정한 유류분 제도의 목적과 위 제1115조 제2항의 취지에 비추어 다른 공동상속인들 중 각자 증여받은 재산 등의 가액이 자기 고유의 유류분액을 초과하는 상속인만을 상대로 하여 그 유류분액을 초과한 금액의 비율에 따라서 반환청구를 할 수 있다고 하여야 할 것이고(당원 1995. 6. 30. 선고 93다11715 판결), 공동상속인과 공동상속인이 아닌 제3자가 있는 경우에는 그 제3자에게는 유류분이라는 것이 없으므로 공동상속인은 자기 고유의 유류분액을 초과한 금액을 기준으로 하여, 제3자는 그 수증가액을 기준으로 하여 각 그 금액의 비율에 따라 반환청구를 할 수 있다고 판시하고 있습니다(대법원 1996. 2. 9. 선고 95다17885 판결)

## (2) 피고들의 유류분 반환범위

선형소송 판결에 의하면 망 ○○관의 상속인 중 유류분 반환의무자는 망 ○○

관으로부터 유증을 받은 피고들 및 망 ○○관으로부터 사전 증여를 받은 망 ○○성의 대습상속인 소외 ○○순과 ○○은인 바, 피고들과 위 ○○순 및 ○○은 사이의 원고들에 대한 유류분 반환비율은 민법 제1115조제2항에 의하여 각자가 얻은 유증가액의 비례로 산정하여야 할 것입니다.

따라서, 위와 같은 법리에 비추어 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원을 포함시키면 유류분 산정의 기초가 되는 재산액 합계는 2,842,044,196원이 되고, 위 ○○순의 유류분 초과액은 480,976,428원(=증여금 9억300만원 환산액 1,033,464,396×0.6(대습상속비율)+예금채권 상속분 3,000,000 - ○○순 유류분액 142,102,209), 위 ○○은의 유류분 초과액은 320,650,952원(=증여금 9억300만원 환산액 1,033,464,396×0.4(대습상속비율)+예금채권 상속분 2,000,000 - ○○은 유류분액 94,734,806), 피고 ○○화의 유류분 초과액은 902,472,784원, 피고 ○○철의 유류분 초과액은 412,432,984원으로서 유류분 반환의무자들의 유류분 초과액 합계는 2,116,533,148원이 되는 바(갑 제2호증의 1 판결문 참조), 피고 ○○화의 반환액 범위는 98,853,446원(=902,472,784/2,116,533,148×231,837,016, 원 미만 버림)이고, 피고 ○○철의 반환액 범위는 45,176,345원(=412,432,984/2,116,533,148×231,837,016, 원 미만 버림)이 되어야 합니다.

그러나, 위 ○○순 및 ○○은이 유증받은 재산이 없고, 오로지 증여받은 재산만 있을 뿐이므로 민법 제1116조 및 위 대법원 판례에 비추어 위 ○○순 및 ○○은의 원고들에 대한 유류분 반환 분담액을 피고들이 분담해야 하는 바, 결국 피고 ○○화의 유류분 반환액 합계는 136,037,908원(=○○화 분담액 98,853,446 + ○○순, ○○은 분담액 합계 37,184,462)이고, 피고 ○○철의 유류분 반환액 합계는 62,169,764원(=○○철 분담액 45,176,345 + ○○순, ○○은분담액 합계 16,993,419)이 되어야 할 것입니다.

## 5. 의 견

원심 판단과 같이 이 사건 소송이 망 ○○성의 증여금에 관하여 유류분 반환을 구하는 소송이라고 한다면, 원고들은 민법 제1116조 및 위와 같은 대법원 판례의 태도에 비추어 피고들은 망 ○○관의 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원을 증여받은 바가 없으므로 피고들을 상대로 소를 제기할 수 없다고 할 것인

바, 피고들은 당사자적격이 없다고 할 것이므로 이 사건 소를 각하하여 주시고,

이 사건 소송은 망 ○○관의 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원의 유류분 반환을 구하는 소송이 아니라 피고들을 상대로 원고들의 유류분 부족분의 반환을 청구하는 것으로서 선행 소송과 동일한 소송물인 바, 원심 사건의 선행소송인 위 ○○지방법원 ○○지원 20○○가합6556 유류분 반환소송 확정판결의 기판력이 본 건에 미치는 바, 이 사건 소를 각하하여 주시고,

원고들의 선행 소송에서의 태도 및 항소포기 등에 비추어 본 건은 권리남용에 해당하거나 신의성실의 원칙에 위배되므로 원심판결과 같이 소를 각하하여 주시고,

가사, 견해를 달리하여 이 사건 소가 적법하다고 하더라도, 망 ○○관의 망 ○○성에 대한 증여금 9억300만원을 유류분 산정의 기초가 되는 재산액에 포함시킬 경우에는 위와 같이 피고 ○○화의 원고들에 대한 반환액은 각 136,037,908원이고, 피고 ○○철의 유류분 반환액 합계는 62,169,764원인 바, 원심의 선행소송에서 피고 ○○화는 원고들에게 108,845,265원씩을, 피고 ○○철은 원고들에게 53,689,167원씩을 반환하였으므로 그 범위 내에서 원고들의 청구는 기각되어야 할 것입니다.

20○○. 6. .

위 피고들의 소송대리인 법무법인 ○○  
담당변호사 ○○재 (인)

○○고등법원

귀중

[답변서와 준비서면] (유류분반환청구. 유류분반환청구의 대상을 제시한 피고의 항변)<sup>276)</sup>

(피고는 농지를 망인으로부터 증여받아 소유권이전등기를 마친 이래 평온, 공연하게 무과실로 위 5필지의 농지를 등기부시효취득하였다 할 것이므로 위 5필지의 농지는 유류분반환청구의 대상이 아니라는 피고의 항변)

※ 준비서면은 하단 참조

답 변 서

사 건 20○○가합 000 유류분반환청구  
원 고 ○○숙  
피 고 ○○춘 외 1명

위 사건에 관하여 피고들 소송대리인은 다음과 같이 답변합니다.

청구취지에 대한 답변

1. 원고의 청구를 기각한다.
  2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

청구원인에 대한 답변

1. 증여경위
 

(1) 원고와 피고들의 부 소외 망 ○○원은 형제들을 대표하여 선조로부터 물려 받은 토지를 관리, 보존하다가 자신도 마찬가지로 자녀들 중 대표에게 위 토지를 물려주어 영구히 관리, 보존케 하려는 생각을 갖고 있던 중, 자녀들 사이에서 위 토지의 분배문제가 거론되자 위 토지를 장남인 피고 ○○춘에게 증여하여 위 피고로 하여금 토지를 관리, 보존케 하기로 마음먹었습니다.

(2) 그리하여 위 망인은 조세문제 때문에 우선 농지만을 증여하기로 하여 20○○. 3. 17. ○○시 ○○구 ○○동 282 전 1,160㎡와 같은 곳 286 전 2,274㎡

276) 한국법률사무자동화(주) 답변서·준비서면프로그램에서 인용(사이트www.lawebook.com/)



(소장의 별지 제1목록 기재 8, 9토지)에 관하여 피고 ○○춘 명의로 증여를 원인으로 한 소유권이전등기를 경료하고(갑제 2호증의 8, 9 각 부동산등기부등본), 20○○. 12. 11. 같은구 ○○동 107 전 205m<sup>2</sup>, 같은 곳 318 전 2,774m<sup>2</sup> 및 같은 곳 321 전 2,278m<sup>2</sup> (소장의 별지 제1목록 기재 11내지 13 토지)에 관하여 피고 ○○춘 명의로 증여를 원인으로 한 소유권이전등기를 경료하였습니다(갑제 2호증의 11 내지 13 각 부동산등기부등본).

(3) 그후 위 망인은 20○○. 6. 15. 그때까지 망인의 소유로 남아 있던 임야를 세 아들 중 국내에 거주하는 장남과 3남인 피고들에게 증여하여 보존케 하되 나머지 자녀와 망인의 형제자매들에게는 일부 토지를 처분하여 그 처분대금을 분배해 주기로 하였습니다(을제 1호증 인증서).

이에 따라 소장의 별지 제1목록기재 토지 중 임야에 대하여는 피고 ○○춘 명의로, 별지 제2목록기재 토지에 대하여는 3남인 피고 ○○걸 명의로 증여를 원인으로 한 각 소유권이전등기가 경료되었습니다(갑제 2호증의 1 내지 7, 10, 14 내지 17 각 부동산등기부등본).

(4) 그런데 망인 사망 후 피고들이 을제 1호증 인증서의 내용대로 이행할 틈도 주지 않고 원고가 이 사건 소를 제기한 것입니다.

## 2. 원고의 상속재산

망인 소유인 ○○ ○○구 ○○동 669-1 ○○시니어스 ○○타운 407호에 관한 2분의 1지분은 망인의 사망으로 인하여 망인의 처인 ○○순과 자녀들인 원고, 피고들과 소외 ○○환이 공동으로 재산상속하였습니다(갑제 2호증의 18 부동산등기부등본).

## 3. 피고 ○○춘의 시효취득

위 제1의 (2)항에서 본 바와 같이 피고 ○○춘은 ○○시 ○○구 ○○동 282 전 1,160m<sup>2</sup>를 비롯한 소장의 별지 제1목록기재 8, 9, 11 내지 13등 5필지의 농지를 망인으로부터 증여받아 소유권이전등기를 마친 이래 현재까지 10년 이상 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의, 무과실로 위 농지를 경작하고 있습니다. 따라서 피고 ○○춘은 가사 위 증여로 인하여 유류분 권리자인 원고에게 손해

가 있는 것을 알았다 하더라도 위 5필지의 농지를 등기부시효취득하였다 할 것이므로 위 5필지의 농지는 유류분반환청구의 대상이 아니라 할 것입니다.

#### 4. 유류분의 산정

위 제2항에서 본 망인 소유의 ○○ ○○구 ○○동 669-1 ○○시니어스 ○○타운 407호에 관한 2분의 1지분의 가액에 피고 ○○춘이 증여받은 소장의 별지 제1목록 기재 토지 중 제 8, 9, 11 내지 13등 5필지의 농지를 제외한 토지의 가액 및 피고 ○○걸이 증여받은 소장의 별지 제2목록 기재 토지의 가액을 가산하여 원고의 유류분을 산정하여야 할 것입니다.

#### 5. 유류분반환청구의 범위

위 제4항과 같이 산정한 유류분에서 위 제2항에서 본 바와 같이 원고가 상속받은 재산의 가액을 공제한 가액이 원고가 반환을 청구할 유류분 가액이 된다 할 것입니다.

### 입 증 방 법

1. 을제 1호증

인증서

20○○. 5.

피고들 소송대리인 변호사

지방법원 ○○지원 제 1 민사부 귀중

[준비서면] (유류분반환청구, 위 같은 사건)

### 준 비 서 면

사 건 20○○가합 000 유류분반환청구

원 고 ○○숙

피 고 ○○춘 외 1명

위 사건에 관하여 피고들 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다 음

1. 망 ○○원의 생전처분 토지대금의 사용

(1) 원고와 피고들의 부 망 ○○원이 생전에 토지를 처분한 사실은 원고의 주장과 같습니다.

위 망인은 피고들에게 증여하는 토지에 대한 증여세를 마련하고 일부는 자신의 생활비와 병원비를 마련하고자 위와 같이 생전에 토지를 처분한 것입니다.

(2) 그리하여 망인은 위 처분대금 약 17억원에서 처분에 소요된 중개수수료와 양도소득세 등에 지출하고 남은 약 15억원 정도를 가지고 그중 약 12억원은 증여세로 사용하고, 나머지 3억원 정도는 생활비와 의료비등으로 지출하였던 것일 뿐, 그 처분대금에서 피고들에게 증여한 것은 없습니다.

2. 유류분반환청구의 범위

종전에 답변서에서 밝힌 바와 같이 원고의 유류분에서 원고가 상속받은 ○○○○구 ○○동 669-1 ○○타운 407호에 관한 상속지분의 가액을 공제한 가액이 원고가 반환을 청구할 유류분가액이 된다 할 것입니다.

20○○. 6.

피고들 소송대리인

변호사

지방법원 ○○지원 제 1 민사부

귀중

[준비서면] (유류분반환, 재산증식에 기여가 참작되어야 한다는 피고의 항변)  
(피고는 증여받은 재산을 유지, 관리하고 그 가치를 증대시킴에 막대한 기여를 하였으므로 그와 같은 기여가 참작되어야 한다는 피고의 항변)<sup>277)</sup>

## 준 비 서 면

사 건 20○○ 나 000 유류분반환  
원 고 ○○순 외4  
피 고 ○○표

위 사건에 관하여 피고 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

### 다 음

#### 1. 부담부 증여

(1) 피고의 아버지 망 ○○조는 피고에 대한 증여 이전인 20○○. 7. 경 분할전의 ○○시 ○○면 ○○리 507-2 답 5,051㎡를 담보로 ○○농업협동조합에서 2,500만원을 대출받았습니다(갑제 2호증의 1 폐쇄등기부등본, 원고들이 원심에서 제출한 청구취지 및 청구원인변경신청서의 청구원인 3항).

(2) 피고는 이 사건 증여 후 3년이 지난 20○○. 경 위 농협으로부터 채무변제독촉을 받고서야 위와 같은 사실을 알고 경매를 막기 위하여 위 ○○에서 20○○. 7. 경 3,800만원 정도를 대출받아 망 ○○조의 위 대출금의 원리금채무(망 ○○조는 대출이자를 전혀 변제하지 아니하였습니다)를 변제하였습니다.

그리하여 분할 전의 위 토지에 관하여 20○○. 7. 22. 피고를 채무자로 한 채권 최고액 4,560만원의 근저당권설정등기가 경료되었습니다(위 갑제 2 호증의 1).

그러나 위 ○○에서 업무착오인지 망 ○○조를 채무자로 한 기존의 근저당권설정등기를 말소하지 않고 있다가 뒤늦게 20○○. 4. 29. 에서야 말소하였습니다(갑제 2호증의 2 부동산등기부등본).

<sup>277)</sup> 한국법률사무자동화(주) 답변서 · 준비서면프로그램에서 인용(사이트www. lawebook. com/)

- (3) 그후 피고는 피고 부부의 개인적 수입과 처남과 처형을 통하여 사채를 얻어 1년만에 대출금을 모두 변제하고 20〇〇. 7. 3. 피고를 채무자로 한 위 근저당권설정등기를 말소하였습니다(위 강제 2호증의 1 폐쇄등기부 등본).
- (4) 피고 부부는 그후 악착같이 돈을 벌어 7년이나 걸려서 위 사채를 갚았습니다.
- (5) 위에서 본 바에 의하면 피고는 부담부 증여를 받았다 할 것이므로 그 부담인 위 토지의 피담보채무는 증여가액에서 공제되어야 할 것입니다.
- (6) 원고들은 망 〇〇조의 위 채무를 망 〇〇조가 변제한 것이라 하나, 망 〇〇조는 변제할 능력이 없었고, 모든 재산을 피고에게 증여한 후라 변제에 신경을 쓸 이유도 없었습니다.
- 등기부상의 기재에 의하더라도 피고가 대출을 받아 이를 변제하였지 다른 사람이 변제하였다고 볼 수는 없습니다.

## 2. 원고들의 특별수익

- (1) 원고 〇〇순을 제외한 나머지 원고들은 피고와 달리 고등학교까지 교육을 받고(원고 〇〇표 제외) 아버지인 〇〇조로부터 혼수품, 예물 등 결혼비용을 받아 결혼을 하게 되었습니다.
- 오래 전 일이라 그에 대한 자료는 없으나 최소한 원고들 각각 결혼비용으로 1,000만원 이상 소요되었음은 경험칙상 명백한 바, 원고 〇〇순을 제외한 나머지 원고들의 유류분 부족액을 산정함에 있어 최소한 각 1,000만원씩은 공제되어야 할 것입니다.
- (2) 또한 원고 〇〇숙은 20〇〇. 9. 경 아버지로부터 〇〇시 〇〇면 〇〇리 633 지상주택을 증여받았는 바(을제호증 건축물대장, 소유자 명의는 강제 1호증의 1 제적등본에 기재된 〇〇숙의 남편인 〇〇용으로 하였음), 몇 년 후 위 주택을 심플라인 공장에 1,500만원에 처분하였으므로 증여가액을 1,500만원으로 보아야 역시 공제되어야 할 것입니다.

## 3. 원고 〇〇순의 유류분반환청구권 소멸

원고들과 피고 사이에서 유류분반환문제로 분쟁이 발생한 후 피고는 20〇〇.5. 12. 어머니인 원고 〇〇순에게는 1억원을 지급하고 합의하였습니다(을제3호증의 1 내지 4 각 입금증).

이는 피고의 아들인 〇〇현이 이 사건 소제기 후인 20〇〇. 6. 초 원고 〇〇순과 대화 당시 원고 〇〇순 스스로 1억원을 받고 합의를 하였음을 시인하고 있는 바입니다(을제 1호증 녹취서 1쪽, 토지보상금 6억 5,000만원에 대한 원고 〇〇순의 유류분액은 7,500만원이나 이를 초과하여 1억원을 지급한 점을 보더라도 단순히 토지보상금에 대하여만 합의한 것이 아니라 모든 재산에 대한 합의임이 분명합니다).

#### 4. 피고의 기여분

- (1) 피고는 부모의 요구에 따라 중학교 3학년 때 중퇴를 하고 부모와 함께 농사에 전념하였습니다.
- (2) 피고는 20〇〇. 결혼을 한 후로는 부부가 함께 부모를 봉양하며 새벽부터 밤까지 죽도록 농사일을 하였습니다.
- (3) 피고는 아버지로부터 토지를 증여받은 후 근저당채무가 있는 것을 알게 되자 농사만으로는 빚을 갚을 수 없어 20〇〇. 경부터 오늘날까지 섬유공장에 취직하여 일을 하면서도 퇴근 후와 토, 일요일 및 공휴일에는 농사일을 거들었습니다(을제호증 소득금액증명).
- (4) 또한 피고는 상당한 비용을 들여 토지의 일부를 개발하여 재산적 가치를 증대시키는 일도 하였습니다(을제 5호증의 1, 2 참조).
- (5) 위와 같이 피고는 증여받은 재산을 유지, 관리하고 그 가치를 증대시킴에 막대한 기여를 하였는 바, 피고의 그와 같은 기여가 참작되어야 할 것입니다.

#### 입 증 방 법

1. 을제 호증 건축물대장
1. 을제 호증 소득금액증명

20〇〇.8..

피고 소송대리인 변 호 사

고등법원 제 31 민사부 귀중

## 사. 재 판

유류분권자의 반환청구권을 형성권으로 새기는 견해와 청구권이라는 견해의 대립이 있으나 형성권이라고 보는 것이 일반적인 견해이다. 따라서 판결이 확정되면 유류분 부족 한도에서 유증과 증여의 효력이 소멸된다. 즉, 그 유증·증여가 아직 이행되지 않았을 때에는 반환청구권자는 유증·증여하지 않아도 되고, 이미 이행되었을 때에는 증여 받은 사람과 유증 받은 사람은 목적물을 유류분권리자에게 반환하여야 하고, 반환청구를 받은 이후의 그 목적물로부터 얻은 과실(果實)도 반환하여야 한다. 원칙적으로 현물반환의무를 지지만 현물반환 대신 가액반환을 하여도 무방하다.

우리 민법은 유류분제도를 인정하여 제1112조부터 제1118조까지 이에 관하여 규정하면서도 유류분의 반환방법에 관하여 별도의 규정을 두지 않고 있으나, 증여 또는 유증대상 재산 그 자체를 반환하는 것이 통상적인 반환방법이라고 할 것이므로, 유류분 권리자가 원물반환의 방법에 의하여 유류분 반환을 청구하고 그와 같은 원물반환이 가능하다면 달리 특별한 사정이 없는 이상 법원은 유류분 권리자가 청구하는 방법에 따라 원물반환을 명하여야 한다.<sup>278)</sup>

반환의무자는 통상적으로 증여 또는 유증대상 재산 그 자체를 반환하면 될 것이나 위 원물반환이 불가능한 경우에는 그 가액 상당액을 반환할 수밖에 없다.<sup>279)</sup> 침해된 유류분이 비교적 소액이고 현물반환을 인정할 경우 증여재산인 각 부동산의 지분이 너무 복잡해지는 결과가 발생할 때에는 유류분을 가액으로 반환함이 상당하다.<sup>280)</sup> 유류분으로 반환하여야 할 대상이 주식인 경우, 반환의무자가 피상속인으로부터 증여받은 주권 그 자체를 보유하고 있지 않다고 하더라도 그 대체물인 주식을 제3자로부터 취득하여 반환할 수 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한 원물반환의무의 이행이 불가능한 것은 아니다.<sup>281)</sup>

## 4. 유류분반환청구권행사의 효력

### 가. 유류분을 침해한 한도에서 실효

유류분반환청구권을 행사하면 유증·증여는 유류분을 침해하는 부분에 한하여 그 효력이 소멸된다.

278) 대법원 2006. 05. 26. 선고 2005다71949 판결.

279) 대법원 2005. 06. 23. 선고 2004다51887 판결.

280) 제주시방법원 2008. 04. 23. 선고 2007가단22957, 27419 판결: 확정.

281) 대법원 2005. 06. 23. 선고 2004다51887 판결.

유류분권리자가 반환의무자를 상대로 유류분반환청구권을 행사하는 경우 그의 유류분을 침해하는 증여 또는 유증은 소급적으로 효력을 상실하므로, 반환의무자는 유류분권리자의 유류분을 침해하는 범위 내에서 그와 같이 실효된 증여 또는 유증의 목적물을 사용·수익할 권리를 상실하게 되고, 유류분권리자의 목적물에 대한 사용·수익권은 상속개시의 시점에 소급하여 반환의무자에 의하여 침해당한 것이 된다. 그러나 민법 제201조 제1항은 “선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.”고 규정하고 있고, 점유자는 민법 제197조에 의하여 선의로 점유한 것으로 추정되므로, 반환의무자가 악의의 점유자라는 사정이 증명되지 않는 한 반환의무자는 목적물에 대하여 과실수취권이 있다고 할 것이어서 유류분권리자에게 목적물의 사용이익 중 유류분권리자에게 귀속되었어야 할 부분을 부당이득으로 반환할 의무가 없다. 다만, 민법 제197조 제2항은 “선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 소가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 본다.”고 규정하고 있고, 민법 제201조 제2항은 “악의의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 하며 소비하였거나 과실로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한다.”고 규정하고 있으므로, 반환의무자가 악의의 점유자라는 점이 증명된 경우에는 악의의 점유자로 인정된 시점부터, 그렇지 않다고 하더라도 본권에 관한 소에서 종국판결에 의하여 패소로 확정된 경우에는 소가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 의제되어 각 그때부터 유류분권리자에게 목적물의 사용이익 중 유류분권리자에게 귀속되었어야 할 부분을 부당이득으로 반환할 의무가 있다.<sup>282)</sup>

## 나. 원물반환

### (1) 원 칙

우리 민법은 유류분제도를 인정하여 제1112조부터 제1118조까지 이에 관하여 규정하면서도 유류분의 반환방법에 관하여 별도의 규정을 두지 않고 있으나, 증여 또는 유증대상 재산 그 자체를 반환하는 것이 통상적인 반환방법이라고 할 것이므로, 유류분 권리자가 원물반환의 방법에 의하여 유류분 반환을 청구하고 그와 같은 원물반환이 가능하다면 달리 특별한 사정이 없는 이상 법원은 유류분 권리자가 청구하는 방법에 따라 원물반환을 명하여야 한다.<sup>283)</sup>

유류분으로 반환하여야 할 대상이 주식인 경우, 반환의무자가 피상속인으로부터 증여받

282) 대법원 2013. 03. 14. 선고 2010다42624 판결.

283) 대법원 2006. 05. 26. 선고 2005다71949 판결.



은 주권 그 자체를 보유하고 있지 않다고 하더라도 그 대체물인 주식을 제3자로부터 취득하여 반환할 수 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한 원물반환의무의 이행이 불가능한 것은 아니다.<sup>284)</sup>

## (2) 예 외

원물반환이 불가능한 경우에는 그 가액 상당액을 반환할 수밖에 없고, 유류분액을 산정함에 있어 반환의무자가 증여받은 재산의 시가는 상속개시 당시를 기준으로 산정하여야 하고, 당해 반환의무자에 대하여 반환하여야 할 재산의 범위를 확정하는 다음 그 원물반환이 불가능하여 가액반환을 명하는 경우에는 그 가액은 사실심 변론종결 시를 기준으로 산정하여야 한다.<sup>285)</sup>

## (3) 원물반환의무 또는 가액반환의무의 지체책임의 발생 시기

유류분반환청구권의 행사로 인하여 생기는 원물반환의무 또는 가액반환의무는 이행기의 정함이 없는 채무이므로, 반환의무자는 그 의무에 대한 이행청구를 받은 때에 비로소 지체책임을 진다.<sup>286)</sup>

## (4) 반환의무자가 원물반환을 주장하며 가액반환에 반대 의사를 표시한 경우, 법원이 가액반환을 명할 수 있는지 여부

우리 민법은 유류분제도를 인정하여 제1112조부터 제1118조까지 이에 관하여 규정하면서도 유류분의 반환방법에 관하여는 별도의 규정을 두고 있지 않다. 다만 제1115조 제1항이 “부족한 한도에서 그 재산의 반환을 청구할 수 있다”고 규정한 점 등에 비추어 볼 때 반환의무자는 통상적으로 증여 또는 유증 대상 재산 자체를 반환하면 될 것이나 원물반환이 불가능한 경우에는 가액 상당액을 반환할 수밖에 없다. 원물반환이 가능하더라도 유류분권리자와 반환의무자 사이에 가액으로 이를 반환하기로 협의가 이루어지거나 유류분권리자의 가액반환청구에 대하여 반환의무자가 이를 다투지 않은 경우에는 법원은 가액반환을 명할 수 있지만, 유류분권리자의 가액반환청구에 대하여 반환의무자가 원물반환을 주장하며 가액반환에 반대하는 의사를 표시한 경우에는 반환의무자의 의사에 반하여 원물반환이 가능한 재산에 대하여 가액반환을 명할 수 없다.<sup>287)</sup>

284) 대법원 2005. 06. 23. 선고 2004다51887 판결.

285) 대법원 2005. 06. 23. 선고 2004다51887 판결.

286) 대법원 2013. 03. 14. 선고 2010다42624 판결.

287) 대법원 2013. 03. 14. 선고 2010다42624 판결.

### 다. 과실의 반환

수증자는 증여 받은 재산의 반환뿐만 아니라 그 수증재산에서 생긴 과실도 반환하여야 할 것인가? 긍정설과 부정설이 대립하고 있다.<sup>288)</sup> 이에 대하여 우리 민법은 명문의 규정을 두고 있지 않다.

### 라. 수증자가 증여 받은 물건을 제3자에게 다시 양도한 경우

유류분 권리자는 원칙적으로 제3자 보호를 위하여 제3자에 대하여 청구할 수 없고 수증자(양도인)에 대하여 그 가액을 청구할 수 있을 뿐이다(민법 제1014조 유추적용). 즉, 현물반환의 예외로 수증자로부터 증여목적물을 양수한 제3자가 선의인 경우에는 증여받은 자에 대하여 그 가액을 청구할 수 있고, 제3자가 악의인 경우에는 목적물을 청구할 수 있다.<sup>289)</sup> 판례<sup>290)</sup>도 “그 양수인이 양도 당시 유류분권리자를 해함을 안 때에는 양수인에 대하여도 그 재산의 반환을 청구할 수 있다.”고 하였다.

### 마. 반환청구를 받은 수증자·수유자가 무자력인 경우

수증자가 무자력이라고 하여 반환의무 그 자체가 소멸되는 것이 아니다. 그로 인한 손실은 유류분권리자의 부담이 될 수밖에 없다.

## 5. 유류분반환청구권의 소멸

### 가. 단기소멸시효

유류분반환청구권은 유류분 권리자가 상속의 개시와 반환하여야 할 증여 또는 유증을 한 사실을 안 때로부터 1년 내에 하지 아니하면 시효에 의하여 소멸한다(민법 제1117조 후단).

유류분 권리자가 수증자와의 재판과정에서 수증자의 증여 주장 및 그에 부합하는 증언의 존재를 알았다는 것만으로는 증여사실을 알았다고 할 수 없다고 한 사례<sup>291)</sup>가 있다. 이와 같은 판례는 상속인을 보호하는 데는 좋지만 제3자의 보호에는 미흡하기 때문에 그 기산점을 유류분 권리자가 상속개시와 유증·증여를 한 사실을 안 때로 해야 한다는 견해가 있다.

288) 박동섭, 앞의 책, 842면.

289) 김주수·김상용, 앞의 책, 747면; 박병호, 앞의 책, 481면.

290) 대법원 2002. 04. 26. 선고 2000다8878 판결; 반대설은 송덕수, 앞의 책, 1978면.

291) 대법원 1994. 04. 12. 선고 93다52563 판결.

민법 제1117조는 유류분반환청구권은 유류분 권리자가 상속의 개시와 반환하여야 할 증여 또는 유증을 한 사실을 안 때로부터 1년 내에 하지 아니하면 시효에 의하여 소멸한다고 규정하고 있는바, 여기서 ‘반환하여야 할 증여 등을 한 사실을 안 때’라 함은 증여 등의 사실 및 이것이 반환하여야 할 것임을 안 때라고 해석하여야 하므로, 유류분 권리자가 증여 등이 무효라고 믿고 소송상 항쟁하고 있는 경우에는 증여 등의 사실을 안 것만으로 곧바로 반환하여야 할 증여가 있었다는 것까지 알고 있다고 단정할 수는 없을 것이나, 민법이 유류분반환청구권에 관하여 특별히 단기소멸시효를 규정한 취지에 비추어 보면 유류분 권리자가 소송상 무효를 주장하기만 하면 그것이 근거 없는 구실에 지나지 아니한 경우에도 시효는 진행하지 않는다 함은 부당하므로, 피상속인의 거의 전 재산이 증여되었고 유류분 권리자가 위 사실을 인식하고 있는 경우에는, 무효의 주장에 관하여 일응 사실상 또는 법률상 근거가 있고 그 권리자가 위 무효를 믿고 있었기 때문에 유류분반환청구권을 행사하지 않았다는 점을 당연히 수긍할 수 있는 특별한 사정이 인정되지 않는 한, 위 증여가 반환될 수 있는 것임을 알고 있었다고 추인함이 상당하다.<sup>292)</sup>

#### 나. 10년의 제척기간

상속이 개시된 때로부터 10년이 경과하면 반환청구권은 소멸한다(민법 제1117조 후단). 이러한 법리는 상속재산의 증여에 따른 소유권이전등기가 이루어지지 아니한 경우에도 달리 그 소멸시효 완성의 항변이 신의성실의 원칙에 반한다고 하는 등의 특별한 사정이 존재하지 아니하는 이상 달리 볼 것이 아니다. 따라서 원심이 망인의 상속재산에 속하는 이 사건 각 부동산에 관한 피고의 유류분반환청구권의 행사가 망인의 사망에 따른 상속개시일부터 10년이 지나 시효로 소멸한 후인 원심에 이르러 비로소 행사되었다는 이유를 들어, 위 유류분반환청구권에 기한 피고의 항변을 배척한 것은 정당하다.<sup>293)</sup>

유류분반환청구 기간에 관한 민법 제1117조 후단 소정의 ‘10년’이 소멸시효기간인지 여부에 대하여 판례<sup>294)</sup>는 “민법 제1117조의 규정내용 및 형식에 비추어 볼 때 같은 법조 전단의 1년의 기간은 물론 같은 법조 후단의 10년의 기간도 그 성질은 소멸시효기간이다”라고 판시하나 학설은 제척기간이라고 본다.

292) 대법원 2001. 09. 14. 선고 2000다66430, 66447 판결.

293) 대법원 2008. 07. 10. 선고 2007다9719 판결.

294) 대법원 1993. 04. 13. 선고 92다3595 판결.

### 다. 소멸시효의 중단

상속재산분할심판절차에서 종전에 하였던 유류분반환 주장을 철회한 것이 유류분반환 청구가 가정법원의 관할에 속하지 않는 점을 고려한 데서 비롯된 법원에 대한 의사표시일 뿐 사법상의 유류분반환청구의 의사표시를 취소하거나 철회한 것으로 볼 수는 없다.<sup>295)</sup>

## 6. 민법 제1113조 제2항의 규정에 의한 감정인의 선임

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.33), 라류 가사비송사건]

유류분 산정에 있어 상속재산 중에 조건부채권이나 존속기간이 불확정한 채권이 있는 경우, 가정법원이 선임한 감정인이 이를 평가한다. 이는 라류 가사비송사건이다. 이에 관하여는 ‘제5관 감정인의 선임’ 771면 참조한다.

295) 대법원 2002. 04. 26. 선고 2000다8878 판결 : 원고가 1996. 11. 13. 유언공정증서의 진정 성립을 인정한 때에 반환하여야 할 유증이 있었다는 사실을 알았다고 하더라도, 그로부터 1년이 경과하기 전인 1997. 2. 4. 내지 같은 해 3. 3. 경 피고 등에게 이 사건 유증에 관하여 유류분반환을 구하는 의사표시를 함으로써 민법 제1117조에 정한 소멸시효의 진행이 중단 되었고, 원고가 같은 해 5. 28. 유류분 주장을 철회한 것은 어디까지나 유류분반환청구가 가정법원의 관할에 속하지 않는 점을 고려한 데서 비롯된 법원에 대한 의사표시일 뿐이므로, 이로써 종전에 피고 등에 대하여 한 사법상의 유류분반환청구의 의사표시를 취소하거나 철회한 것으로 볼 수는 없다.